

論行政強制執行之權利救濟體系 與保障內涵^{*}

—— 以行為、不行為或容忍義務之執行為探討重心

李建良^{**}

目 次

壹、序論：行政強制體系與救濟體系之關聯性	二、基礎處分與行政執行之關聯性與救濟問題
貳、行政執行之基本概念與體系	三、行政執行之救濟機制與行政爭訟之關係
參、行為、不行為或容忍義務執行之基本構造	四、各別執行措施之救濟問題：執行行為之法律性質及其救濟方法
一、制度構造	五、第三人之權利救濟問題
二、程序構造：「多階段」暨「多層次」之行政程序	六、執行完畢之權利救濟問題
肆、行政執行之救濟問題與體系建構	伍、綜合論述
一、基礎處分與行政執行之區隔性與救濟問題	

* 投稿日：2012年11月7日；接受刊登日：2013年5月21日。〔責任校對：陳嬋恬〕。

** 中央研究院法律學研究所研究員。

摘 要

行政執行，係行政機關以強制方法促使義務人履行其行政法上義務，或實現與履行義務同一內容狀態之制度，其對人民之身體、自由、人格或財產等權利造成直接而重大之干預，不僅須有法律之依據（法律保留），且須遵守形式要件與正當程序（正當法律程序），合乎實質之法律要求（例如比例原則、平等原則），並應給予人民在權利受侵害時尋求司法救濟之機會（訴訟權及權利救濟保障），始合於法治國原則之要求。關於行政執行之權利救濟制度，現行法之規範頗為零散，且多有闕漏，亟待綜整，並加補充，方能建立一套完整井然的救濟體系與制度內涵，此為本文之所由作。礙於篇幅，本文先將研究重點置於公法上行為、不行為或容忍義務之強制執行。本文的特點有四：在進入正題之前，先略述行政執行之基本概念與體系，以作為觀照比對之基礎。其次，關於行政執行救濟體系之分析，並非單純現行法條文的實然解釋，而是法制、學理與實務間之交叉辯難，嘗試建立行政執行救濟之應然體系。再者，本文研究探討之標的不侷限於行政執行方法等枝節性之救濟問題，而是更大格局地擴及囊括作為行政執行名義之基礎處分。最後，秉承「執执行程序終結不等於權利救濟終結」的基本觀念，本文探討「執行完畢」的權利救濟問題，以臻體系之完整，並與基礎處分（執行名義）與行政執行（執行行為）關聯課題，首尾相契、前後呼應。

關鍵詞：行政執行、權利救濟、公法上行為、不行為或容忍義務、行政處分、執行名義、執行方法、即時強制。

On the Judicial Remedies and Rights Protection in the Administrative Enforcement

Focusing on the Enforcement of Action, Non-action or Forbearance

*Chien-Liang Lee**

Abstract

Administrative enforcement is a system for administrative agencies to compel an obligor to fulfill an obligation in administrative law or to achieve a state of affairs to the same effect as the obligation in its fulfillment, through coercive methods. The system severely interferes with the body, freedom, personal and property rights of the people. Thus it requires authorization of law, due process of law, compliance of formal and substantial requirements of law and the opportunity of legal remedy when rights are violated, which are all part of the principle of rule of law. This system of remedy is fractioned under current legislation and is in need of amendment to form a coherent regime, which is the purpose of this article. Due to space limit, this article focuses on the enforcement of Action, Non-action or Forbearance.

This article has four features. First, there is a brief introduction of the basic concepts and structure of administrative enforcement as the basis of comparison before entering the main argument. Second, it encompasses an analysis of the remedy system of administrative enforcement, not limited to the interpretation of statute, but a cross reference between current regime, theory and practice, to construct the

* Research Professor, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.

administrative enforcement remedy system that ought to be. Third, the aim of this article is not confined to the details of the remedy for the manner of enforcement, but includes the remedy for the fundamental administrative act as entitlement foreclosure. Last, it maintains the idea that “the end of enforcement process is not the end of remedy,” and discusses the remedy of “concluded enforcement”.

Keywords: administrative enforcement, remedy of rights, public law obligations of action, non-action or forbearance, administrative act, entitlement foreclosure, manner of enforcement, immediate coercion.

壹、序論：行政強制體系與救濟體系之關聯性

行政執行，行政法上之強制執行，係指國家機關以強制方法促使（強迫）義務人¹履行其行政法上義務，或實現與履行義務同一內容狀態之制度，規範此一制度之法律，謂之「行政執行法」²。從干預程度以言，行政執行可說是對人民權利（身體、自由、人格及財產）直接且重大之行政行為。基於法治國家之原則，行政執行不僅須有法律之依據（法律保留），且須遵守形式要件與正當程序（正當法律程序），合乎實質之法律要求（例如比例原則、平等原則），並應給予人民在權利受侵害時尋求司法救濟之機會（訴訟權及權利救濟保障）。在事前、事中及事後的法治體系中，（司法）權利救濟體系雖居於後端，對於人民權利的保障卻具有鎖鑰之關鍵地位，其重要性往往甚於前端之保障。蓋行政執行係以行政執行法為依據，基本上不生法律保留上之疑慮³；而行政執行之實質要件及

¹ 按行政執行法第9條、第11條第1項、第13條至第19條、第21條、第24條等規定，行政執行之對象為「義務人」。所謂「義務人」之概念，除人民外，尚包括行政主體及行政機關。換言之，主管機關亦得依法課予行政主體或行政機關公法上之義務，於義務不履行時，予以行政上強制執行。關於行政主體為義務人而為行政執行之情形，行政執行法第26條準用強制執行法之規定，後者於強制執行法第122條之1至第122條之4設有「對於公法人財產之執行」規定，可資適用，實務上亦不乏其例。譬如健保局曾因臺北市堅持拒繳補助款，依行政執行法之規定，移送法務部行政執行處強制執行。行政執行處並查封臺北市所屬公用財產，計30筆土地。

由於以行政主體或行政機關為對象課予公法上之義務者，絕大多數屬於公法上金錢給付義務，鮮少課予行為、不行為或容忍義務者，復以本文主要以行為、不行為或容忍義務之執行為探討重心，義務人多半是人民，故以下僅稱人民，必要時使用「義務人」概念，特先指明。

² 行政執行法第2條規定：「本法所稱行政執行，指公法上金錢給付義務、行為或不行為義務之強制執行及即時強制。」嚴格而言，此項規定並非行政執行之立法定義，僅是行政執行之類別。惟綜合本法第27條及第28條第2項第5款之規定，仍可得出本文開篇之行政執行制度定義。

³ 在舊行政執行法時期，由於欠缺公法上金錢給付義務執行之規定，曾引發是否違反法律保留原則之疑義及能否由行政機關強制執行之爭論。彼時大法官解釋採否定說，並堅持須由法院強制執行，就人權保障及法治行政之落實而言，值得肯定。參見司法院釋字第16號解釋：「強制執行法施行後，強制執行僅得由

程序要求，行政執行法設有基本之規定，可資援用。儘管如此，行政執行法規定之解釋、適用，於學說及實務上仍存有諸多爭議與歧見，執行機關是否確實恪遵法治規範及正當程序，亦未必可知，須透過司法救濟之途徑，檢視審斷，定分止爭，方能樹立行政執行之規矩繩墨。是以，行政執行之救濟問題對行政執行制度自身具有一種反饋力度，既可從救濟觀點反思行政強制的要件及程序、執行方法等法制是否完備，實務運作有無商榷之處，亦可正向促成行政強制法治之實踐與人權保障基本原則（如比例原則、平等原則）之落實。

行政執行之權利救濟制度，其重要性固如前述，然現行法對此之規範，卻頗為零散，且多有闕漏，亟待綜整，並加補充，方以建立一套完整井然的救濟體系與制度內涵，此本文所由作之衷旨。為期讀者準確掌握題意、避免誤解，容先作三點說明：

第一，行政執行既是強制**義務人**履行公法上**義務**，則義務之存在，乃行政強制之核心要素。依「應履行義務內容」之不同，行政執行可大別為「公法上金錢給付義務之執行」及「公法上行為、不行為或容忍義務之執行」二種，前者如課稅處分或罰鍰處分之執行；後者如違章建築拆除處分之執行、停工停業處分之執行或強制人民施打預防針等。此二種行政強制之制度，在執行機關、執行程序、執行方法，乃至於權利救濟等方面，頗多差異，在研究方法上允應採「分進合擊」之策略，分別剖析，再綜以論述。礙於篇幅，本文擬先將重點置於公法上行為、不行為義務之強制執行，僅於必要相關處，兼論公法上金錢給付義務之強制執行。

法院為之。行政官署依法科處之罰鍰，除依法移送法院辦理外，不得逕就抗不繳納者之財產而為強制執行。本院院解字第三三零八號解釋，仍應適用。」司法院釋字第35號解釋：「對人民財產為強制執行，非有強制執行法第四條所列之執行名義，不得為之。行政機關依法科處罰鍰之公文書，如法律定有送由法院強制執行或得移送法院辦理者，自得認為同法第四條第六款所規定之執行名義，否則不能逕據以為強制執行。」

第二，行政執行之行政強制體系與救濟體系之間具有相互影響、彼此連動之關聯性。行政強制執执行程序之開始與進行，人民如何救濟、救濟何事，乃至於現行救濟法制是否完備等問題，無不繫於行政強制執行之法律體系與制度內涵。唯有明悉行政執行之體系骨架與程序構造，井然有序之行政執行救濟體系構建，方始可期。有鑑於此，本文在進入行政執行救濟體系的正題之前，先略述行政執行之基本概念與體系，以作為觀照比對之基礎。

第三，行政執行法之現制，相對於1932年制定、1947年修訂之舊法，雖有大幅度的翻修與更新，但不可諱言的是，行政執行新法自2001年1月1日實施至今，不論學說見解或司法實務，均存有諸多歧見與爭議，顯示現行法制未臻完備。因此，行政執行救濟問題之分析及其法律體系之建構與開展，自難以行政執行法之現行規定為基礎，專事法條之註解與詮釋，而有必要參採國外法制與學說，進行反思性與前瞻性之論述。準此考量，本文關於行政強制執行救濟體系之分析，並非單純現行法條文的實然解釋，而是法制、學理與實務間之交叉辯難，嘗試建立行政執行救濟之應然體系⁴。

第四，本文雖以「行政強制執行之權利救濟體系」設題，然基於行政強制體系與救濟體系之間具有緊密關聯之思維前提，研究探討之標的不侷限在行政執行方法等枝節性之救濟問題，而是更大格局地擴及囊括作為行政執行名義之基礎處分，此為行政執行救濟體系建構不可或缺之一環，亦為行政執行法學研究的必要之舉。為期讀者掌握作者的思路理脈，先就本文所欲探討之問題與課題，試作骨架輪廓的描述，並略作重點說明，期以收綱舉目張之效，利於本

4 本文以我國法上之行政執行制度為論述中心，若僅是「重述」現行規定，而不思檢討、興革，則不惟減損本文之學術價值，亦有失法學研究者的本分。因此，本文觀點或多有與我國行政執行制度或學者通見「有所扞格」之處，此乃作者針對現行法制及學理的批判之見，期能對當前法制闕漏或偏失有所導正，敬祈讀者諒察作者亟欲補偏救弊之學術微願與寫作初衷。

文之閱讀與理解：

一、首論行政執行之基本概念與體系構造（貳），闡明行政執行的制度本旨，並建立「多階段」暨「多層次」程序構造之基本觀念（參、二）。

二、在前述之基本架構下，次析行政執行救濟問題之基礎課題：基礎處分（執行名義）與行政執行的「區隔性」與「關聯性」（肆、一；肆、二），後者尤其重要，於學理與實務上頗多爭擾，此又以基礎處分所依據之事實或法律事後變更是否及如何影響行政執行之問題為最，即：事實或法律事後變更是否及如何構成「阻卻執行事由」，以及由此衍生之救濟問題，同時帶出「行政處分違法判斷基準時」與「行政程序重開」兩組涉乎事實法律變動之行政救濟課題，形成「行政爭訟之違法判斷基準時」、「行政程序重開之適用範圍」及「行政執行程序之終止」三者交互連動的關係（肆、二），為本文最為精微之處。

三、在究明基礎處分（執行名義）與行政執行（執行行為）之區隔與關聯課題之後，緊接闡述行政執行之救濟機制與行政爭訟之關聯（肆、三）。由於行政法院過往抱持「行政執行不得司法救濟」的偏差立場，直至近期始有改變，故此一問題之闡述尤不可免。

四、在廓清架構性、基礎性之課題後，本文進入「各別執行措施」之救濟問題的討論（肆、四），內容含括執行行為之法律性質及其救濟方法等問題的探討。

五、在完整論述以「義務人」為主軸的行政執行救濟體系後，本文將研究觸角延伸至「第三人」在執行情序中之權利地位與救濟課題（肆、五）。此部分之探論，一定程度與「義務人」之救濟問題互為表裡，允有併予研析之必要。

六、秉承「執行程序終結不等於權利救濟終結」的基本觀念，本文最後探討「執行完畢」的權利救濟問題（肆、六），以臻體系之完整，並與本文起論之基礎處分（執行名義）與行政執行（執行行為）關聯課題，首尾相契、前後呼應。

為方便思考，利於抽象法規之理解與法學原理之解說，在開論之前，先設想一則簡單的案例：

【思考案例】某甲擁有一筆土地，位於禁建區，因申請建築執照未獲許可，乃於該地私自建築房屋。主管機關獲報後，以甲未經許可擅自建築為由，限期命其拆除。於行政執行程序中，主管機關廢止該禁建區之劃定。試問：甲如何循行政爭訟程序，謀求救濟？

貳、行政執行之基本概念與體系

行政執行，旨在強制人民履行其公法上義務，屬行政權之一種作用，其特點在於行政機關得逕以自己之名義實施強制執行，不必如民事強制執行，必須事先取得司法機關之裁判，以之作為執行名義，始得施以強制執行⁵。

行政執行之程序，通常接續於行政機關作成「課予義務之行政處分」（下命處分）的程序之後。此一程序構造特徵，猶如民事強制執行程序接續於民事訴訟程序之後⁶，而以法院作成確定判決為訴訟程序之終結。就法治國家原則之意旨及行政執行之基本構造而言，行政處分寓有「具體化（公法上法律關係）及建立執行名義之

⁵ 參見強制執行法第4條第1項。

⁶ 續接於民事強制執行之前者，除民事訴訟程序外，在現行法制中，尚有如公證法第13條規定得逕受強制執行約定之公證書等情形，自不待言。

功能」(Konkretisierungs- und Titelfunktion)⁷。經由行政程序之進行，行政處分將國家與人民之間的行政法律關係(Verwaltungsverhältnis)作有拘束力之具體化，以此行政處分為基礎(可稱為「基礎處分」⁸)，構成隨後之執行政程序的「執行名義」(Vollstreckungstitel)。在法治意義上，行政處分兼具行政執行之實體法上及程序法上之基礎，從而所謂之行政執行，毋寧原則上應該是「行政處分之執行」(Verwaltungsaktvollstreckung)⁹。即如【思考案例】之建築主管機關發現有違章建築，而限期命甲拆除其房屋，甲因該拆除處分(基礎處分)而負有拆除之義務(具體之公法上行為義務)。甲如未依限履行拆除義務，而由建築主管機關派人實施強制拆除措施者，即屬於貫徹「命拆除處分」之行政強制執行。

由於行政機關以「強制力」執行行政任務，係於課予人民公法上義務之後，另對人民權利附加之新負擔或不利益，故行政執行應是行政機關干預人民權利的一種獨立類型，有別於基礎行政處分課予人民義務所造成之不利益。基於法治國原則之旨趣，行政機關所據以作成基礎行政處分之法律依據(「處分權」)，不足以作為行政執行(「強制權」)之授權基礎。從而，行政執行之實施，應另有法律之依據，始得為之，尤其執行之「方法」及「程序」等事項，更應以法律作明確詳盡之規範，始合乎法治國原則之要求，並確保人民之權益¹⁰。於上例中，建管機關命違章建築所有人拆除違建之決

7 參見Ludwig Renck, Verwaltungsakt und Feststellungsklage – BVerwGE 26, 161, JuS 1970, S. 113 (115); Michael App/Arno Wettlaufer, Verwaltungsvollstreckungsrecht, 4. Aufl., 2005, § 7 Rn. 1.

8 即德國學理上之„Grundverfügung“或„Grundverwaltungsakt“，參見Jürgen Vahle, Der sofortige Vollzug im Verwaltungsvollstreckungsrecht – Begriff, Voraussetzungen, Prüfungsschemata, DVP 1994, S. 91 (92); Hanno-Dirk Lemke, Verwaltungsvollstreckungsrecht des Bundes und der Länder, 1997, S. 123.

9 參見Rainer Pietzner, Rechtsschutz in der Verwaltungsvollstreckung, VerwArch 84 (1993), S. 261 (261).

10 參見Hans J. Wolff/Otto Bachof/Rolf Stober/Winfried Kluth, Verwaltungsrecht, Bd. 2, 7. Aufl., 2010, § 64 Rn. 10.

定——「基礎處分」，與屬於貫徹該基礎處分之強制拆除措施——「行政強制手段」，二者分屬不同層面之問題。

行政執行既是「行政處分之執行」，則行政機關通常須依法定職權，先以行政處分課予人民一定之義務（基礎處分），再於人民不履行其義務，且經法定之催告程序而仍無效果時，始得以強制手段促其履行義務（強制執行）。此種依序遞進之行政執行政程序，往往無法應付突發事件或急迫之情況。例如行政機關遇有（因人民違反行政法上之義務所生）急迫危險而欲排除之，若嚴格要求其必須先作成行政處分、再循序採取執行措施，則勢將貽誤排除危險之時機。是以，於遇有急迫危險之例外情形，容應允許行政機關不先作成行政處分（免除行政機關作成行政處分之義務，而非免除人民排除危險之義務），即採取一定之強制措施，以遂行行政任務。此種「無行政處分之行政強制」（*Verwaltungszwang ohne vorausgehenden Verwaltungsakt*）¹¹，不以「人民行政法上義務之執行名義化」（*Titulierung verwaltungsrechtlicher Bürgerpflichten*）為前置程序，而是由行政機關在一種時間與程序皆予縮減的集中過程中，「立即」採取強制方式以達到義務已履行之同一狀態¹²。德國學說上將此稱之為「即時強制」（*sofortiger Zwang*）¹³；在法制上除有「即時強制」之用詞外，另有「即時執行」（*sofortiger Vollzug*）¹⁴或「直接

¹¹ 參見 *Pietzner* (Fn. 9), S. 263; *App/Wettlaufer* (Fn. 7), § 7 Rn. 10.

¹² 參見 *Rainer Pietzner*, *Unmittelbare Ausführung als fiktiver Verwaltungsakt*, *VerwArch* 82 (1991), S. 291 (291 ff.).

¹³ 此一用語源自威瑪憲法時期學者 *Richard Thoma*，參見 *Richard Thoma*, *Der Polizeibefehl im Badischen Recht: Dargestellt auf rechtsvergleichender Grundlage*, 1906, S. 95.

¹⁴ 參見德國聯邦行政強制執行法第6條第2項規定。惟有學者認為「即時執行」（*sofortiger Vollzug*）此一概念容易引起誤解，蓋即時強制實際上並無行政處分之存在，從而並非嚴格意義之「行政處分執行」（無行政處分可資執行），參見 *Hanns Engelhardt/Michael App*, *Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz: Kommentar unter besonderer Berücksichtigung der landesrechtlichen Bestimmungen*, 3. Aufl., 1992, Anm. IV zu § 6 VwVG。另有學者

執行」(unmittelbare Ausführung)之稱語¹⁵。

基於上述的理解，吾人可從行政強制權之發動條件與實施程序的角度出發，將行政執行區分為「一般之行政強制」(或稱行政上之強制執行)與「即時強制」二種，前者係指行政機關依法定職權，先以行政處分課予人民一定之義務，於人民不履行其義務時，經法定之催告程序而仍無效果時，再以強制手段促其履行義務；後者則指遇有急迫之情事，由行政機關直接採取必要之強制措施，以排除危害，無須先以行政處分課予人民義務，且無須踐行法定之催告程序，故即時強制乃屬一般行政強制之例外情形¹⁶。換言之，即時強制著重於「執行政程序之簡化」，其與「公法上行為、不行為或容忍義務之執行」之間，應是一種「原則——例外」之關係¹⁷，而

主張此種執行行為「同時」具備行政處分之作作用，或是一種「默示之行政處分」(konkludenter Verwaltungsakt)，而得為即時強制之基礎。不過，聯邦行政強制執行法第6條第2項之立法理由：「(即時強制)之情形，乃必須立即有所行動，不可能事前作出行政處分，或者取得行政法院之裁判。針對此種無法立即作成行政處分之情況，規定行政強制亦得立即為之。」(參照BT-Drucks. I/3981 S. 8 zu § 6)，故即時強制(即時執行)之執行，實際上並無行政處分(基礎處分)之作成。至於即時強制之法律性質為何，則屬另一問題(詳見後述)。倒是「即時執行」(sofortiger Vollzug)此一概念須與德國行政訴訟法上之「立即執行」(sofortige Vollziehung)相區別，後者係指行政處分之執行，不因人民對之提起行政爭訟而停止。參見德國行政法院法第80條規定。

- 15 此一用語最早見於普魯士警察法第44條第1項第2句。關於「即時執行」(sofortiger Vollzug)與「直接執行」(unmittelbare Ausführung)之區別及其問題，參見Dieter Kugelman, Die unmittelbare Ausführung und die sofortige Anwendung von Verwaltungszwang, DÖV 1997, S. 153 (153-160)。

德國各邦之規定，基本上係取法1977年11月25日所頒行之「聯邦及各邦統一警察法模範草案」，主要兩種規範模式，一是「措施之直接執行」，其內容為：「警察得自行或委託他人直接執行措施，如該措施之目的無法或無法及時由義務人達成者，此項措施應立即告知措施之相對人。」二是「即時強制」，其內容為：「為防止危險之必要，特別是無法或無法及時對義務人採取措施，或無效果，且在警察職權範圍內者，得不先為行政處分而實施行政強制。」詳參李建良，行政上即時強制之研究，收於：國立政治大學法學院編，1998年海峽兩岸行政法學術研討會實錄，頁232以下（1999年）。

- 16 參見Fritz Fleiner, Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., 1913, S. 216.

- 17 同說參見陳敏，行政法總論，7版，頁874（2011年）：對人民行為或不行為義

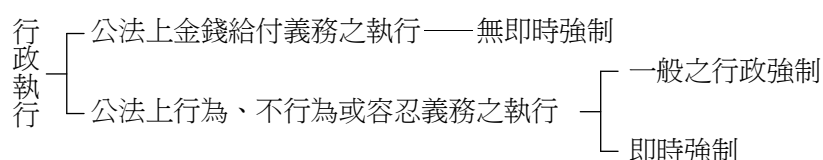
非二種彼此獨立、互無關連之制度¹⁸。例如於【思考案例】中，主

務之行政強制執行，原則上係以人民不履行經行政機關以行政處分設定之義務為條件，並須告戒及核定具體之強制方法（間接強制、直接強制），始得使用該強制方法。惟行政機關在有當前之緊急危害，不能等待行政處分作成，再依一般程序予以執行之情形，立即在法定職權範圍內，依法律規定採取必要之措施，即為所謂之「即時強制」。為一種簡化程序之緊急措施，其實質內容可以為「直接強制」，亦可以為間接強制之「代履行」。

- 18 或謂：即時強制可運用「代履行」或「直接強制」二種方法，與我國行政執行制度有所扞格。實則，「代履行」與「直接強制」二種方法與即時強制有無扞格，端視如何理解「代履行」與「直接強制」此二種方法，以及我國行政執行法如何規定。依行政執行法第29條第1項規定，代履行係執行機關委託第三人或指定人員代為履行能由他人代為履行之行為義務；依同法第28條第2項，直接強制除例示之四種情形外，係指以實力直接實現與履行義務同一內容狀態之方法。行政執行法第36條以下有關「即時強制」之規定，雖未出現「代履行」與「直接強制」此二法律用語，而是以「對於人之管束」、「對於物之扣留、使用、處置或限制其使用」、「對於住宅、建築物或其他處所之進入」、「其他依法定職權所為之必要處置」列舉「即時強制方法」，並就前四種方法明定動用的法定要件。僅先就「其他依法定職權所為之必要處置」以論，在解釋上即可能包含「其他依法定職權」所為之「代履行或直接強制」措施。次就「對於人之管束」而言，其實施之方法無非直接以實力對於人民身體所為之強制措施，屬於一種直接強制方法，以行政執行法第37條第1項第4款「有害公共安全之虞，非管束不能預防危害者」為例，執行機關施以管束措施，乃因受管束者有害公共安全之虞（例如受管束者罹有非典型傳染病），非管束不能預防危害。換言之，受管束者自身負有不危害公共安全之義務，故執行機關以實力直接實現與履行義務同一內容狀態。再者，「對於物之扣留、使用、處置或限制其使用」的內涵，行政執行法第38條、第39條有更進一步之規定，其中「扣留」乃以實力剝奪對物（尤其是危險物）之占有，屬於以實力直接實現與履行義務（不得占有危險物之義務）同一內容狀態的直接強制方法；又如「遇有天災，處置建築物，以達防護之目的」，例如建築物有倒塌之虞，執行機關雇工予以拆除或為牢固措施，則屬代履行措施，蓋有倒塌之虞的建築物所有人原負有拆除或使牢固之義務，屬能由他人代為履行之行為義務。最後，關於「對於住宅、建築物或其他處所之進入」即時強制方法的實施，行政執行法第40條明定，以人民之生命、身體、財產有迫切之危害，非進入不能救護者為限。然受救護者未必是住宅、建築物或其他處所之所有人或管理人。是以，若遇有住宅、建築物或其他處所之所有人或管理人拒絕執行機關進入救護之情形，執行機關採取之強制進入措施（例如破門而入），即屬以實力直接實現與履行義務同一內容狀態之直接強制方法。準此以言，即時強制可運用「代履行」或「直接強制」二種方法，與我國行政執行制度並無扞格之處。相同觀念，另請參見劉淑範，水土保持法第二十七條「警察職權」之現行適用相關問題與立法商榷，收於：行政院農業委員會、國立臺灣大學編，水土保持法技師簽證、代履行及警察職權問題之研究，八十五年度水土保持及集水區經營研究計畫成果彙編，頁600（1997年）。

管機關發現違章建築時，原則上應先以行政處分命其自行拆除，於不履行時，得依一定程序強制拆除。惟該違章建築如有立即倒塌之虞，且無法及時課予所有人拆除義務者，主管機關即得逕為拆除，無須先為命拆除之處分。此種特殊之行政強制類型應僅存在於行為、不行為義務之執行。至於公法上金錢給付義務之執行，通常不致發生急迫之情事，而無即時強制可言¹⁹。為便於觀察，謹圖示如下（【附圖一】），俾供參考²⁰：

【附圖一】



現行行政執行法第2條規定：「本法所稱行政執行，指公法上金錢給付義務、行為或不行為義務之強制執行及即時強制」；第36條第1項規定：「行政機關為阻止犯罪、危害之發生或避免急迫危險，而有即時處置之必要時，得為即時強制」，其修正理由並指出：「即時強制無須先有義務存在，多係出於緊急情況，較一般行政執行，更易影響人民權益，爰參照德國立法例（西德聯邦行政強制執行法第六條第二項、西德萊因·柏爾茲邦行政強制執行法第六十一條第

¹⁹ 關於行政執行之基本體系，另可參見 *Hans-Günther König*, System des verwaltungsbehördlichen Vollstreckungsrechts, BayVBl. 1967, S. 262 (262 ff.).

²⁰ 關於行政執行之分類，國內學者見解不一，茲例述如下，俾供對照：例如學者陳新民以人民有無「違反義務」，將行政強制執行分為「行政上之強制執行」與「即時強制」兩大類，參見陳新民，行政法學總論，修訂6版，頁294（1997年）；又如學者李震山依義務發生原因之不同，將行政執行區分為「本於法令之行政處分所為之執行」與「直接依法令之規定所為之執行」兩大類，前者又可分為作為、不作為、忍受義務之執行與金錢給付義務之執行；後者則可分為即時強制（義務人在場）與直接強制（義務人不在場，只對物）二種，參見李震山，行政法導論，頁316-317（1997年）。

二項) 明定其要件」。由是可知，現行行政執行法係將行政執行分成「公法上金錢給付義務之強制執行」、「行為或不行為義務之強制執行」及「即時強制」三種，並按此三種類型分章規定其執行方法與程序，特別是「即時強制」乃「行為或不行為義務之強制執行」以外之另項獨立強制執行制度，「無須先有義務存在」，與行政執行係「義務之強制」迥然相異，二者呈互無關連之兩制。此種分類方式不僅生適用上之疑義，且無論在法理上或比較法上均有頗值商榷之處。直接而明顯的適用問題是，現行行政執行法欠缺「有義務存在，但因情況急迫而須直接實施強制措施」之規定，此一立法上的疏誤²¹於實務運作上造成頗多困擾²²。其次，修正理由所示參照之德國立法例，其中德國聯邦行政強制執行法第6條第2項規定，其內容為：「為阻止該當於刑法或罰鍰構成要件之違法行為，或為防止急迫之危險，而有即時執行之必要，且在行政機關法定職權範圍內者，得不先為行政處分而實施行政強制。」其重點在「得不先為行政處分」，而非「無須先有義務存在」，且此項規定係連接第1項規定之後，在規範體系上安排於「第二章：行為、容忍或不行為之強制（Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen）」，屬於以行政處分為基礎之行為、不行為義務執行之例外規定；復查萊因·柏爾茲（Rheinland-Pfalz）邦行政強制執行法第61條第2項規定，其內容為：「為阻止該當於刑法或罰鍰構成要件之違法行為，或為防止當前之危險所必要，且在行政機關法定職權範圍內者，亦得無事先作成之行政處分（ohne vorausgehenden Verwaltungsakt）而

21 我國即時強制規定之立法理由明白揭示「參照德國立法例（西德聯邦行政強制執行法第六條第二項、西德萊因·柏爾茲邦行政強制執行法第六十一條第二項）」，可證立法者並無另作與德國即時強制不同規定之意，剩下的問題只在於立法者（草案研擬者）是否誤讀或誤解德國立法例，而此正是本文之作的重點所在，也是探討行政執行法（尤其是即時強制）問題不容迴避的問題。

22 主要之例為：主管機關採取緊急強制措施所生之費用（尤其代替義務人履行義務所生之費用），除法律另有特別規定外，無法向義務人徵收。蓋行政執行法第29條所定代履行費用之追繳，以作成行政處分或以書面限定相當期間履行為前提。

採取怠金（第64條）以外之強制方法。」同樣地，此項規定亦是銜接第1項「以行政處分為基礎之行為、容忍或不行為義務執行」之後，且為第三章「命行為、容忍或不行為之行政處分之執行（Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine Handlung, Duldung oder Unterlassung gefordert wird）」的首要條文。此類條文體例及規範意旨為德國行政執行法制之通例，足以印證即時強制係一種「程序簡化」的行政執行制度，與「公法上行為、不行為或容忍義務之執行」之間為「原則——例外」之關係，而非彼此兩立、互無關連。準是以言，設若上述修法理由信實可徵，則現行規定與參照立法例間之誤差²³，顯係出於法案起草者誤讀或不解德國法制所致²⁴。再者，從行政法理及觀念邏輯以言，「義務」之有無與情況是否「危急」，乃屬兩組併立的概念，二者間並無邏輯推導或互為因果之關係²⁵。確切言之，義務之有無繫於法律之規定，屬於規

23 學說上指出此點者，例如蔡震榮，行政執行法，收於：翁岳生編，行政法（下），3版，頁254（2006年）謂：本條（按：行政執行法第36條）係參考德國聯邦行政執行法第6條第2項規定而來，但我國之即時強制性質上無須以義務為前提且於行為或不行為義務之執行外，另行規定，此與德國法上之即時強制之性質稍有不同，德國法上之即時強制是規定在行為或不行為之強制執行中，吾人若參考德國聯邦行政執行法第6條規定即可得知，該條第1項是規定一般踐行階段式之行為或不行為之強制方法，而第2項規定即屬此種即時強制。因此，德國法上之即時強制原則上仍以義務之違反為前提，但基於事件之急迫性，若以一般程序執行，將無法達到執行之目的。

24 學說上有謂：「即時強制並非實現因處分或裁定而存在之義務的手段，但本法仍仿德奧立法例一併加以規定」（參見吳庚，行政法之理論與實用，增訂10版，頁555（2007年）），其中所指之「仿德奧立法例」，至少在德國部分，即不無誤解之處。

25 或謂：「我國即時強制著重於急迫性法益危害之防止；德國法上之即時強制偏向於免經基礎處分而逕行採取的義務實現措施」，然此二者並無「實質」的差異。蓋德國法上即時強制之「偏向於免經基礎處分而逕行採取的義務實現措施」，其目的亦「著重於急迫性法益危害之防止」，否則無須特別規定免除基礎處分之作成。至於所謂「義務實現措施」，則繫於行政法上實體規範與具體個案之情節。確切言之，人民是否負有排除特定危害之行政法上義務，取決於行政實體法之規定（干預保留），與即時強制之著重於急迫性法益危害之防止（採取何種強制措施），乃屬不相衝突的兩種不同層次的問題。若執「我國即時強制著重於急迫性法益危害之防止；德國法上之即時強制偏向於免經基礎處

範圍之問題；情況是否危急，則視個案情節而定，屬於事實面之問題。於人民不負有公法上之義務，主管機關（依法）對之採取強制措施，固然多出於情況危急所必要²⁶；然行政機關採取緊急措施的對象，卻非全無法律上義務之存在，特別是造成危險之人民，其往往負有公法上之義務²⁷。在觀念上，此種依法律而負有之義務，並不會因情況危急而致義務不存在。換言之，情況危急並非義務存在與否的必然影響要素。至於「即時強制……較一般行政執行，更易影響人民權益」，似是而非。蓋行政強制是否對人民權益造成影響，端視行政機關所採取之強制方法而定，即時強制並無必然較一般行政執行更易影響人民權益之理，且與情況是否危急無關。總之，現行行政執行法的整體規範構造及細部條文，把「即時強制」與「一般行政執行」的差別建立在「義務有無」的觀念上²⁸，容有

分而逕行採取的義務實現措施」，而論斷我國與德國不同，不免流於皮毛之見。

26 在學理上稱為「緊急妨害人」(Notstandsstörer)。由於此種人民對於危險的發生並無責任，故其因強制措施所受的損害，屬於一種特別犧牲，國家應給予補償。參見李建良，論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題——兼評最高行政法院93年度判字第628號、95年度第1421號判決及其相關判決，收於：黃舒芃編，2007行政管制與行政爭訟，頁59-60（2008年）。

27 例如主管機關對於某一排放有毒氣體的工廠採取使其立即停工的強制措施，乃因該工廠依法律負有不得排放有毒氣體的義務。

28 國內學說普遍認為即時強制不以義務存在為前提，似乎是受到此一立法模式的影響。例如林錫堯，行政法要義，3版，頁227（2006年）謂：「所謂即時強制，係指行政機關為阻止犯罪、危害之發生或避免急迫危險，而有即時處置之必要時，所為之強制措施。即時強制並不以人民有違反行政法上義務為前提，此為即時強制與行政上強制執行區別之主要所在。蓋以，確保國家安全、增進國民福祉，乃行政機關固有之職責，為達成此種職責，有時必須採取即時處置，對國民之自由或財產加以限制或干涉；雖然，在民主法治社會應尊重國民之基本權，但為保護國民人權，免於遭受危害，並維持社會秩序，有時有發動強制權之必要；因此，在某些急迫情形，未能即時課人民以具體的特定義務，或縱課以具體的特定義務亦不能達成行政目的，尤應承認行政機關於必要時得即時採取強制措施，以實力加諸於人民之自由或財產，以實現行政上之必要狀態。」

上開見解有關即時強制定義部分，基本上是直接拷貝法律條文及立法理由，而未引據外國立法例或學說見解。至於後續所持理由，係以為防免人民遭受急迫危害而有即時處置必要為理據，不無本文所指將「義務有無」與「危害急迫」

未妥，允宜全面改正。本文以下的論述，係以【附圖一】所示之制度應然構造為基礎，而非現行行政執行法之實然體制，謹此指明²⁹。

參、行為、不行為或容忍義務執行之基本構造

行政救濟係提供人民免於受到公權力（主要是行政權）非法干預之程序機制，行政救濟制度必須對應公權力之運作方式與程序構造，始能契合於人民權利救濟之需求。行政強制為具干預性之公權力，行政執行之救濟體系的建構，亦無由例外。現行行政執行之救濟法制是否完備等問題之探討，須從掌握行政強制執行之法制體系與程序構造著手。行政執行之基本體系，前已述及，（公法上行為、不行為或容忍義務³⁰）行政執行之制度暨程序構造，以下論之。

混為一談之嫌，而所稱「未能即時課人民以具體的特定義務」，正是「原應以行政處分課人民以具體的特定義務，但未能即時為之」之謂，故即時強制之實施，仍以義務存在為前提，只是該義務未以（特別是書面）行政處分予以具體化而已。

²⁹ 平心而言，我國行政法學界對於即時強制制度的偏差理解（從作者的角度來看），實已到了積重難返的地步（目前似乎只有劉淑範（註18），頁600，提出與作者相同的法律見解），挑戰並顛覆此一陳年舊念，猶如蚍蜉撼樹，其困難可想而知。惟作者仍願一本學術信念，勉力略盡言責。更何況，改變現有不合理或錯誤的法制，原本就是法學研究的基調，若一味膠柱鼓瑟，不思求變，只會讓臺灣法學原地踏步，無法進展成為法治國家。

³⁰ 在義務概念及類別上，除行為、不行為義務之外，尚有所謂「容忍」義務（Duldungspflicht），指不得阻止第三人之行為的義務，尤其對於公權力之行為或措施，負有不得抗拒、規避或妨礙之義務。容忍義務與不行為義務，似同實異。蓋不行為義務之課予，在於針對特定之行為將產生（對公眾或特定人）危害而予以禁止之，該行為具有一定之危害性；反之，容忍義務之課予，其所禁止之行為係相對於特定之公權力行為，旨在讓公權力行為得以遂行；若無公權力行為之存在，即無容忍義務可言。例如警察實施檢查或沒入處分時，受檢查人或應沒入之物的所有人負有容忍之義務。又如於【思考案例】中，主管機關限期命甲拆除其未經許可擅自建築之房屋，係課予甲拆除之「行為義務」；甲如未依限拆除，而主管機關採取拆除措施時，甲負有不得妨礙拆除之「容忍義務」。此項義務不僅及房屋之所有人，尚包括房屋之承租人。關於「容忍義務」之概念，參見 *App/Wettlaufer* (Fn. 7), § 10 Rn. 5; *Michael App*,

一、制度構造

行政執行之制度構造，因「應履行義務內容」之不同，而有差異。在公法上金錢給付義務之執行，基本上係由處分機關於追繳無效之後，移由另一專責機關——行政執行分署³¹——強制執行之；反之，公法上行為、不行為或容忍義務³²之執行，係由處分機關為執行機關，親自擔負強制執行之工作。前者採處分機關與執行機關分離制，後者則為處分機關與執行機關同一制。此二類行政執行之制度構造，允宜分別論述。前已言及，本文先置重於行為、不行為或容忍義務之強制執行。

基本上，行為、不行為或容忍義務執行之制度構造，可概分為「法律基礎」、「執行名義」、「執行方法」及「執执行程序」四大部件。執行方法，可分為怠金、代履行（合稱間接強制）、直接強制三類；執执行程序，包含告戒、執行方法之確定及執行方法之實施三個階段。至於「即時強制」之方法，因其屬行為、不行為或容忍義務執行之特殊例外類型³³，即所謂「無事前行政處分之行政強制」

Verwaltungsvollstreckung im Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, WUR 1991, S. 249 (251); Paul Stelkens, Verpflichtung zur Duldung – Notwendigkeit einer Duldungsanordnung?, Natur+Recht 1983, S. 261 (261 ff.).

31 原由行政執行處負責執行，2012年1月1日配合政府機關組織再造，改制為行政執行分署，隸屬於法務部行政執行署。

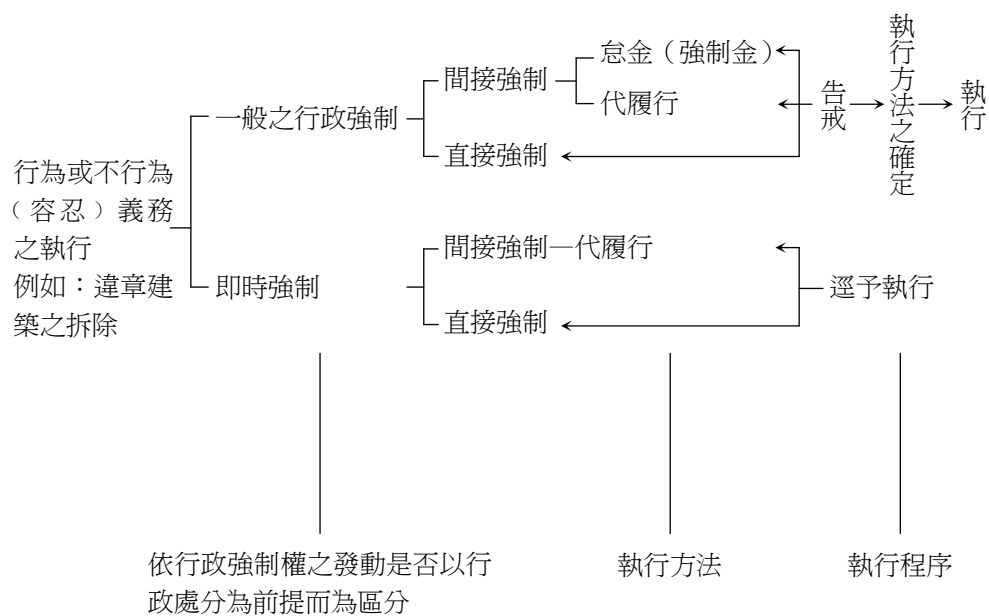
32 我國行政執行法僅規定「行為、不行為義務之強制執行」。德國聯邦及各邦行政執行法率多規定「行為、不行為或容忍義務」之執行。例如聯邦「行政執行法」(Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, VwVG)第二章之標題為「行為、容忍或不行為之強制」(Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen)，第6條第1項規定：「命物之交付、一定行為或容忍或不行為之行政處分，得依第九條所定之強制方法執行之，如該行政處分不具可爭訟性或得予立即執行，或不因行政救濟而生停止效力者。」Baden-Württemberg邦行政執行法第18條規定：「課予行為（不含金錢給付）、容忍、不行為義務之行政處分，得以強制方法執行之。」如前所述，容忍義務與不行為義務在內涵上仍有區別，故以下稱「公法上行為、不行為或容忍義務」，特此說明。

33 所謂「特殊例外類型」，係指「原應以處分課予義務、卻因急迫而無暇為之」，也就是無「處分」之存在。

（Verwaltungszwang ohne vorangehenden Verwaltungsakt）³⁴，故可運用代履行或直接強制二種方法（參見【附圖二】、【附圖三】）。

【附圖二】

行為、不行為義務執行之基本構造（一）

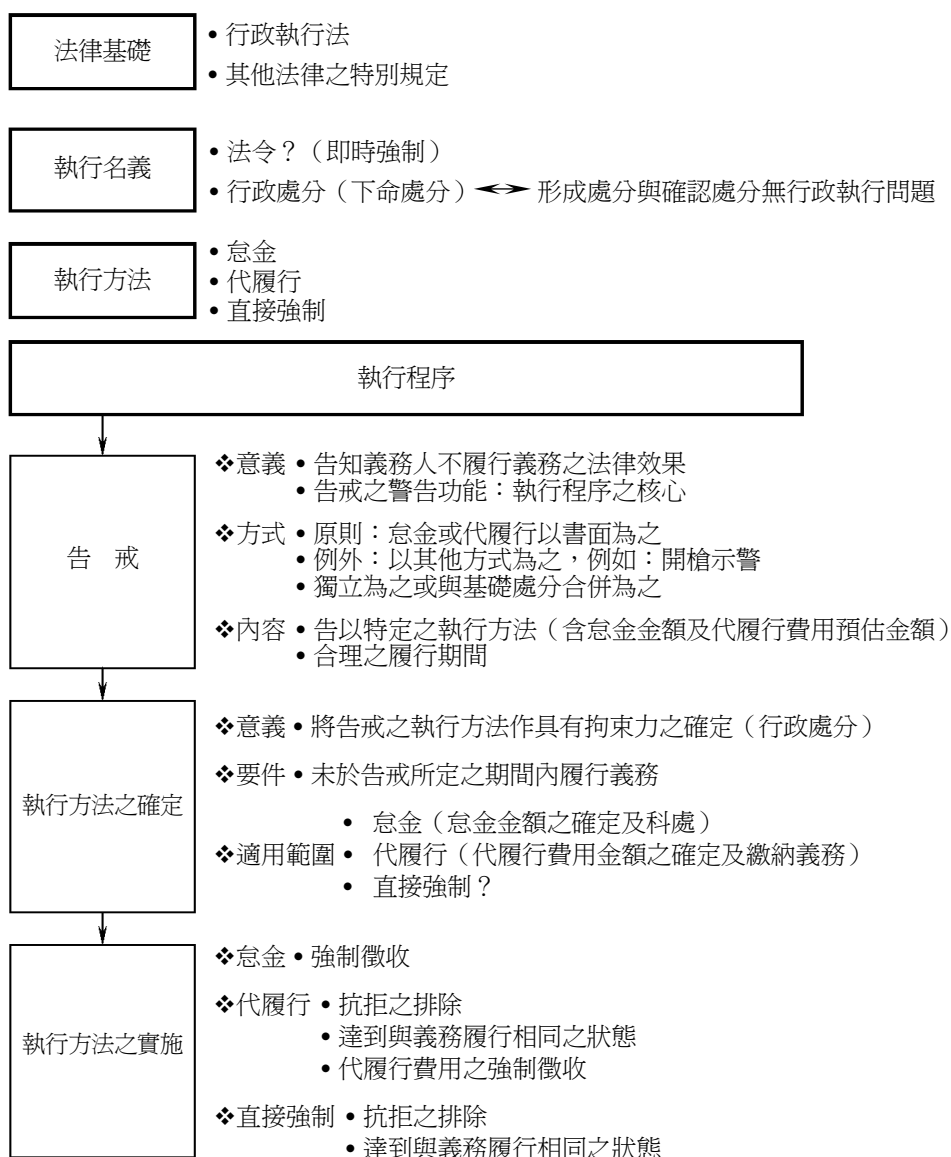


³⁴ 參見Lemke (Fn. 8), S. 180 ff.

【附圖三】

行為、不行為義務執行之基本構造（二）

行政強制執行：以強制手段貫徹行政處分所課予之行為、不行為或容忍義務



二、程序構造：「多階段」暨「多層次」之行政程序

行政強制執行，係以強制力貫徹人民所負擔之行政法上義務，具有強烈之干預色彩。在法治國家中，基於人民基本權利保護之考量，行政強制執行之程序及制度構造，必須顧及人民權利之保護。是以，法治國家之行政強制（必須）具有如下之基本特徵：一、多階段之程序構造；二、儘可能給予人民自動履行之機會；三、兼顧人民權利之保障（比例原則）與行政任務之達成。綜言之，行政強制之程序以儘可能不動用強制手段為制度設計核心，唯有在義務人惡意拒絕履行義務之情形，始動用強制手段——強制執行之最後手段性原則。

行政執行政程序，係接續於通常行政程序之後，亦即該行政程序以作成「課予義務之行政處分」（下命處分）為程序之終結。就法治國家之行政執行基本構造而言，行政處分寓有「具體化之功能及執行名義功能」，已如前述。在此意義下，行政處分應同時具有彰顯民主法治國家之人民圖像的功能，為民主法治國家的必要制度之一³⁵。蓋民主法治國家之根基，係建立在人性尊嚴之保障以及人民

³⁵ 關於行政處分之制度意義，實務上偶有狹隘過時的觀念，例如臺北高等行政法院94年度訴字第4136號判決理由謂：「……『行政處分』概念之產生，考究其歷史背景，不過是一個『讓行政作為能受司法審查』的功能性、技術性概念而已，本身並無獨立存在之學理價值，僅是人民提起行政爭訟，而受理機關與法院在進行案件合法性審查時，引為說理的過渡性橋樑而已。所以應該儘量朝合目的性方向來掌握此一概念，讓有必要進行檢證之行政作為，能儘早獲得司法審查。……」此種基於所謂「考究其歷史背景」而將行政處分貶為「技術性概念」之說法，主要受到19世紀歐陸國家（主要是德國）行政訴訟制度採「列舉主義」之影響，亦即若乏行政處分之存在，即不得提起行政救濟。實則，若準確考究歷史背景，行政處分概念暨制度之建構，非僅止於讓行政行為受司法審查之考量。依德國行政法鼻祖Otto Mayer當初引介建構行政處分的用意，即是將之比作為司法判決之機制，據以符應法治國之法安定要求，藉此嚴予確定並界分國家運作與人民自由領域的軌道與界線。Otto Mayer甚至直截了當的說，所謂的法治國，即是「行政的儘可能司法形式化」（die tunlichste Justizförmigkeit der Verwaltung）。參見Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Neudruck Bd. I, 3. Aufl., 2004 (1924), S. 62.

之主體性、自主性與自我負責的基礎上。個人雖然受到公權力之規制，惟人民並非國家機關之下屬臣民或「客體」。人民作為國家之構成主體，行使權利、承擔義務，係具有自主性、責任感之獨立人格³⁶。行政處分「制度」之設，正足以體現此一特性。透過行政處分之作成，行政機關片面地課予人民特定之義務，構成人民之不利利益；另方面則同時藉此確立具體的法律關係及公法上義務，使人民知所行止³⁷。原則上，行政機關應該期待人民會遵守法律並履行行政處分所課予之義務。非到不得已之地步，行政機關不宜輕易動用強制手段。行政執程序雖略不同於其他通常程序，貴在迅速。惟行政強制須另有法律依據之法治思維，以及行政執行法之所由制定³⁸，即在避免強制執行之過於迅速。換言之，行政執行法之中心旨趣，不貴在迅速。由此可得出之法治要諦即是：行政執行以迅速為先，行政執行法則以緩慢為貴。

循上以論，行政機關在動用強制手段之前，應給予人民有自動履行之機會，以免去遭受行政上之強制。行政執行之程序中，設有

事實上，二次戰後，德國已改採概括原則，凡屬公法上爭議，皆屬行政訴訟之範疇，行政處分早已不再是「讓行政作為能受司法審查的功能性、技術性概念」。我國行政訴訟制度於2000年亦改採概括原則，故行政處分作為一種救濟概念的觀念，不僅不符歷史原旨，且業已過時，應予修正，甚或揚棄。相關基礎文獻，另可參見Hans-Uwe Erichsen, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Aufl., 2002, § 12 I Rn. 5; Peter Krause, Rechtsformen des Verwaltungshandelns, 1974, S. 179; Joachim Martens, Zur Begriffsbestimmung des Verwaltungsaktes, DVBl. 1968, S. 322 (323 ff.); Fritz Ossenbühl, Die Handlungsformen der Verwaltung, JuS 1979, S. 681 (683).

³⁶ 參照BVerfGE 44, 125 (142).

³⁷ 此亦所以行政機關作成不利於人民之處分前，必須給予人民陳述意見之機會（行政程序法第102條），於作成行政處分時，須附記理由（行政程序法第96條第1項第2款）之原因所在。正當法律程序與行政決定的可接受度之間，具有互為因果之關係。參見Eberhard Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl., 2006, S. 102 ff.

³⁸ 在此值得反思的問題是：何以要有行政執行法？行政執行的要件是否不同於基礎處分之要件？行政執行的程序是否不同於基礎處分之程序？行政處分具有執行力，是否意味行政強制屬於行政處分內涵的一部分？

「告戒」³⁹與「強制方法之確定」之階段，即是用以符應前開之意旨。此等行政執行之「前置程序」，旨在形成一種心理上之強制，期以人民自動履行義務，省卻強制措施之運用，於國於民，皆有其利。從法治國原則之角度出發，此不僅出於「權力節度」(Machtökonomie)之考量，尚且是「國家權力適度性」原則之體現，即所謂過度禁止之比例原則⁴⁰。行政執行程序設計之基本哲學，乃「心理上之強制」先於「物理上之強制」⁴¹，先禮後兵，以收「不戰而屈人之兵」的效應。

行政處分若要以強制方法貫徹之，首先在第一階段，須先以書面為告戒(關於強制方法)(schriftliche Androhung des Zwangsmittels)。在此階段，應設定義務履行之期間，亦即可期待義務人自動履行義務之期間⁴²。告戒得與基礎處分相結合。告戒之

39 「告戒」一詞，係德文„Androhung“的修譯，於德國既是學理概念，亦是法制用語(參見德國聯邦行政執行法第13條)。我國(舊)行政執行法第2條第2項規定：「前項處分(按：間接強制處分)，非以書面限定期間預為告戒，不得行之；但代執行認為有緊急情形者，不在此限。」可見「告戒」一詞之法制用語。然1998年11月11日修正公布之現行法，已刪除「告戒」之用語，僅於第27條規定：「依法令或本於法令之行政處分，負有行為或不行為義務，經於處分書或另以書面限定相當期間履行，逾期仍不履行者，由執行機關依間接強制或直接強制方法執行之。前項文書，應載明不依限履行時將予強制執行之意旨。」故「告戒」一詞目前只是學理概念，而非法制用語，於告戒制度之適法運用及正當程序功能的彰顯，頗多妨礙，允宜修正之。

40 參見Pietzner (Fn. 9), S. 261. 行政執行法第3條規定：「行政執行，應依公平合理之原則，兼顧公共利益與人民權益之維護，以適當之方法為之，不得逾達成執行目的之必要限度。」其旨亦同。

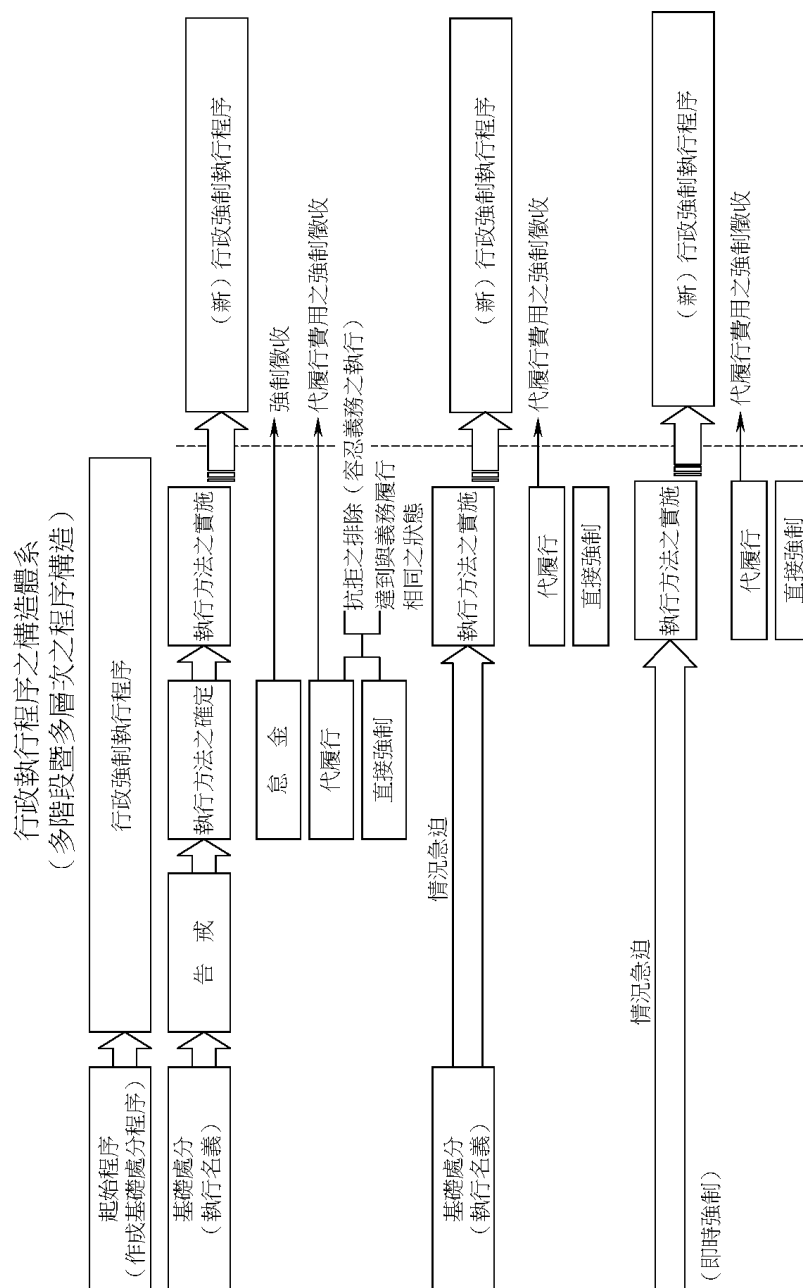
41 無怪乎，此種程序上之設計，在歐陸直至19世紀中葉始見發展。蓋在專制國家中，人民為國家之下屬臣民，人民履行義務為當然之事，自不可能以如此緩和之方式，實施強制執行。關於行政執行法制之淵源，參見Ottweiler Buch, Das nichtkodifizierte Verwaltungszwangsrecht in Preußen. Das nichtkodifizierte Verwaltungszwangsrecht in Preußen. Ein Beitrag zur Lehre von den gewaltrechtlichen Verwaltungsakten und ihrer Verwirklichung, AöR 31 (1913), S. 326 (364 ff.).

42 惟所課予之義務係容忍或不作為義務，依事物之本質，應無所謂「履行期間」之問題，故在告戒中，亦無從設定履行期間。參照德國Baden-Württemberg邦行政執行法第20條第1項後段規定。

內容，須指出特定之執行方法。執行機關若欲採取代履行措施，尚須於告戒中預估代履行費用；若欲採取怠金，則應預知其金額。告戒應送達於義務人，尤其告戒與基礎處分一併為之，而該基礎處分毋須送達於相對人（義務人）即生效力之情形，仍須另以書面將告戒送達於義務人，始生告戒之效力。例如一般處分僅須公告即生效力（行政程序法第110條第2項），設若該一般處分課予不特定或可得特定之人民一定之義務，同時於公告上載明若於一定之期間內不履行義務者，即行強制執行者，除有急迫之情形外（即時強制），該告戒仍須個別送達於相對人，始得對之實施強制手段。

行政執行程序之開啟，「告戒」居於樞要地位，隨之程序依次為「執行方法之確定」與「執行方法之實施」，從程序構造而以觀，屬於一種「多階段之行政程序」，俾以確保法之安定性，減緩行政強制之進行，以維民權。在各階段中，復有產生新的行政處分（基礎處分）者，例如怠金之科處或代履行費用之核課，其亦有強制執行之問題，從而又派生出新的行政執行程序，可謂之為「多層次之行政程序」（參見【附圖四】）。

【附圖四】



肆、行政執行之救濟問題與體系建構

明悉行政執行具有「多階段」與「多層次」之程序構造特徵，即可知行政執执行程序之開始與進行，乃是一種或多種「基礎處分（執行名義）與行政執行（執行行為）」承接續進的關係，其間無可避免地會有一定程度的彼此連動或相互影響。尤以在我國現行行政爭訟制度採取「不停止執行原則」之法規範架構下，更使兩者間之關聯性趨於緊密。是以，在探討各別執行措施之救濟問題時，必先滌清「基礎處分」（執行名義）與「執行行為」之間的區隔與連動關係，以免因嚴格界分兩者而產生權利救濟體系之割裂與法學論理之瑕疵。

一、基礎處分與行政執行之區隔性與救濟問題

從行政執行之程序構造可知，基礎處分之程序與行政執执行程序之程序，分屬不同階段，由此可以推得行政執行法上之一項重要基本原則，即：基礎處分之瑕疵，除有無效之情形外，於行政執执行程序中，不予過問。換言之，行政執行之合法性，並非繫於基礎處分之合法性，而是決乎基礎處分之「有效性」（*Wirksamkeit*）與「可執行性」（*Vollstreckbarkeit*）⁴³。所謂「基礎處分之有效性」，指行政處分無無效之事由，且未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效之情形（參照行政程序法第110條第3項）。所謂「基礎處分之可執行性」，指無阻礙執行之法律上事由存在，依照德國聯邦行政執行法第6條第1項規定，可執行性，指基礎處分具不可爭性（*unanfechtbar*），亦即具形式確定力（例如逾越訴願期間），或基礎處分附有立即執行之命令，或對於基礎處分之救濟不具停止執行之效力。我國行政執行法並無行政處分須確定始得強制執行之明文，

43 *Pietzner* (Fn. 9), S. 268; *Wolfgang Weiß*, Gibt es einen Rechtswidrigkeitszusammenhang in der Verwaltungsvollstreckung?, DÖV 2001, S. 275 (275 ff.).

加上我國關於行政處分之暫時權利保護制度，係採「原則不停止、例外停止」之設計⁴⁴，故所謂「基礎處分之可執行性」，僅指基礎處分未經訴願機關或行政法院為停止執行之決定或裁定。

循上，由於課予行為、不行為或容忍義務之基礎處分，性質上屬侵益處分，處分相對人（義務人）如有不服，自得（於行政執行程序之外）依法循序提起訴願及撤銷訴訟，以資救濟。處分機關與執行機關若非同一，執行機關不得以基礎處分違法為由，拒絕執行⁴⁵。蓋應予執行之行政處分一旦生效，即對其他機關產生拘束力。基礎處分若已具形式之存續力（不可爭訟性），除有回復原狀之情事，義務人僅能依行政程序法第128條，透過請求行政程序重開之方式，阻止執行之進行。就【思考案例】來說，甲對於主管機關限期命其拆除之行政處分，如有不服，應於收到處分書之日起，於法定期限內循序提起訴願及撤銷訴訟，以資救濟。甲若未於法定救濟期間內提起行政爭訟，則於進入行政執行程序後，即不得再爭執拆除處分之違法性。至於主管機關「嗣後」廢止該禁建區劃定之情事，則屬甲能否及如何依行政程序法第128條請求行政程序重開之問題（詳見後述）。基礎處分確定後，若允許義務人仍得於執行階段爭執基礎處分之合法性⁴⁶，並以之指摘執行行為的合法性，則將行政執行程序之救濟與基礎處分實體合法性之問題混為一談，且勢將使訴願法有關訴願期間之規定，形同具文。實則，關於基礎處分之合法性，屬各該專業性法律之實體問題；反之，基礎處分「能否」強制執行，應取決於行政執行法之規定。是以，基礎處分若該

⁴⁴ 參照訴願法第93條、行政訴訟法第116條。

⁴⁵ 此亦為德國實務與學說的多數見解。參見BVerwG, NJW 1984, 42; BayVG, BayVBl. 1989, 630 (631); Michael App, Die Verwaltungsvollstreckung im Baurecht, JA 1991, S. 351 (353); Engelhardt/App (Fn. 14), § 18 Anm. II 2b; Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Aufl., 2009, § 20 Rn. 12.

⁴⁶ 也就是說，人民即使已遲誤訴願期間，或不提起訴願，於基礎處分具有形式確定力後，仍得於執行期間爭執基礎處分之合法性。

當於執行行為之合法條件，即基礎處分（執行名義）之「有效性」與「可執行性」，而非基礎處分（執行名義）之「合法性」（*Rechtmäßigkeit*）。準此以論，除有即時強制之情形，告戒以基礎處分的有效存在為前提，因之，可稱得上是一種「依附性之行政處分」（*abhängiger Verwaltungsakt*）⁴⁷。基礎處分若經撤銷，則告戒亦失所附麗。若從救濟程序之角度以觀，針對基礎處分之救濟程序與針對告戒之救濟程序，乃呈現一種「階次爭訟」（*Stufenstreitigkeiten*）之關係。從而，除告戒本身具有違法原因外，若要以基礎處分不存在為由而撤銷告戒處分，則須俟撤銷基礎處分之形成判決發生確定力時，始得為之。基於程序經濟及權利保護有效性之考量，此二階次之救濟程序，得予合併於同一訴訟程序中為之，形成一種客觀之訴之合併（*objektive Klagehäufung*）⁴⁸。至於強制方法之告戒本身是否存獨立之違法事由而得予撤銷⁴⁹，以及基礎處分如履行或執行完畢者，是否及如何以該「基礎處分」為程序標的進行救濟之問題，則屬另一衍生性及關聯性問題，容待後述（見「肆、四（一）」、「肆、六（一）」）。

二、基礎處分與行政執行之關聯性與救濟問題

依前所述，基礎處分若有效存在，縱使有違法之情形，除非循救濟途徑予以撤銷或處分機關依職權撤銷外，原則上不影響行政執行之進行。此項原則是否允許有例外情形之存在，從而給予人民對

47 *Hans Julius Wolff/Otto Bachof*, *Verwaltungsrecht*, Bd. I, 9. Aufl., 1974, § 47 IVa, S. 393 (393); *Hartmut Söhn*, *Steuerrechtliche Folgenbeseitigung durch Erstattung: zugleich ein Beitrag zum Steuerschuldverhältnis*, 1973, S. 187 ff; *Raimund Brihl*, *Die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungszwangs im gestreckten Verfahren*, *JuS* 1997, S. 926 (926).

48 行政訴訟法第196條第1項（相當於德國行政法院法第113條第1項第2句及第3項）設有類此規定，可資參照。

49 德國聯邦行政執行法第18條第1項第3句規定：「告戒如未與基礎處分相結合，而該基礎處分已具不可撤銷性者，該告戒僅於其本身構成權利侵害之主張範圍內，得予撤銷之。」可資參照。

之有救濟之機會，容待探討。以下試從「基礎處分所依據之事實或法律事後變更」與「基礎處分之義務履行完畢」二端析論之。

（一）基礎處分所依據之事實或法律事後變更與行政執行之關聯

基礎處分作成後或確定後，發生事實或法律之變更者（如【思考案例】之情形），所在多有，遇此情形，原本有效、合法之基礎處分是否因而變成違法？該基礎處分是否仍得作為執行名義，開始或繼續執行？值得探討。此等問題因牽涉撤銷訴訟之違法判斷基準時、行政程序重開、行政執行終止等行政訴訟、行政實體與行政執行法上之諸般問題，有待剖析廓清之⁵⁰。基本的思考方向及酌量因素，除行政執行法之基本原理外，尚須著眼於程序之經濟性及人民權利之有效救濟，進行交錯思考。質言之，基礎處分作成後或確定後，發生事實或法律變更之情事，其所引動的問題首先是基礎處分的合法性是否為之動搖？此一問題的索解非可單獨為之，而須對應考量到行政執行的問題，也就是有無執行的必要？此一問題又牽及行政執行的制度目的詮釋課題，由此乃帶出執行政程序應否終止的問題。從人民權利有效救濟的角度出發，此二基本問題（基礎處分的合法性與行政執行的必要性）則同時涉乎兩個不同但互有交集的問

50 「行政爭訟之違法判斷基準時」與「行政程序重開」為行政法上兩項頗為重要且棘手的課題，理論上可各自獨立作為單篇論文的主題。不過，本文就此二問題的探討，係著眼於「基礎處分所依據之法律或事實事後變更與行政執行之關聯」此一命題設定。換言之，本文的重點在於探討基礎處分作成後事實或法律變更對行政執行之救濟問題所生之影響（精確的說：行政執行程序中事實或法律變動的權利救濟問題），至於「行政爭訟之違法判斷基準時」或「行政程序重開」只是思考本文核心關切課題的切入點與問題意識。國內雖不乏關於「行政爭訟之違法判斷基準時」與「行政程序重開」的相關研究及文獻，惟迄今為止似尚無將探討視角置於「基礎處分所依據之法律或事實事後變更與行政執行之關聯」的問題上，此一研究空缺亟待填補。也因此，作者無意亦無必要就此二議題進行全盤性的探討，而是嘗試從行政執行的角度，找出此二議題之間的關聯，並據以建構出行政執行上全面且完整的救濟體系。作者特此聲明，以免不識者誤會。

題：一是進入行政爭訟程序中，事實或法律變更此一因素是否及如何影響基礎處分的合法性判斷（基礎處分之違法判斷基準時）⁵¹？此一問題同樣不能隔離思考，而須考量基礎處分作為執行名義及其可能產生執行後果的問題。另一是能否以事實或法律發生變更為由申請行政程序重開，請求撤銷、廢止或變更基礎處分（行政程序重開）⁵²？此固然與行政爭訟分屬不同層面之問題，但卻又有兩個相

51 相關文獻，參見賴恆盈，論行政訴訟之裁判基準時，政大法學評論，121期，頁223-312（2011年）；陳清秀，情事變更與課稅處分之違法判斷基準時／最高行89判1265，台灣法學雜誌，179期，頁169-175（2011年）；陳愛娥，撤銷訴訟中判斷行政處分合法性之基準時與行政法院對行政函釋的審查權——評臺北高等行政法院九十八年度簡字第五二九號判決，月旦裁判時報，1期，頁25-30（2010年）；彭鳳至主持，陳清秀報告，行政訴訟上事實及法律狀態之裁判基準時，行政訴訟法研究會第十二次研討會，台灣法學雜誌，125期，頁38-91（2009年）；陳淑芳，撤銷訴訟之裁判基準時點，台灣本土法學雜誌，90期，頁54-78（2007年）；林三欽，論行政訴訟之判斷基準時——兼評最高行政法院94年度判字第588號判決，收於：湯德宗、劉淑範編，2005行政管制與行政爭訟，頁41-73（2006年）（以下簡稱：林三欽，行政爭訟）；許登科，論撤銷訴訟中行政處分之違法判斷基準時，法學叢刊，48卷2期，頁61-75（2003年）；林三欽，訴願案件之違法判斷基準時，台灣本土法學雜誌，23期，頁1-16（2001年）；李建良，論行政處分之違法判斷基準時——以訴願程序為中心，收於：台灣行政法學會編，行政法爭議問題研究（下），頁907-934（2000年）（以下簡稱：李建良，問題研究（下））；李建良，訴願程序之違法判斷基準時，月旦法學雜誌，64期，頁22-23（2000年）。

52 相關文獻，參見程明修，行政程序法上有關行政處分撤銷與程序重新進行之規範改正，法學叢刊，57卷3期，頁67-109（2012年）；劉建宏，稅捐行政程序重開之探討，當代財政，14期，頁28-37（2012年）；劉建宏，既判力與行政程序重開及違法行政處分之撤銷，台灣法學雜誌，187期，頁46-64（2011年）；詹鎮榮，行政程序重新進行之程序標的——以我國及德國行政法院相關裁判為中心，東吳公法論叢，4期，頁211-261（2011年）；詹鎮榮，行政程序重新進行之程序標的——我國與德國法制之比較，東吳法律學報，23卷1期，頁95-133（2011年）；黃俊杰，行政法實務講座：第四講——程序重新，月旦法學教室，95期，頁26-34（2010年）；吳志光，行政程序重新進行之要件，台灣法學雜誌，150期，頁69-73（2010年）；林樹埔，行政程序法第128條程序重開之理論與實務，法令月刊，61卷2期，頁76-86（2010年）；洪家殷，有持續效力之行政處分與行政處分程序之重新進行，台灣法學雜誌，125期，頁143-148（2009年）；程明修，是否重開行政程序之決定均為行政處分／最高行九七裁五四〇六，台灣法學雜誌，125期，頁209-210（2009年）；傅玲靜，論行政程序之重新進行——以遺產稅之核課與剩餘財產差額分配請求權價額之扣除為例，月旦法學雜誌，147期，頁101-120（2007年）；林素鳳，程序重新、訴願再審與再審之

互連動的待解課題：其一，人民得否對基礎處分同時提起撤銷訴訟與申請程序重開？此一問題表面上應採否定見解，但由於人民係以基礎處分作成後變更之事實或法律作為主張基礎處分違法之依據，因此於撤銷訴訟中，基礎處分之違法判斷基準時對於人民能否同時申請行政程序重開，即具有決定性的作用。蓋行政法院若以基礎處分作成時之事實或法律作為違法判斷基準，則實無不允許人民以基礎處分作成後變更之事實或法律申請程序重開之理（「基礎處分之違法判斷基準時」對「行政程序重開之適用範圍」的互動關聯）；其二，人民如得以基礎處分作成後變更之事實或法律申請程序重開，並據以請求變更、撤銷或廢止基礎處分，則從程序經濟的觀點而言，行政法院是否應以基礎處分作成後變更之事實或法律為據，逕予撤銷基礎處分，而不是由人民申請行政程序重開，於遭拒後再循序提起行政爭訟？以上問題環環相扣，茲先以【思考案例】為例，鋪陳各種情況及問題脈絡，再逐次解析之。

於【思考案例】中，甲之所以未獲建造執照，而私自建築房屋，乃因其所有土地位於禁建區。嗣主管機關廢止該禁建區之劃定，設若甲所建房屋並未違反建築法相關規定，則該拆除處分（基礎處分）是否仍有執行之必要？甲應如何救濟？不無疑問。就如何尋求行政救濟的角度而言，因法律或事實變動之發生時點，而有不同。

基礎處分作成後，事實或法律之變更，若發生在訴願期間、起

訴——兼評台北市政府九十一年十月十六日府復字第○九一一九○二七五○一號復審決定，月旦法學雜誌，118期，頁199-213（2005年）；許登科，論訴願再審之程序標的及訴願再審決定之救濟——以評釋行政院台九十訴字第○四五一二一號決定為中心，月旦法學雜誌，92期，頁110-128（2003年）；林明昕，論訴願之再審與行政處分之廢棄——一道介乎行政爭訟法與行政程序法之間的法學課題，收於：公法學的開拓線——理論、實務與體系之建構，頁289-317（2003年）；洪家殷，論行政處分程序之再度進行——以德國一九七六年行政程序法第五十一條之規定為中心，政大法學評論，45期，頁305-350（1992年）。

訴期間或上訴期間，或於訴願程序、訴訟審理程序或上訴審理程序者（即【附圖五】所示之T1、T3、T4、T6、T7、T9時點），由於基礎處分尚處於得撤銷之狀態，故義務人或利害關係人得以基礎處分（拆除處分）為程序標的，循序提起訴願及撤銷訴訟，以除去該處分之效力。茲有問題者，乃基礎處分作成後所發生之事實或法律變更，於訴願及撤銷訴訟審理程序中，得否作為判斷系爭基礎處分違法之考量因素？於此涉及行政處分違法判斷基準時之爭議。設若訴願機關或行政法院以「行政處分作成時」作為行政處分之違法判斷基準時點，則行政處分作成後所發生之事實或法律變更，自無法成為撤銷基礎處分之理由。

→問題一：訴願或撤銷訴訟之違法判斷基準時，應以行政處分作成時，抑或訴願決定或行政訴訟言詞辯論終結前？基礎處分作成後所發生之事實或法律變更，得否作為停止執行之考量因素？

相對於直接訴請撤銷基礎處分，另一種救濟的可能性，是循行政程序重開之途徑。惟查行政程序法第128條第1項所定申請行政程序重開，係以「行政處分於法定救濟期間經過後」為要件，亦即須系爭行政處分業已生形式確定力，始得為之。若嚴格依此規定之要件，則義務人無法針對未確定之行政處分申請程序重開，又如上所述，行政法院若以「行政處分作成時」作為違法判斷基準時點，而不考量行政處分作成後所發生之事實或法律變更，則義務人於尋求救濟時，勢必陷入「進退維谷」的窘境。

→問題二：行政程序重開是否應以「行政處分於法定救濟期間經過後」（行政處分確定）為要件？

事實或法律之變更，若發生於在訴願期間、起訴期間或上訴期間經過後、但義務人未提出救濟，或經行政訴訟審理判決確定而維持原處分之後（即【附圖五】所示之T2、T5、T8、T10時點），基礎處分雖發生不可爭訟之確定力，但義務人得依據行政程序重開之規

定（行政程序法第128條第1項第1款），以行政處分所依據之事實或法律事後發生有利於其之變更，請求行政機關廢止該拆除處分（基礎處分），行政機關若拒絕重新開啟程序，或行政機關雖重新開啟行政程序，並重新審究該行政處分，但仍維持原處分，則該義務人尚得提起行政爭訟，謀求救濟⁵³。然則，刻正進行之執行強制程序，並不因義務人對行政機關有關程序重開之決定提起爭訟而受影響，尤其行政機關若拒絕重新開啟程序，義務人無從對已確定之基礎處分聲請停止執行⁵⁴，從而縱令日後獲撤銷或廢止基礎處分之結果，恐已因執行完畢而生難以回復之損害⁵⁵。

→問題三：基礎處分所依據之事實或法律事後變更，得否作為「終止」行政執行之事由？

從上述程序重開、行政爭訟與行政執行之關係（參見【附圖五】）的分析顯示，基礎處分與行政執行雖分屬不同程序階段，然於基礎處分所依據之事實或法律發生事後變更之情形，往往引動是否開始執行或繼續執行之問題，從而帶出上述如何完善保護人民權益的三大法律課題，以下依序探討之⁵⁶。

53 義務人得提起課予義務訴願（訴訟），請求行政法院判令行政機關為程序重開之處分。

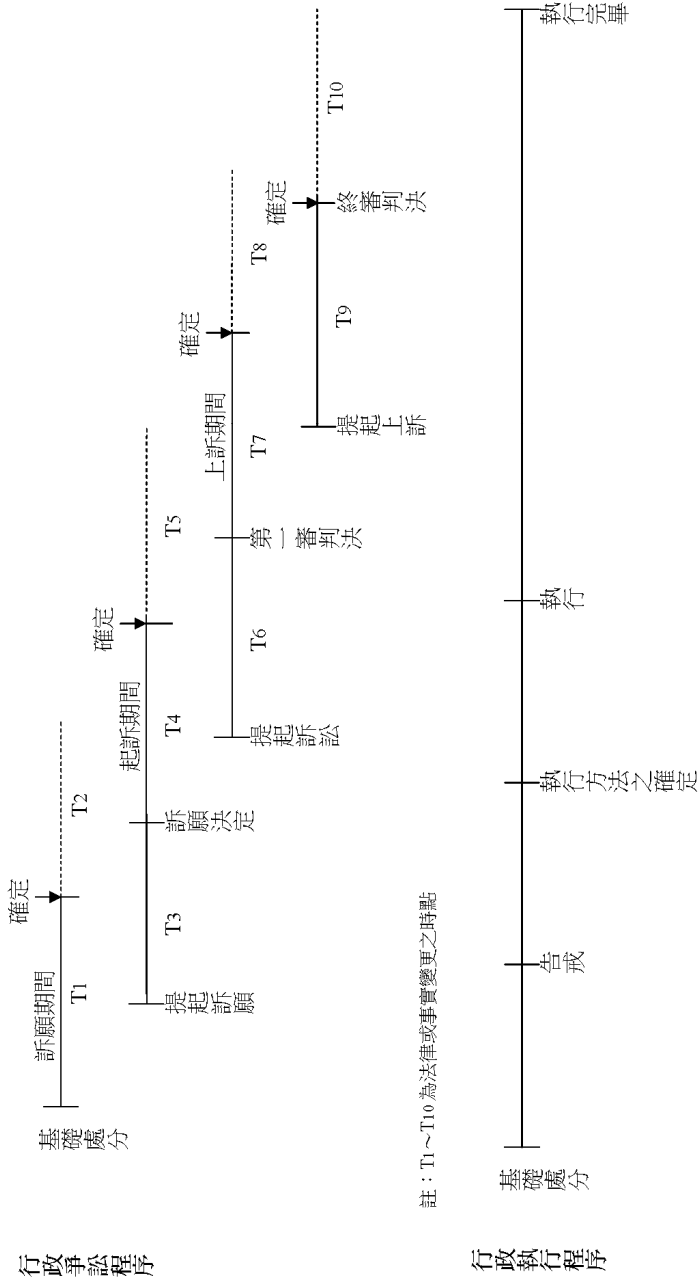
54 訴願法第93條與行政訴訟法第116條規定之適用，以行政處分「未確定」為前提，此處係涉及針對「已確定之基礎處分」的程序重開問題，故無訴願法第93條與行政訴訟法第116條規定之適用餘地。

55 另請參照德國實務見解BVerwGE 6, 320 ff.

56 本文旨在指出「行政爭訟之違法判斷基準時」、「行政程序重開之適用範圍」及「行政執行程序之終止」等看似「獨立、無關」的議題（國內文獻至今為止的研究狀態），其間實則存有頗為複雜且密切互動的糾葛關係，故以下以較為精簡的方式，歸納整理出作者思考的理路與整體問題的脈絡，以便讓國內學界與實務知曉問題之所在，並提供進一步討論的基礎，特此指明。

【附圖五】

程序重開、行政爭訟與行政執行之關係



1. 基礎處分作成後發生之事實或法律變更得否據以作為判斷該處分之違法性？

作成基礎處分之前提（事實或法律）要件業已不存在者，即作成處分之「目的喪失」（Zweckfortfall），從行政爭訟之角度而言，首先要解決的是基礎處分違法判斷基準時的問題。

現行法制針對除去（違法但有效）行政處分效力所提供的救濟管道為訴願及撤銷訴訟，而且訴願先行，撤銷訴訟在後，故於救濟程序中，基礎處分之違法判斷基準時問題，可區分為「訴願之違法判斷基準時」與「行政（撤銷）訴訟之違法判斷基準時」。訴願程序具有行政程序之性質，且訴願決定亦屬一種行政處分，故訴願機關於判斷系爭處分時，應以「訴願決定時」之法律及事實狀態為準。蓋訴願機關於訴願程序中作成訴願決定，一如行政機關於行政程序中作成行政處分，而依法治國家之一般基本原則，行政機關於行政程序中，對於尚未作終局決定之案件，應隨時注意法律及事實之狀態，俾使行政決定合乎決定時之法律及事實狀態。此一原則不僅適用於一般之行政機關，尚且及於具有行政機關性質之訴願機關。因此，訴願機關於審究原處分是否合法時，不能僅侷限於作成行政處分時之法律及事實狀態，而應注意其後法律及事實之變化，並審酌該處分於訴願決定之時，是否合於當時之法律或事實狀態⁵⁷。準此以言，基礎處分作成後事實或法律有變動，且利於義務人者，訴願機關應斟酌新事實或適用新法規，並注意訴願法第81條第1項「不利益變更禁止」規定⁵⁸。

⁵⁷ 參見李建良（註51），問題研究（下），頁907-934。

⁵⁸ 基礎處分作成後事實或法律有變動，縱使有利於義務人，因訴願機關可斟酌新事實或適用新法規重為處分，故理論上訴願機關得作成全新的處分，且可能為較之原基礎處分更不利的處分。不過，由於我國訴願法第81條第1項已有「不利益變更禁止」之規定，故儘管訴願機關得為全新的行政處分，仍不得抵觸訴願法第81條第1項「不利益變更禁止」之規定。

較為棘手者，乃行政訴訟之違法判斷基準時問題，尤其涉及法規變更之情形，於此應分以下層次探討：

1) 探求變更後之法規（新法）的「時之效力」

首先，基礎處分作成後，其所依據之法規事後發生有利於義務人之變更者，應先究明變更後之法規（新法）是否具有溯及之效力，若然，則行政法院自應適用新法，作為判斷系爭基礎處分之準據（以新法為準據法）⁵⁹。法規（新法）是否具有溯及之效力，基本上可分為二種情形：一是立法者明示新法之效力向前發生（真正之溯及）；另一是立法者未有明示，但舊法所適用之事實於新法持續存在，得為新法適用之對象（不真正溯及）。此處所指行政法院應適用新法，係指前者（真正之溯及）而言，亦即行政法院「依立法者之指示」而「必須」適用新法。至於後者之情形，基本上屬於法律解釋適用層次之問題，嚴格的說，並非法規本身的效力溯及，而是法規的「溯及適用」⁶⁰，仍須進入行政處分違法判斷基準時的問題脈絡中探討，以下續論之。

2) 撤銷訴訟違法判斷基準時點之原則與例外

撤銷訴訟之程序標的（行政處分）的違法判斷，通說係以「處分時」為基準時，而非「裁判時」，基本上是建立在兩項出發點之上：其一，在制度上，行政訴訟旨在對行政行為作事後的合法控制，故行政法院所應審查者，乃行政機關作成處分時是否合於當時之法律及事實狀態。其二，在觀念上，合法作成之行政處分，不會因事後的法律或事實變更而（當然）構成違法。換言之，事後發生

⁵⁹ 關於德國學說及實務見解，參見BVerwGE 50, 2 (7 f.); 51, 15 (24); 59, 148 (160); 64, 218 (222); 66, 178 (184); Jörg Schmidt, in: Erich Eyermann/Ludwig Fröhler (begr.), Verwaltungsgerichtsordnung: Kommentar, 13. Aufl., 2010, § 113 Rn. 45 ff.

⁶⁰ 相關概念之爭議，參見彭鳳至，論法律不溯既往原則之適用與誤用——以七十四年增訂、九十一年修正民法第一〇三〇條之一第一項之適用為例，月旦法學雜誌，104期，頁68-92（2004年）。

的事實或法律變動原則上不會影響行政處分的合法性⁶¹，故應以行政處分作成時之事實及法律狀態決定其是否合法。此項立論可從行政程序法有關行政處分撤銷及廢止的規範體系獲得支持。一則，行政程序法第117條以下有關行政處分撤銷及廢止規定的適用，係建立在行政處分「違法」（撤銷）與「合法」（廢止）區分的基礎上，且以「處分作成時」作為違法判斷的基準。設若處分作成後之事實或法律狀態得以作為判斷行政處分之因素，將使行政處分之違法判斷問題呈現浮動現象，進而紊亂行政程序法第117條以下的規範體系，以致難於適用。二則，行政程序法第122條前段規定：「非授予利益之合法行政處分，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止。」據此，對於不利處分是否廢止，原處分機關享有裁量權。設若行政法院得依裁判時之法律（處分作成後之法律）撤銷該處分，無異表示原處分機關有廢止該處分之義務，從而將使上述行政程序法之規範意旨失去意義。

以上立論，固非無見，然能否毫無保留地一體適用於所有類型之行政處分上，尤其從行政執行的角度反向思考，容有斟酌的餘地。首先，關於具有處罰性質之行政處分，例如罰鍰或吊扣執照，於「裁罰後」發生法規變動之情形，例如罰金罰鍰提高標準條例於2009年4月29日公布廢止；又如吊扣執照之法定要件廢止，則在此之前依該條例作成之罰鍰處分或吊扣執照（基礎處分），是否應予變更？該等基礎處分於進入行政執行程序後是否仍有繼續執行的必要，或應否終止？此一問題可先從行政罰法第5條「從新從輕」出發，探求其規範意旨與適用對象。揆諸行政罰法之所由制定，旨在建立行政機關裁處行政罰之共通適用的法律依據⁶²，循此行政罰法

61 參見Maurer (Fn. 45), § 10 Rn. 3. 國內文獻，參見林三欽，行政爭訟（註51），頁41-73；彭鳳至主持，陳清秀報告（註51），頁38-91。

62 參見行政罰法立法總說明：「……由行政機關裁處之行政罰，其處罰名稱、種類不一，裁處程序及標準互異，且因缺乏共通適用之法律，致得否類推適用刑法總則或其他刑事處罰法律規定，或引用其等之法理，理論不一，見解分歧。」

第5條⁶³應係以「裁罰機關」為規範對象，立法者明文指示裁罰機關關於「裁罰時」必須選用最有利於行為人的法律，屬於裁罰機關「準據法選用」的規定。裁罰機關若違反行政罰法第5條從新從輕原則，行政救濟（訴願及訴訟）機關即應於行政爭訟程序中予以糾正。嚴格而言，此一規定並非用以規範「行政救濟」程序中所生行政處分「違法判斷基準時」的問題⁶⁴。換言之，裁罰機關「裁罰後」所生的法規變動問題，即已脫離行政罰法第5條的規範射程範疇，而涉入「行政程序是否重開」、「裁罰機關應否廢止」、乃至於進入行政爭訟程序中之「違法判斷機關時」等問題範疇，與裁罰機關的選法問題不同，應分別予以處理。

惟查行政罰法第5條從新從輕原則的立法精神在於，行政處罰不涉及行政法律關係是否確定的法安定性問題，而是對於特定之違規行為進行事後法律上之究責。是以，當立法者對於特定行為之「是否究責」及「如何究責」嗣後有所改變時（例如不再究責或減輕究責），對該行為實無理由執故強予處罰，甚而執行到底，故

目前實務上雖賴司法院解釋、行政法院判例或判決及行政解釋作為依循，惟常因時空變遷或具體個案之考量，亦屢生爭議。因之，行政罰之裁處如無共通適用之統一性、綜合性法律可資遵循，不但嚴重影響行政效能，斷傷政府威信，更有失公平正義，難以保障人民權益，故制定共通適用之行政罰法，以健全行政法體系，誠有迫切需要。」

63 內容：「行為後法律或自治條例有變更者，適用行政機關最初裁處時之法律或自治條例。但裁處前之法律或自治條例有利於受處罰者，適用最有利於受處罰者之規定。」

64 在觀念上，「法規變動所生行政處罰之法適用」與「行政處罰（罰鍰處分）的違法判斷」，乃屬不同層次的問題，應加區辨。按法規變動所生法適用上之問題，乃是一種「不同時點複數法規」間的選用問題，涉及如何判斷法適用的「基準時」，確切的說，乃是一種時間觀點的「準據法選定」。因此，行政處罰的「法規選用」（準據法選定）問題探討，在概念上即必須區辨「處罰機關的判斷基準時」與「救濟機關的判斷基準時」兩種類型。後者為此處所探討之「違法判斷基準時」，亦即訴願機關或行政法院基於救濟機關的地位，針對行政機關先前所作的裁罰處分進行「事後的違法判斷」；相對而言，處罰機關就特定違反行政法上義務之行為，於「裁處時」遇有「行為前後」法規變動之情形，必須在「新法」或「舊法」的適用上作出選擇。是以，裁處機關於裁處時並無所謂行政處分的「違法」判斷，而只有「正確選法」的問題。

「從新從輕」允應同時成為行政救濟的審理原則。此一立論尚且可以從行政罰法第5條立法理由「參考刑法第二條第一項、社會秩序維護法第三條、德國違反秩序罰法第四條第二項至第四項、奧地利聯邦行政罰法第一條第二項」作進一步的論證。既言參考刑法第2條第1項，則刑法尚且對犯罪行為人給予「從輕」的待遇⁶⁵，行政處罰實無較諸刑法嚴厲之理⁶⁶。是以，若以具處罰性質之行政處分為程序標的之撤銷訴訟⁶⁷，應以裁判時作為違法判斷基準時，且依

65 不同於刑事處罰係直接由法院為之，行政處罰的運作係由行政機關主導，法院只是居於事後合法控制（違法審查）的地位。換言之，從違法行為之發生以迄司法裁判確定之間，隔著一層行政權作用，而且是積極主動之行政裁罰，而非不告不理的司法裁判。也因此，法規變動所生的法適用問題，行政處罰要比刑罰來得複雜許多。於刑事處罰的程序中，原則上雖先有檢察官提起公訴，再由法院為是否有罪之判決。然法院的權力作用並非審究「公訴」（起訴書）的合法性，而是居於「處罰機關」的地位作成判決，故刑事裁判不生所謂「違法」判斷之問題。儘管刑罰與行政罰的程序與機制有所差異，然人民受國家處罰所受之不利利益則無不同，基於法治國原則及人權保障的意旨，二者之處罰原則不宜有異。

66 於此可參照稅捐稽徵法第48條之3規定：「納稅義務人違反本法或稅法之規定，適用裁處時之法律。但裁處前之法律有利於納稅義務人者，適用最有利於納稅義務人之法律。」本條為1996年7月30日公布新增，立法理由如下：「行政法上的『實體從舊』原則，其目的是要確定法律關係。但是，租稅行政罰則不然，並無法律權利義務關係確定問題，而是政府要對不遵守租稅行政規定的納稅義務人要如何裁處罰鍰，才能促其遵守稅法規定，如期履行繳納稅捐義務。所以連刑法都准許對犯罪行為人給予『從新從輕』的待遇，租稅行政罰更無不適用的道理。」上開法條所稱之「裁處」，依實務之見解，包括訴願之決定及行政訴訟之判決，故行政訴訟程序中（含上訴於最高行政法院之程序中），法律若為有利於納稅義務人之變更者，行政法院即應適用最有利於納稅義務人之法律（參見最高行政法院98年度判字第674號判決）。

嚴格而言，從「適用裁處時之法律」的文義以觀，稅捐稽徵法第48條之3的規範對象應是「裁處機關」，而非訴願機關及行政法院。換言之，稅捐稽徵法第48條之3與行政罰法第5條的法條文句雖略有差異，但規範旨趣並無不同。不過，行政法院仍從「連刑法都准許對犯罪行為人給予『從新從輕』的待遇，租稅行政罰更無不適用的道理」的立法理由推演出「行政爭訟程序中之從新從輕」原則，作為租稅行政罰的違反判斷基準時。此項法律見解具有一般性之重要意義，值得參介。

67 如何區分「具處罰性質」之行政處分，參見李建良，行政罰法中「裁罰性之不利處分」的概念意涵及法適用上之若干基本問題——「制裁性不利處分」概念之提出，月旦法學雜誌，181期，頁133-163（2010年）。實務上，行政法院目前創設「管制性之不利處分」概念，用以和行政罰法第2條所稱「裁罰性不利處

「從新從輕」原則處理，以維護人民權益。

次者，前開立論主要側重訴訟制度與概念邏輯論辯，且著眼於行政機關的立場，而未從行政實體法的角度辨析行政處分的規制內涵及其衍生效應。實則，行政處分的規制多樣，其合法要件及效力時點，必須從所由之法規依據、規制目的及其衍生後果進行全面性的觀照，始能切中肯綮，不致流於機械率斷。在此基礎下，值得探討者，乃行政處分所欲規制之內涵或所形成之法律關係，若係以一定事實或法律持續存在為前提，並產生一種持續性之規制效力，則一旦事實或法律狀態有所改變，該行政處分之效力、乃至於合法性即同時發生連鎖效應而隨之動搖，從而在判斷其違法性時，即應將此等變動因素納入考量。例如以居住在國內作為福利津貼之核發要件，則處分相對人（受益人）一旦不再居住國內（事實改變），則該核給處分之合法基礎即生動搖，而生可能違法之問題。此類之行政處分，在學理上向以「具有持續效力之行政處分」稱之⁶⁸，亦屬法制概念而見諸於行政程序法第128條第1項第1款。此種處分之效力既具有持續性，則應以行政法院言詞辯論終結前之事實或法律判斷該處分之適法性。

然須注意者，「具有持續效力之行政處分」概念與行政處分之違法判斷基準時問題不宜劃成等號，仍須視原告之主張而定⁶⁹。換

分」係以違反行政法上義務而對於過去不法行為所為之行政制裁相區隔（參見最高行政法院101年度判字第165號判決）。

⁶⁸ 此一概念源自德國„Verwaltungsakt mit Dauerwirkung“之概念，同時亦見於該國社會法典（Sozialgesetzbuch）第10編第48條之明文。依德國學說之見解，具有持續效力之行政處分，係指形成或變更持續性法律關係之行政處分，亦即該行政處分之效力非因一次性之執行或實現即已終結。例如：營業許可、駕駛執照、公物之提供公用、公務員之任用等，均屬具有持續效力之行政處分；反之，基於特殊原因之社會救助，則屬一次性之行政處分。參見Ulrich Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 7. Aufl., 2008, § 35 Rn. 223 ff.

⁶⁹ 關於「具有持續效力之行政處分」之概念內涵及其與行政處分違法判斷基準時之關係，於德國學說上非無爭議，參見Dagmar Felix, Der Verwaltungsakt mit

言之，原告得主張撤銷行政處分之全部，亦可僅撤銷某一時段之行政處分。若原告主張撤銷之時段並無事實或法律之變更，則仍以該時段之事實或法律狀態判斷之⁷⁰。此外，行政機關若撤銷或廢止具有持續效力之行政處分而生爭訟者，例如廢止營業許可或吊銷駕駛執照，則該廢止或吊銷處分之合法性仍應以處分作成時之事實及法律狀態判斷之。

就【思考案例】而言，甲之所以未獲建造執照，係因其所有土地位於禁建區上，故於主管機關廢止該禁建區之劃定時，設若甲所建房屋並未違反建築法相關規定，則該拆除處分（基礎處分）即應無執行之必要，從而甲若依法針對系爭拆除處分提起行政訴訟，行政法院即應將此因素考量在內。蓋違章建築拆除處分之規制內涵，除客觀上課予處分相對人除去該建築物之行為義務外，最主要之規制目的在於除去因該建築物之存在所可能產生之危險⁷¹。就此而言，拆除處分之規制效力與其所欲排除之特定危險狀態間具有持續性的關聯。是以，當主管機關廢止該禁建區之劃定，且甲所建房屋並未違反建築法相關規定時，系爭拆除處分存在之必要性（排除危險）即失所附麗，應予撤銷，以維處分相對人權利，並符撤銷訴訟之制度旨趣。

2. 行政程序重開之申請是否以基礎處分確定為要件？

相對於直接以基礎處分為程序標的，提起訴願及撤銷訴訟以除去該處分之效力，透過行政程序重開制度，請求除去基礎處分，在

Dauerwirkung – eine sinnvolle Kategorie des Allgemeinen Verwaltungsrechts?, NVwZ 2003, S. 385 (385 ff.); Matthias Wehr, Der Verwaltungsakt mit Dauerwirkung, BayVBl. 2007, S. 385 (385 ff.); Isabel Schübel-Pfister, Aktuelles Verwaltungsprozessrecht, JuS 2012, S. 420 (423 ff.).

⁷⁰ 另請參見德國實務見解BVerwG, NVwZ 2012, 510-512.

⁷¹ 未經申請許可而建造之建築物，若實際上符合相關建築技術規範（即一般所謂之「形式違建」），原則上主管機關應先命起造人辦理建造執照，而不得逕予命拆除之，否則即違反比例原則。

某種程度上，則是一種迂迴之道，人民以處分後事實或法律有變動為由，訴請行政機關撤銷或廢止基礎處分，故在訴訟類型上，並非撤銷訴訟，而是課予義務訴訟。

行政程序重開制度之所由設，旨在給予人民針對已無法透過行政爭訟程序除去效力（不可爭訟性）之行政處分，於一定要件下，仍有變更該處分之機會及權利，類如行政訴訟之再審程序。是以，行政處分作成後，且發生形式之確定力者，義務人或利害關係人得依據行政程序重開之規定（行政程序法第128條第1項第1款）⁷²，以行政處分所依據之事實或法律事後發生有利於其之變更，透過課予義務訴訟程序，請求行政機關廢止該拆除處分（基礎處分）。有待探討的問題是，系爭基礎處分若尚未確定，然其所依據之事實或法律事後發生有利於義務人之變更者，義務人得否請求行政程序之重開？尤其，如何解釋行政程序法第128條第1項所定「**行政處分於法定救濟期間經過後**」之要件？

此一提問之解答，與前述基礎處分違法判斷基準時之爭議，互有關聯。若如本文之見，於具持續效力行政處分之情形，其違法判斷原則上應以撤銷訴訟言詞辯論終結前之事實或法律狀態為基準，則系爭當事人自得且應直接依法循訴願及撤銷訴訟程序主張之，無由迂迴請求程序重開，另由處分機關撤銷或廢止該處分之必要。問題在於，行政法院若採通說見解，仍以「處分作成時」之事實或法律狀態作為違法判斷基準⁷³，則行政處分作成後變動之事實及法律

⁷² 行政程序法第128條第1項第1款規定：「具有持續效力之行政處分所依據之事實事後發生有利於相對人或利害關係人之變更者。」姑不論「具有持續效力之行政處分」究何所指，其僅限於「事實事後發生變更」，似乎過狹。反觀德國行政程序法第51條第1項第1款規定：「行政處分所依據之事實或法律事後發生有利於相關當事人之變更者」，其範圍較廣，亦較合理周延。我國行政程序法第128條第1項第1款僅限於「事實事後發生變更」，屬明顯之法律漏洞，應透過法律解釋補充之。

⁷³ 近期之例，為臺北高等行政法院99年度訴字第1856號判決（中科四期開發許可撤銷案）。

勢必無法成為據以撤銷該處分之事由，於此情形，唯有另尋救濟之路，而可資考量者，乃申請行政程序重開一途。不過，行政法院若膠柱於行政程序法第128條第1項「行政處分於法定救濟期間經過後」要件之一偏，而未能明曉事實或法律變動無從於救濟程序中主張之事實（如採「處分作成時」說）而有所應變者，勢將造成要件不符、實體不究的權利救濟漏洞。

行政程序法第128條第1項以「行政處分於法定救濟期間經過後」為申請要件之規範旨趣⁷⁴，在於系爭行政處分若能透過法定救濟程序予以變更者，無由允許處分相對人尋求間接週折且效益較低之救濟路徑。準此以推，設若特定之權利主張（行政處分作成後之事實或法律變動）無法於法律救濟程序中提出或被法院審究者，容應開放行政程序重開之門，給予人民有救濟之機會，以符行政程序重開之制度本旨。基於以上之考量，本文認為，行政法院對於撤銷訴訟之違反判斷基準時，若一律採「處分作成時」說，則行政程序法第128條第1項「行政處分於法定救濟期間經過後」之要件，即應依「舉重以明輕」（argumentum a maiore ad minus）之法理，解釋上不包含行政處分作成時其所依據之事實或法律事後發生、且有利於義務人之變更之情形，容許基礎處分相對人或利害關係人在該處分未確定前，得依行政程序法第128條申請行政程序重開，以謀救濟。

3. 基礎處分作成後發生之事實或法律變更得否作為「終止」行政執行之事由？

以上有關權利救濟之考量重點，集中在能否除去基礎處分效力

74 從比較法的觀點來看，我國行政程序法第128條規定係仿襲繼受自德國聯邦行政程序法第51條，該條所定行政程序重開（Wiederaufgreifen des Verfahrens）之申請並無「行政處分於法定救濟期間經過後」之要件，而是以「具不可撤銷性之行政處分」（unanfechtbarer Verwaltungsakt）為申請標的，以及「申請之提出，僅於相關當事人非因重大過失而未能於前行程序中（in dem früheren Verfahren），特別是救濟程序，主張其事由者，始得為之」為申請之限制（第51條第2項）。

之問題上。另一種訴求方式，則是轉而側重於執行階段，試圖阻斷行政執行之開始或續行。就行政執行法之規定以觀，涉及的是行政執行法第8條第1項有關行政執行「終止」之問題。

在觀念上應先區辨者，乃「執行目的已達成」與「執行目的無法達成」兩種不同的執行障礙因素。後者之例，主要有高度屬人性之行政處分，如處分相對人（義務人）死亡⁷⁵；處分之標的滅失，如應予撲殺之罹有傳染病動物，業已死亡；行政處分所欲防止之危險因情事變更而不復存在⁷⁶，如作成違章建築之拆除處分後，因事實或法律變更而已無拆除之必要者⁷⁷等。行政執行法第8條第1項第1款所稱「義務已全部履行或執行完畢者」，屬於「執行目的已達成」之情形（容後詳述）；相對而言，第3款所稱「義務之履行經證明為不可能者」，則是「執行目的無法達成」的明文。至於第2款「行政處分或裁定經撤銷或變更確定者」，基本上呼應前述所言，基礎處分若未經撤銷或變更，縱使違法（但有效），則執行機關原則上仍得執行之。在此規範體系架構下，應予探討究明者，乃基礎處分若未經撤銷或變更確定，能否以事後發生之事實或法律變更為由，申請終止行政執行？又，此種情形屬於何種終止事由？

面對上述問題，或許可以從基礎處分與行政執行之區隔性切入，主張基礎處分事後發生事實或法律變更，屬基礎處分層面之問題，非得作為阻卻行政執行之理由⁷⁸。然則，此一見解忽略了行政執行本身並非目的，其毋寧是為實現基礎處分之義務及其所欲規制之法律狀態。抑且，如前所述，行政執行係典型之干預行政，對於人民基本權之干預程度甚鉅，不僅須有法律明文規定，執行權之發

75 相關案例，參見德國實務裁判VGH BW, NJW 1984, 195 (196).

76 相關案例，參見德國實務裁判VG Leipzig, DÖV 1994, 660 (660).

77 相關案例，參見德國實務裁判BVerwGE 5, 351 (353); 6, 321 (322); BVerwG, MDR 1977, 607.

78 德國學說採此見解者，例如Wolf-Rüdiger Schenke/Peter Baumeister, Probleme des Rechtsschutzes bei der Vollstreckung von Verwaltungsakten, NVwZ 1993, S. 1 (3).

動及實施亦須具備實質正當性，尤其不得違反比例原則⁷⁹。準此以言，基礎處分作成後發生之事實或法律變更，若導致執行目的無法達成者，執行機關即不得啟動執行政程序，或應終止進行中之執行措施⁸⁰。從而，行政執行法第8條第1項第3款所稱「義務之履行經證明為不可能者」，在解釋上即應包含基礎處分作成後事實或法律變更致執行目的無法達成⁸¹之情形⁸²，以給予義務人或利害關係人請求終止執行之機會。

基礎處分作成後所發生之事實或法律變更，義務人得以訴訟方式處理執行名義所生之實體法上爭議，在制度上屬於一種「義務人異議之訴」⁸³，於訴訟程序上如何進行救濟，因法律規定不明而生爭議⁸⁴。最高行政法院於97年5月1日召開該年度5月份第1次庭長法

79 參見行政執行法第3條規定。

80 德國學說之相同見解，參見Lemke (Fn. 8), S. 240; Hans-Uwe Erichsen/Dirk Rauschenberg, Rechtsschutz in der Verwaltungsvollstreckung, Jura 1998, S. 323 (324).

81 此處所稱「執行目的無法達成」，觀念上包含「行政執行已無必要之情況」在內。

82 關於執行目的無法達成所生之問題，德國部分邦的行政執行法定有終止執行（Einstellung der Vollstreckung）之明文，以資解決。例如Baden-Württemberg邦行政執行法第11條規定：「行政執行之目的已達成，或經顯示不能以強制方法達成者，應即終止執行。（Wenn der Zweck der Vollstreckung erreicht ist oder wenn sich zeigt, daß er durch die Anwendung von Vollstreckungsmitteln nicht erreicht werden kann, ist die Vollstreckung einzustellen.）」另，Sachsen邦行政執行法第2條亦有類似規定，可資參照。

83 參見李建良，試論行政執行之債務人異議之訴——兼評最高行政法院97年5月份第1次庭長法官聯席會議決議，收於：王必芳編，2008行政管制與行政爭訟，頁127-166（2009年）。

84 （舊）行政訴訟法第307條規定：「債務人異議之訴，由高等行政法院受理；其餘有關強制執行之訴訟，由普通法院受理。」從規範體系而言，僅應適用於「行政法院裁判」之執行政程序（參見李建良，論行政訴訟強制執行之基本體系，臺北大學法學論叢，49期，頁61-122（2001年）；李建良，行政訴訟強制執行之救濟體系——以司法執行政程序為中心，東吳法律學報，13卷2期，頁31-60（2002年）），能否類推適用於「行政處分」之執行政程序，不無疑問。在德國學說及實務上，有主張直接適用民事訴訟法有關債務人異議之訴之規定。參見Hans Friedhelm Gaul, Die Mitwirkung des Zivilgerichts an der Vollstreckung von Verwaltungsakten und verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen, JZ 1979, S. 496 (499 ff.); Kornelius Kleinlein, Der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der

官聯席會議，其討論的第一項法律問題，即是：行政處分之受處分人，可否於行政機關以該行政處分為執行名義之強制執行程序終結前，以有消滅或妨礙債權人請求之實體事由發生，向高等行政法院提起債務人異議之訴？其決議文為：「按行政執行名義成立後，如有消滅或妨礙債權人請求之事由發生，不論其執行名義為何，於強制執行程序終結前應許債務人提起異議之訴，以排除強制執行。行政訴訟法第307條前段規定：『債務人異議之訴，由高等行政法院受理』，應認其係屬行政訴訟法關於債務人異議訴訟類型之規定。雖該條係列於同法第8編，但既未明定僅以同法第305條第1項或第4項規定之執行名義為強制執行者為限，始有其適用，則行政處分之受處分人，於行政機關以行政處分為執行名義行強制執行時，如於執行名義成立後有消滅或妨礙債權人請求之事由發生，亦得於強制執行程序終結前，向高等行政法院提起債務人異議之訴。」此一決議固然解決了債務人異議之訴的法律依據及受訴法院之爭議，然其所預設之「行政執行之債務人異議之訴」，則是一項內涵亟待填充之

Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten, VerwArch 81 (1990), S. 149 (177); Hans-Dietrich Traulsen, Die Rechtsbehelfe im Verwaltungsvollstreckungsverfahren, 1971, S. 150 ff., 174 ff.; OVG NW, DÖV 1965, 425 (426); OVG Berlin, DÖV 1961, 513 (514); NVwZ-RR 1989, 510; VG Freiburg, NVwZ-RR 1989, 514; 亦有主張準用民事訴訟法有關債務人異議之訴之規定。參見Peter Fischer, Rechtsschutz gegen die Vollstreckung aus Verwaltungsakten - Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, BayBVL 1980, S. 173 (173); Wolf-Rüdiger Schenke, Vollstreckungsrechtsschutz gegen Verwaltungsakte bei nach Bestandskraft entstandenen Einwendungen gegen den zu vollstreckenden Anspruch, VerwArch 61 (1970), S. 260 (260 ff., 342 ff.); Schenke/Baumeister (Fn. 78), S. 9; Eyermann/Fröhler (Fn. 59), Anh. § 172 Rn. 10; Ferdinand O. Kopp/Wolf-Rüdiger Schenke, VwGO, 16. Aufl., 2009, § 167 Rn. 18; Gerhard Sandler, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz: Kommentar anhand der Rechtsprechung, 4. Aufl., 2000, § 5 Rn. 13; Engelhardt/App (Fn. 14), § 5 VwVG Anm. 5; Inge Rudolph, Das Zwangsgeld als Institut des Verwaltungszwangs, 1992, S. 107; BVerwGE 27, 141 (143); OVG NW, NJW 1976, 2036 (2038); NVwZ 1993, 74; VGH BW, NVwZ 1993, 72. 另，行政訴訟法第307條因配合行政法改制及行政訴訟法庭的增設而於100年11月23日修正文字如下：「債務人異議之訴，依其執行名義係適用簡易訴訟程序或通常訴訟程序，分別由地方法院行政訴訟庭或高等行政法院受理；其餘有關強制執行之訴訟，由普通法院受理。」併此說明。

特殊行政訴訟類型。

如上所述，債務人異議之訴，係以訴訟之方式，解決執行名義上之實體法上爭議，並排除進行之強制執行或阻止行政執行之開始。換言之，行政法上債務人異議之訴，係以執行機關為被告所提起之行政訴訟。由於當前行政訴訟法制係依「行政行為之態樣」建立各種之訴訟類型⁸⁵，則此種以請求終止「整個」行政執行程序之訴訟，究屬何種訴訟類型，不無疑問，有待釐清。

由義務人向行政法院請求執行機關不得作出執行之行為，核其性質及訴求旨趣，乃屬於一種「不得執行之不作為請求訴訟」（eine Klage auf Unterlassung der Vollstreckung）⁸⁶。次查行政訴訟法第3條之規定，行政訴訟指撤銷訴訟、確認訴訟及給付訴訟三種。就請求「不得執行」之角度，此種預防性訴訟似應屬行政訴訟法第8條第1項所定之「一般給付訴訟」，亦即屬於一種「請求不作為訴訟」。然因義務人異議之訴並非僅針對「特定」之行為或措施，為不作為之請求，而是欲以「執行目的無法達成」為由，阻斷整個執行程序，使系爭執行名義之「執行效力」歸於消滅。換言之，人民提起此種債務人異議之訴，旨在訴請行政法院作成不許就該執行名義之全部或一部為強制執行之形成判決。就此而言，「行政執行之債務人異議之訴」應屬一種「一般形成訴訟」⁸⁷，此種訴訟類型法無明定，可由行政法院創設之⁸⁸。

85 參見李建良，台灣行政訴訟法制之沿革、演進與發展課題，收於：湯德宗、王鵬翔編，2006兩岸四地法律發展（上），頁303-305（2007年）。

86 參見Schenke/Baumeister (Fn. 78), S. 9; Lemke (Fn. 8), S. 485; Erichsen/Rauschenberg (Fn. 80), S. 325; Raimund Brühl, Die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungszwangs im gestreckten Verfahren, JuS 1998, S. 65 (66).

87 「一般形成之訴」之用語，亦相對於撤銷訴訟之「形成訴訟」。關於「一般形成訴訟」之概念及爭議，參見林明昕，一般形成訴訟——德國行政訴訟法上之爭議問題，收於：翁岳生教授祝壽論文編輯委員會編，當代公法新論（下）——翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集，頁79-97（2002年）。

88 相關討論，詳參李建良（註83），頁148-152。

（二）基礎處分之義務履行完畢與行政執行之關聯

不同於前述「執行目的無法達成」之阻卻執行事由，基礎處分（執行名義）確定後，如有消滅或妨礙該處分請求事項（義務）之事由發生，例如義務已全部履行，執行機關能否開始執行或繼續執行？義務人能否及如何救濟？屬於因「執行目的已達成」所生之基礎處分與行政執行的關聯問題。

義務已經履行尚不足構成撤銷或廢止原基礎處分之理由，蓋原處分之適法性並不因義務之履行而變成違法。換言之，基礎處分不問其是否具有形式確定力，縱使義務人已經履行義務，仍不影響基礎處分之效力，故行政程序法第117條以下有關撤銷原處分之規定，於此無適用之餘地。義務人亦不得以義務業已履行為由，而請求撤銷基礎處分。不過，義務人得以義務已經履行為由，請求終止行政執行，並廢除相關執行行為。行政執行法第8條第1項第1款設有明文：「行政執行有下列情形之一者，執行機關應依職權或因義務人、利害關係人之申請終止執行：一、義務已全部履行」，可資參照。

義務人依行政執行法第8條第1項第1款請求執行機關終止執行，執行機關若拒絕終止執行者，義務人得先依行政執行法第9條第1項聲明異議⁸⁹，執行機關若認為異議有理由者，即應停止執行之開始或續行；聲明異議若遭駁回者，義務人得提起債務人異議之訴，其依據及訴訟類型，已如前述，於此不贅。應補充說明者，債

⁸⁹ 行政執行法第9條規定係仿襲強制執行法第12條之規定所設，而該條規定若對照同法其他救濟規定而作體系解釋，可以得知，該條所稱「其他侵害利益之情事」，係指因實施「強制執行」所生之侵益情事，而非發生消滅或妨礙債權人請求之事由。是以，於上述執行機關拒絕終止執行之情形，似無法依行政執行法第9條規定聲明異議。惟按行政執行法並未如強制執行法在聲明異議制度之外，同時設有「義務人異議之訴」，故在解釋上，行政執行法第9條之聲明異議，非不能適用於因義務已履行完畢而請求終止執行之爭議。

務人異議之訴的暫時權利保護制度為假處分⁹⁰。義務人得於提起請求不作為本案訴訟之同時，聲請行政法院為假處分之裁定，以定暫時之狀態，在行政法院作出本案裁判之前，暫時凍結執行程序之續行⁹¹。此外，義務人尚得提起確認訴訟，請求確認各別之執行行為違法⁹²，或確認基礎處分所課予之義務已不存在。惟須注意確認訴訟之「備位性」問題，若可透過撤銷訴訟或給付訴訟而獲得救濟者，即不得提起確認訴訟⁹³。

併此指出者，義務人未自動履行，經強制執行而履行義務者，亦屬「執行目的已達成」之情形。然此種因執行完畢所生之行政救濟問題，較之自動履行複雜，故本文另闢專節討論之（參見「六、執行完畢之權利救濟問題」）。

三、行政執行之救濟機制與行政爭訟之關係

行政執行法第9條第1項規定：「義務人或利害關係人對執行命令、執行方法、應遵守之程序或其他侵害利益之情事，得於執行程序終結前，向執行機關聲明異議。」此項規定係針對各別執行措施所特設之救濟途徑，不問各該措施之法律性質為何，概可據該規定

⁹⁰ 參見BayVG, BayVBl. 1993, 600; Engelhardt/App (Fn. 14), § 18 VwVG, Anm. IV 2; Kopp/Schenke (Fn. 84), § 167 Rn. 20.

⁹¹ 於此並非涉及「基礎處分」的撤銷訴訟及其所衍生的停止執行問題，而是基礎處分之義務已履行完畢，執行機關卻仍持續或繼續為執行措施。於此情形所生之救濟問題，屬於「債務人異議之訴」的類型，其程序標的並非「基礎處分」，亦即訴求及程序標的並非旨在「撤銷」特定之行政處分，而是請求執行機關不得再執行措施（包括未來），在訴訟類型是「請求不作為（不得執行）」之一般給付訴訟，與此對應的暫時權利保護制度為假處分，而非「行政處分」停止執行制度。

⁹² 參見VG, NVwZ 1993, 73; HessVG, NVwZ-RR 1989, 507; Maurer (Fn. 45), § 20 Rn. 11; Kopp/Schenke (Fn. 84), § 167 Rn. 17; Rudolph (Fn. 84), S. 113; Bill Drews/Gerhard Wacke/Klaus Vogel/Wolfgang Martens, Gefahrenabwehr, 9. Aufl., 1986, S. 571 (608).

⁹³ 關於確認訴訟之備位性，參見劉淑範，論確認訴訟之備位功能：行政訴訟法第六條第三項之意涵與本質，人文及社會科學集刊，15卷1期，頁59-112（2003年）。

聲明異議，謀求救濟。有疑義者，對於聲明異議之決定，如有不服者，能否提起行政訴訟，續謀救濟？按行政執行法修正時，修正草案第9條第2項規定：「前項聲明異議，執行機關認其有理由者，應即停止執行，並撤銷或更正已為之執行行為；認其無理由者，應於十日內加具意見，送直接上級主管機關於三十日內決定之。」原有「異議人對之（亦即異議決定）不得再聲明不服」之字句。此段文字於立法院進行二讀程序時遭到刪除，據此應可解為立法院有意予異議人聲明不服之機會，從而，異議人對於異議決定如有不服，得提起行政訴訟法，以謀救濟。然於行政訴訟實務上，行政法院曾以原修正草案原有「不得聲明不服」規定為據，否認異議人之司法救濟權⁹⁴，此種無視立法院刪除此段規定之用意，漠視人民司法救濟權益之作法，自不足採。是以，不論從法律解釋方法以言，抑或從人民訴訟權之保障究論，人民對於聲明異議之決定，如有不服者，尚得進一步提起行政訴訟，續謀救濟（關此將於討論「執行方法之實施」的法律性質及其救濟問題時，再予詳論）。

最高行政法院於2008年12月26日召開97年12月份第3次庭長法官聯席會議，討論的法律問題之一，為義務人或利害關係人不服執行機關所為行政執行措施時，是否因行政執行法第9條聲明異議程序之規定，而不得提起行政爭訟？決議採否定立場，認為行政執行法第9條規定「旨在明定義務人或利害關係人對於執行命令、執行方法、應遵守之程序或其他侵害利益之情事，如何向執行機關聲明異議，以及執行機關如何處理異議案件之程序，並無禁止義務人或利害關係人於聲明異議而未獲救濟後向法院聲明不服之明文規定，自不得以該條規定作為限制義務人或利害關係人訴訟權之法律依據」，同時放棄歷來不許人民提起行政訴訟之見解，改為：「在法律明定行政執行行為之特別司法救濟程序之前，義務人或利害關係人

94 參見高雄高等行政法院91年度訴字第783號裁定、臺北高等行政法院91年度訴字第4427、4533號裁定。

如不服該直接上級主管機關所為異議決定者，仍得依法提起行政訴訟」。此項決議之作成，意味行政法學界多年來對實務之批評意見，獲得最高行政法院正面之回應。相信在擺脫「行政執行不能司法救濟」之緊箍咒後，行政執行救濟體系之建構，將會有長足之開展。本決議後段所示：「何種執行行為可以提起行政訴訟或提起何種類型之行政訴訟，應依執行行為之性質及行政訴訟法相關規定，個案認定」，自賴學界與實務之共同努力，俾以建立一套足供「個案認定」之具體準據。至於本決議末尾提及「其具行政處分之性質者，應依法踐行訴願程序，自不待言」云者，實則牽涉行政執行法第9條所定聲明異議程序之於訴願程序，究屬「前置關係」、「取代關係」抑或「競合關係」，學說上早有討論⁹⁵，但無定見，何者較符合法律規定之本旨，猶待深論⁹⁶。

四、各別執行措施之救濟問題：執行行為之法律性質及其救濟方法

行政執行救濟體系之建構，除須對應行政執行之體系構造及制度內涵外，尚須觀照當前之行政救濟體系，尤其是訴訟類型及其程序要件。蓋現行行政訴訟制度之訴訟類型，撤銷訴訟、課予義務訴訟、一般給付訴訟、確認訴訟，基本上係以行政行為之態樣為取向，更精確言之，係以爭訟行政行為（程序標的）之法律性質，大別為「行政處分」與「行政處分以外之行為」二類，作為制度設計之考量基礎，並分別設定不同之程序合法要件。是以，在析論行政執行之救濟體系之前，須先究明各該執行行為之法律性質，再論其救濟方法。

95 參見蔡茂寅，怠金處分之救濟，月旦法學雜誌，50期，頁14-15（1999年）。

96 實務見解，主要參見最高行政法院98年度裁字第202號裁定。

（一）告戒

告戒對於行政強制執执行程序之開啟，具決定性之規制作用，居於行政執执行程序之樞要地位，不容輕視。告戒對於「是否」及「如何」動用強制手段，具有拘束性之確認效力（執行機關若採取不同於告戒所載之強制方法，即構成違法），為行政強制執行後續階段之前提要件⁹⁷。是以，相對於基礎處分，告戒無疑是一獨立之行政處分⁹⁸，從而得為撤銷訴訟之程序標的⁹⁹。

在實務運作上，基礎處分與告戒經常合而為一，惟在觀念上，基礎處分與告戒，乃屬不同層次之概念，其各有不同之規範內容，且為不同階段之行政程序。是以，義務人對於告戒處分之救濟，並不當然及於基礎處分，反之亦然。設若義務人僅就告戒有所不服，則當基礎處分因訴願期間之經過而確定時，義務人僅尚得針對告戒

⁹⁷ 參照BayVGHE 34, 75 (76); BayVGH, BayVBl. 1983, 276.

⁹⁸ 告戒在性質上屬行政處分，為德國學界及實務之通說，參見Traulsen (Fn. 84), S. 103; Hans Julius Wolff/Otto Bachof, Verwaltungsrecht, Bd. III, 1978, § 160 IIj, S. 391; Sandler, (Fn. 84), § 13 Rn. 1; BVerwG, DVBl. 1989, 362 f.; DÖV 1996, 1046; NVwZ 1998, 393; BVerwGE 82, 243; OVG Lüneburg, BRS 44, Nr. 208; VGH Mannheim, ESVGH 24, 105 (107); 28, 42 ff.

實務上早期認為告戒為行政處分，參見（最高）行政法院58年度判字第378號判決、68年度判字第359號判決。惟行政訴訟法修正，高等行政法院成立，行政法院改制為最高行政法院之後，卻改變見解認為告戒僅是行政執执行程序行為，不具行政處分之性質。此種見解之轉變，多少是囿於行政執行各項措施不得提起行政訴訟之陳腐觀念。國內學者有認為告戒為行政處分者，例如許宗力，行政處分，收於：翁岳生編，行政法（上），頁552（2000年）。

⁹⁹ 德國聯邦行政執行法第18條第1項規定：「對於強制方法之告戒，得以針對應予執行之行政處分之救濟方法救濟之。告戒如與基礎處分相結合者，於該處分尚未成為救濟方法或訴訟程序之標的時，對於告戒之救濟同時及於該處分。告戒如未與基礎處分相結合，而該基礎處分已具不可撤銷性者，該告戒僅於其本身構成權利侵害之主張範圍內，得予撤銷之。」此一規定初觀之下，似乎不認為告戒為獨立之行政處分。究其實，本項規定旨在排除基礎處分與告戒處分救濟途徑之雙軌性，其中第二句規定，則是有利於義務人之特別規定。此種救濟之自動延伸規定，主要是基於權利保護之有效性與程序經濟之考量，俾使義務人對於基礎處分之指摘與對告戒之不服，於同一程序中，一併解決。參見Pietzner (Fn. 9), S. 267.

「本身」所生之權利侵害有所爭執，而不得再對（課予義務之）基礎處分有所主張¹⁰⁰。人民對於「告戒處分」所得主張之事由，略有：未以書面為之，未合法受達於義務人，未載明履行期間，未載明執行方法，所定履行期間不合理、甚至不可能實現，所告戒之執行方法違反比例原則，所告戒怠金之金額或代履行費用過高等。

另併予指明者，現行法對於公法上行為、不行為義務之執行仍援用舊法，規定可為執行名義者，包括「依法令」及「本於法令之處分」兩種（行政執行法第27條第1項）。現行法中雖規定無行政處分書者，應以書面通知限期履行，方得予以強制執行，以保障義務人之權益（行政執行法第27條第1項）。惟嚴格言之，「書面通知」在性質上屬於行政強制執行程序中之告戒處分，而非就人民之權利義務關係為確定之行政處分，則人民於行政爭訟中所能指摘者，應僅限於有關執行政程序上之事項，例如期限之長短是否適當，內容是否明確等，至於實體之權利義務事項，例如，就是否構成違章建築之事項有所爭議時，似無從於該行政爭訟中主張之，故行政執行法第27條規定之「限期履行書面通知」與「依行政處分而負公法上之義務」者，仍有所別¹⁰¹，為保護人民權益計，宜於行政執行法中規定，行政強制執行原則上非依行政處分不得為之。

¹⁰⁰ 為避免此種情形之發生，強化對義務人權益之保護，德國聯邦行政執行法第18條第1項第2句規定：「告戒如與基礎處分相結合者，於該處分尚未成為救濟方法或訴訟程序之標的時，對於告戒之救濟同時及於該處分。」惟義務人若明示僅就告戒提起行政爭訟者，其效力不及於基礎處分，蓋義務人之意思仍應與予尊重。參見Engelhardt/App (Fn. 14), Anm. II 2a zu § 18 VwVG。至於告戒若未與基礎處分一併為之者，基於相同之考量，似應作相同之解釋，亦即，除義務人有明示之相反見解，否則其對告戒之不服，其效力應及於基礎處分。

¹⁰¹ 吳庚教授則認為，書面通知與行政處分既無實質上之差別，則限期履行書面通知之規定與依行政處分負金錢給付義務者，並無區分之實益，請參閱吳庚（註24），頁502。

(二) 執行方法之確定

所謂「執行方法之確定」(Festsetzung eines Zwangsmittels)者，指將告戒中所載之執行方法予以具拘束力之確定¹⁰²。例如確定怠金之金額，並科處之，或確定代履行費用之金額及義務人之繳納義務¹⁰³，應具行政處分之性質¹⁰⁴。

怠金之確認(Zwangsgeldfestsetzung)之所以具有行政處分之性質，乃因怠金之「給付義務」，始於怠金之確認，而非告戒。換言之，怠金之確認，在性質上，為所謂之「給付處分」(Leistungsbescheid)，乃是另一新的基礎處分，構成另一新的(公法上金錢給付義務之)執行程序的執行名義。至於其他執行方法之確定，亦具有獨立之規制內涵¹⁰⁵。例如於代履行之情形，執行機關作成執行方法之確定時，始生義務人之繳納義務。於直接強制之情形，雖無類如怠金與代履行費用之課予金錢給付義務之規制作用，惟其對義務人確認即將動用直接強制手段時，實同時課予義務人

¹⁰² 基本概念及相關問題，參見Bertrand Malmendier, Die Zwangsmittelfestsetzung in der Verwaltungsvollstreckung des Bundes und der Länder, VerwArch 94 (2003), S. 25 (25 ff.).

¹⁰³ 參照行政執行法第29條第2項：「前項代履行之費用，由執行機關估計其數額，命義務人繳納；……。」

¹⁰⁴ 依照德國1950年代制訂聯邦行政執行法之立法理由，「執行方法之確定」被視為事實行為，因而，在該法中只針對告戒設有救濟規定，而未及於「執行方法之確定」，甚至在立法理由說明，此種爭議僅能透過行政內部監督方式處理之(BT-Druck. I/3981 S. 9 zu BVwVG § 18)。不過，此一「立法意旨」多少係囿於二次戰前僅行政處分始得提起行政訴訟之觀念，並未為戰後行政法院所採。德國聯邦行政法院早在1955年11月14日之判決中指出：「怠金之確認本身，無論在司法實務上或是學說上，均被認為是一種可資撤銷之行政處分；蓋其乃對具體個案之高權決定。(BVerwGE 49, 169 (170 f.); BVerwGE 28, 305 ff.; 84, 354 (359).)」參見Pietzner (Fn. 12), S. 297, 303; Rolf Birk, Die Festsetzung des Zwangsgeldes nach dem Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz, BayVBl. 1967, S. 124 (126).

¹⁰⁵ OVG Koblenz, NVwZ 1986, 762; Siegfried Neumann, Die Anfechtung formeller Verwaltungsakte, insbesondere der Festsetzung von Zwangsmitteln: Zur Vollziehung von Verwaltungsakten, DVBl. 1957, S. 304 (305); Traulsen (Fn. 84), S. 104 f.

「容忍」強制措施之義務¹⁰⁶。尤須強調者，執行方法之確定，除確認義務人未於法定之履行期間內履行其應盡之義務外，更進一步決定即將採取之強制方法，特別是時間上之要素。藉由此種方式，給予義務人最後自動履行之機會，以免遭受強制手段之不利後果¹⁰⁷。

行政執执行程序之階段化，亦即，將行政程序之進行，分隔為基礎處分之作成、告戒、執行方法之確定，並均將之定性為行政處分，且各有不同之規範內容，其必然對應不同之救濟程序，且各自有不同之爭訟標的。換言之，對於告戒之爭訟，必然與對執行方法確定之救濟，有所不同。準此以推，告戒之規範內容一經確定，或經爭執而未獲變更，則在針對執行方法之確定有所爭執時，自不得再就告戒之規範內容有所指摘。具體而言，告戒之規範內容，乃履行期間（行為義務）、「是否」施以強制執行，以及應以何種強制方法為之。是以，義務人若對執行方法之確定有所爭執者，例如對於怠金之科處或對於代履行費用之科處，自不得再就履行期間（行為義務）、「是否」施以強制執行乙節，以及強制方法之種類及額度，有所不服，而僅能針對超出於告戒規範內容之部分，例如怠金及代履行之金額與告戒之內容不同，或告戒所無之執行方法，有所爭執¹⁰⁸。

關於「執行方法之確定」基本觀念之辨正，實務上有一則案例

¹⁰⁶ 由於直接強制方法之動用，通常發生於情況急迫時，亦即執行人員直接動用強制手段，故在「法律上」是否存有所謂「執行方法之確定」此一階段程序，非無疑問，德國學說及實務上，近來頗多有關是否將「告戒—執行方法之確定—執行方法之實施」三階結構改為「告戒—執行方法之實施」二階結構之討論，參見Malmendier (Fn. 102), S. 25 ff.

¹⁰⁷ 參見Pietzner (Fn. 9), S. 270; BVerwGE 82, 243 (245 f.). 德國部分邦行政執行法雖未明定「執行方法確定」之階段，但基於保護人民權利之需要，尤其是基於比例原則之考量，在實務上仍有此一階段，並將執行方法之確認當作行政處分，參見OVG Koblenz, NVwZ 1984, 1185; NVwZ 1986, 762. 不同意見BayVG, BayVbl. 1986, 176 (177).

¹⁰⁸ Neumann (Fn. 105), S. 305 f.; BVerwGE 84, 360; OVG Berlin, NJW 1968, 1109.

（高雄高等行政法院98年度訴字第150號判決），可供參考、探討：

被告為高雄縣政府，為辦理曹公圳（鳳山城址段）復育整治及水質改善計畫，在高雄縣鳳山市某路段圳路範圍內進行施工。臺灣省高雄農田水利會（即原告）以該路段土地部分為其所有，高雄縣政府未經其同意逕自施工，遂向臺灣高雄地方法院（下稱高雄地院）聲請假處分，經該院於97年5月2日以高雄地院高97司執全文字第2297號執行命令，命高雄縣政府於本案判決確定前，不得在該土地上為營造及一切處分行為在案。嗣原告在該土地上設置圍籬等障礙物，高雄縣政府遂於97年5月29日發函要求原告於文到3日內立即撤除各種施工障礙等器物，並配合主管機關改善圳路疏濬及環境維管等各項施工設施，如未於期限內改善完竣，將依行政執行法第29條規定代履行，並命原告繳納代履行之費用及相關支出。惟原告並未於期限內改善，高雄縣政府乃於97年6月13日發函請求原告於同年月30日前繳納代履行費用及相關支出計71,908,180元台幣。原告不服，提起訴願，遭決定不受理，遂提起本件行政訴訟。承審之行政法院作成訴願決定及原處分均撤銷之判決。

關於撤銷訴願決定部分，訴願決定係以原告如對被告上開命其繳納代履行費用之處分不服，應依聲明異議方式以資救濟，尚非屬提起訴願所得救濟之範圍為由，而為訴願不受理。就此，行政法院以「代履行」為間接強制方法之一，關於執行方法上之選擇是否妥當，其救濟途徑固應依行政執行法第9條規定聲明異議，惟對於代履行費用之核定函，既具有確認及下命處分之性質，義務人若對其是否應負擔該費用或對其金額有所不服，自得依法提起訴願及行政訴訟救濟之，認上開訴願決定所持法律見解，自有可議。

關於代履行費用核定函之適法性問題，承審之行政法院認為高雄縣政府辦理曹公圳（鳳山城址段）復育整治及水質改善計畫，因原告非上開計畫之執行機關，自無配合施工之義務，從而，高雄縣

政府以上開費用為代履行費用為由，函命原告繳納，即有違誤。

以上論述，揆其旨趣，行政法院係以原告（臺灣省高雄農田水利會）無配合施工及拆遷圳溝兩旁建物之行政法上義務，推導出原告無負擔該代履行費用義務之結論。然嚴格而言，系爭代履行費用處分之作成，係因原告未履行高雄縣政府命其撤除系爭土地上各種施工障礙等器物及配合改善圳路疏濬及環境維管等各項施工設施之「義務」所致。換言之，原告負有撤除系爭障礙物之「公法上行為義務」，與原告因未履行前開行為義務所負有之代履行費用義務（公法上金錢給付義務），分別是兩個獨立之行政處分，在觀念上，乃屬二事，承審之行政法院似有將「基礎處分」與「執行行為」混為一談之嫌，由此印證本文何以再三強調區辨「基礎處分」與「執行行為」之原因所在。

（三）強制方法之實施（含即時強制）

行政執执行程序若進入動用強制方法之階段，則執行機關應依照其事前所確定之強制方法實施之。關於行政實體法上及行政執行法上有待規制之問題，業已經由基礎處分、告戒及確定執行方法等程序處理之，於執行方法「實施」之階段，則是將上開行政處分所要求之義務（行為、不行為及容忍義務）予以貫徹（實現）。其主要特徵在於，（心理上或物理上）壓制義務人之反抗意志，就此而言，不同執行方法之效果，自然有所差異。

1. 怠金之實施

怠金之實施，表現在對所課怠金額度之「強制收取」（Beitreibung），由此復開啟另一新的行政強制執执行程序。質言之，即以「怠金之確認」（執行方法之確定＝行政處分）為執行名義，接續以其他之行政措施，貫徹之。通常先作成如命給付之處分，繼

之以查封、拍賣等措施¹⁰⁹或強制取拿與怠金給付義務等值之財產¹¹⁰，或佐以拘提管收、限制住居等間接強制方法¹¹¹。凡此均屬公法上金錢給付義務之執行，非本文之重心，將另文介述之，於此僅論究其法律性質。按上開執行方法之實施，概皆具有規制作用，例如強制取拿之標的，不問查封拍賣，或是強制占有（解除占有），應皆屬法律行為，而具行政處分之性質¹¹²。人民對之若有不服，經聲明異議後，得對之提起撤銷訴訟，謀求救濟。

2. 代履行之實施

代履行之實施，係就可替代性之公法上行為義務，於義務人不履行時，由執行機關代為履行，並收取費用。例如：建築主管機關查獲某未經許可之違章建築，經命其拆除（基礎處分）而未獲遵從時，而予拆除，並收取拆除所支出之費用，即屬之。是以，代履行之實施可分為「代替義務人履行義務，以達與義務履行之相同狀態」與「收取代履行費用」二端。其中代履行費用之收取，寓有行為義務轉換為金錢給付義務之意。此一義務復以給付處分確定之，並得經由強制徵收之途徑予以執行，其情形如同怠金之強制徵收，已如前述，不再贅述。

有疑問者，此一法律效果，亦即國家對人民之代履行費用請求權，在行政執行之程序中，係於何一階段產生並予所確定。具體言之，代履行費用之給付義務，究係於代履行執行方法確定時，即已存在，抑或於實施代履行行為時，方始發生？德國聯邦行政法院係採前說¹¹³，學者有採後說者¹¹⁴；另亦有持折衷見解，即以前說為

109 參照行政執行法第14條以下規定及強制執行法相關規定。

110 參見BVerwGE 54, 314 (316); Pietzner (Fn. 9), S. 271.

111 參見司法院釋字第588號解釋。

112 惟德國有學者主張強制取拿人民所有之物，在性質上屬於事實行為，參見Pietzner (Fn. 9), S. 271.

113 BVerwG, NJW 1976, 1703 ff.

主，但以義務人自動履行義務為解除條件（*auflösende Bedingung*），亦即該費用給付義務必須至義務人不履行、且執行機關業已實施代履行措施，始條件成就¹¹⁵。本文認為，代履行費用之給付義務應於執行方法之確定時，即已產生，此亦執行方法之確定具有行政處分之原因所在（參見前述）。至於義務人在執行機關動用強制力之前，即已自動履行者，該課予繳納代履行費用之行政處分，其效力仍繼續存在，惟義務人得以義務已經履行而請求終止執行（參見前述）。

再就「代替義務人履行義務，以達與義務履行之相同狀態」而言，須先區辨由何人實施該強制行為。按行政強制執行體系中，代履行包含「自力履行」（*Selbstvornahme*）與「他力履行」二種¹¹⁶。所謂「他力履行」，係指由行政機關委託私人（第三人）代為履行之謂。此種外觀上看似「私人行為」之履行行為，在德國實務及學說，非僅不將之定性為行政處分，甚至不認為其具有高權性質（公權力性質）¹¹⁷。實則，義務人對於私人（第三人）之執行行為，例如汽車拖吊或進入建築物，亦負有容忍之義務，於實施執行行為時，若遭遇義務人之抗拒，行政機關亦得基於法律之授權，以實力排除之¹¹⁸，故本文認為，其仍屬公法上之行為¹¹⁹，與由行政機關人

114 例如 *Christian-Friedrich Menger*, *Höchststrichterliche Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht*, *VerwArch* 68 (1977), S. 293 (294 ff.).

115 *Pietzner* (Fn. 9), S. 272.

116 行政執行法第29條第1項規定：「依法令或本於法令之行政處分，負有行為義務而不為，其行為能由他人代為履行者，執行機關得委託第三人或指定人員代履行之。」此一規定是否兼含「自力履行」與「他力履行」二種，非無爭議。參見李建良，行政執行，收於：翁岳生編，行政法（下），頁917-918（1998年）。

117 BGH, NJW 1978, 2502 f.; 不同意見 *Joachim Burmeister*, *Die Ersatzvornahme im Polizei- und Verwaltungsvollstreckungsrecht*, *JuS* 1989, S. 256 (256 ff.).

118 參照德國聯邦行政執行法第15條第2項：「於代履行或直接強制時，義務人抗拒者，得以實力排除之。警察得依執行機關之請求協助之。」

119 此點在人民之權利因該私人之行為而受有損害時，能否請求國家賠償之問題上，尤具重要性。參見李建良，因執行違規車輛拖吊及保管所生損害之國家

員自行為之（自力履行）應無不同。至於代履行之實施行為本身是否具有行政處分之性質，抑或屬於行政事實行為，則非無爭議¹²⁰。按「代履行」與「直接強制」之差異，僅在於義務之可替代性與否，就排除抗拒及達到與義務履行之相同狀態而言，二者咸同，而非迥然有別，故其法律性質之問題，得與下述之直接強制併予探討之。

3. 直接強制之實施

直接強制之實施，例如警察動用警棍或以噴水方式驅散群眾，或以警力解除義務人對某一房屋之占有；又如主管機關命義務人不得於其所有土地上燃燒稻草，未獲遵從，乃逕予以澆熄等。上開施用警棍、噴水、清空房屋、澆熄稻草等行為，均屬一種純粹物理力之運用，似不具有規制作用。然此一觀察，只是其表，未必符實。

直接強制之實施，是否具有行政處分之性質，德國學說及實務上頗具爭議，歧說紛呈，迄今未歇。以德國聯邦行政法院為例，早期即有不同見解，該院第五庭曾持行政事實行為說，認為執行行為雖屬高權措施，惟並不具有規制作用，換言之，必須直接形成、變更或廢止相對人之權利，始堪為行政處分¹²¹。反之，第一庭則認為，類如清空房屋之執行行為，具有行政處分之性質，乃因其非僅執行原基礎之清空處分，同時在執行清空措施時，對於義務人之權利地位亦產生影響¹²²。

嗣後，德國聯邦行政法院於1967年2月9日針對所謂「施瓦本區

賠償責任——兼論委託私人行使公權力之態樣與國家賠償責任，中興學學，39期，頁85-133（1995年）。

¹²⁰ 參見VGH Kassel, NVwZ 1982, 514; *Stelkens* (Fn. 68), § 35 Rn. 74.

¹²¹ BVerwG, NJW 1956, 1652; 同說*Stelkens* (Fn. 68), § 35 Rn. 32; *Schenke* (Fn. 146), Rn. 194, 196; *Hans Meyer/Hermann Borgs-Maciejewski*, VwVfG, 2. Aufl., 1982, § 35 Rn. 40.

¹²² BVerwG, DÖV 1964, 171.

騷動案」(Schwabinger Krawalle)作出之裁判¹²³，自此成為實務上具有標竿作用之裁判。本案事實略以：慕尼黑市施瓦本區（商業區）主要街道上，連續數日陸續不斷有群眾聚集，人數達數千人之眾，致使公共秩序受到嚴重影響，大量員警被派往現場維持秩序。一晚，某高階警官於現場命令群眾清除該街道。該警官先以口頭下達驅離命令（Platzverweisung），並同時告戒聚集之群眾，若不自行離開現場，將動用配戴的塑膠警棍（Hiebwaffen）強制驅離。群眾拒不遵從，警察遂以警棍強行驅離群眾。某位參與該群聚之人民頭部遭警棍擊中，乃於事後向行政法院提起訴訟，請求確認警察之驅離命令及以警棍作為直接強制措施違法。

聯邦行政法院對於以警棍作為直接強制之方法，以如下之理由，定性為行政處分¹²⁴：

「此等行為並非僅是純粹之事實行為，而是符合行政法院法第42條所稱行政處分概念要素。直接強制之運用，因致個人權利受有特別重大之影響，而詳予規範。……警察不僅得以書面或言語之行政處分，尚得藉由體力（körperliche Gewalt）以默示行為（konkludentes Verhalten）促使相關人民為一定之行為（*Ernst Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts*, 9. Aufl., 1966, S. 191.）。」

對於上開見解，學者提出批評，認為聚集群眾離去現場之要求，業已基於原本之驅離命令¹²⁵，故警察無須再以警棍作出相同之要求。另外，有學者認為，此種認定與現實生活相去甚遠（*lebensfremd*），從權利救濟的角度來說，亦無必要。蓋此類行為之行政救濟，與其是否為行政處分無關¹²⁶。警棍之使用，旨在促使義

¹²³ BVerwGE 26, 161 ff.

¹²⁴ BVerwGE 26, 161 (164 f.).

¹²⁵ Renck (Fn. 7), S. 114.

¹²⁶ Drews/Wacke/Vogel/Martens (Fn. 92), S. 215 (217).

務人履行其義務（離去現場）。藉由加諸於義務人身上之疼痛，「逼使」其履行行為（離去現場）義務，義務人之反抗意志遭到棍棒之威嚇作用所壓制。此種以體力（物理力）直接強迫義務人為特定之作為，必然是針對義務人之反抗意志而發。至於該義務人原本所應遵從之義務，業已經由基礎處分（驅散命令）所確定，警棍之使用，充其量只是提醒義務人其所應遵從之義務，而未設定新的義務。

除上述法院見解外，學說上另有主張構成行政處分之理據，即援引Forsthoff行政法教科書之見解（*Ernst Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts*, 9. Aufl., 1966, S. 191.），認為此種事實上之行為其實蘊含有命相對人容忍執行行為之內涵，亦即將強制行為視作一種默示之容忍命令（*konkludenter Duldungsbefehl*）。對於此種論理上之嘗試，反對見解認為，其與「強制方法」之法律性質不相吻合。蓋強制方法之使用，並非旨在課予義務人容忍國家強制力之義務，而是促使義務人履行其原本基於基礎處分（執行名義）所應負之行為義務。至於對於行政機關強制力之容忍義務，其意義僅在於，義務人負有不得抗拒執行行為之實施¹²⁷。然而，此類在本質上亦屬一種「不作為義務」的容忍義務，從行政強制執行之法律關係，即已得出。換言之，容忍義務乃是行政機關實施強制權力的相對之物（*Gegenstück*）¹²⁸，而不是特別有所謂「容忍承受棒擊之義務」。蓋動用警棍並非是一種「杖刑」（*Prügelstrafe*），而是驅使人民履行作為義務之一種輔助手段¹²⁹。

綜觀上述說法，直接強制之實施是否具有行政處分之性質，顯非能僅從其表現於外之「物理行為」論斷之，尚應參酌其效力輻圍作體系性、功能性之綜合考量。換言之，除從概念要素之角度分析

127 刑法上之妨害公務罪，即旨在制裁此種「容忍義務」之違反。

128 *Pietzner* (Fn. 9), S. 276.

129 參見Frederik Rachor, *Das Polizeihandeln*, in: Lisken/Denninger (Hrsg.), *Handbuch des Polizeirechts*, 5. Aufl., 2012, E. Rn. 39 f.

執行行為之法律性質外，尚有從權利救濟之角度，考量有無將執行行為視作行政處分之必要。此一考量視角之所以經常被提出討論，多半出於直接強制對於人民權利所造成之干預程度。惟須指出者，對於事實的改變或對於人民權利之干預，並非當然等同於行政處分概念要素之「規制」。換言之，行政措施影響或干預人民之公法上權利，並不當然使該措施成為行政處分，應屬當今行政法學上之基本通念¹³⁰。蓋人民基於公權利所得對抗之國家行為，不僅限於具有規制性之行政處分，尚包括具有干預性之事實行為，故干預行為並不同於行政處分。

細究將強制行為定性為行政處分之見解，除開從概念要素之視角外，主要出於兩項理由，一是從行政救濟的角度，另一是從行政程序法規範的角度。前者係因為過去行政爭訟僅以行政處分為程序標的，對於行政事實行為欠缺救濟管道，即使將行政訴訟之範圍擴大到所有公法上爭議，因對於事實行為之救濟種類及方法，較諸以行政處分為標的之各種訴訟類型，較為遜色、不備。後者乃因行政程序法對於行政行為之規範，以行政處分最為詳盡、周全，反觀對於事實行為之程序規範，則相對較為簡陋¹³¹。

關於行政事實行為受正當法律程序之規範乙節，衡諸當前行政程序法之規定，確實有所不足，惟縱令將執行行為定性為行政處分，未必就能受到較周全之制約。蓋行政程序法部分條文將行政執行行為排除於該法適用範圍之外，其中最明顯者，乃行政強制執行時所採取之各種處置，行政機關得不給予陳述意見之機會（參照行政程序法第103條第4款）。倒是行政執行法中自有之程序規範，對於執行行為之制約，較之行政程序法並不遜色。

¹³⁰ 參照BVerwGE 77, 273.

¹³¹ 參見Albert Bleckmann/Rolf Eckhoff, Der „mittelbare“ Grundrechtseingriff, DVBl. 1988, S. 373 (381 f.).

至於行政救濟之考量角度，其問題又可分成兩種層次，一是「能否」救濟之問題；二是「如何」救濟之問題。後一問題之存在，又以前一問題獲肯定為前提。

關於「能否」救濟之問題，可以細分成兩種成因，一是出於對行政執行「程序特性」之考量，認為行政執行貴在迅速，不宜由法院予以審理，故不問行政執行行為之法律性質為何，即使是行政處分，一概不得提起行政訴訟，僅能透過行政監督之方式救濟之¹³²。另一成因是出於「行政訴訟制度」所使然，亦即，曩昔行政爭訟以行政處分存在為前提，故行政執行行為若不具行政處分之性質，即不得提起行政爭訟，以資救濟¹³³。前一因素，由於法律之特別排除規定，故行政執行「基於法律明文」而被摒除於行政救濟之門。反之，後一因素並未禁絕行政執行之救濟，只是將救濟之客體限定在行政處分之上，結果造成行政處分概念之擴大，從而有所謂「形式行政處分」(formeller Verwaltungsakt)¹³⁴或「默示行政處分」¹³⁵等概念的提出。

按直接強制之實施，係對人民依據基礎處分所應履行之義務，新增額外之不利益，向無爭議。而在此一階段（直接強制）之執行程序，需要額外之權利救濟，亦屬至明。民事強制執执行程序之聲明

132 德國二次戰前，即採此制，例如普魯士警察行政法第57條即規定，行政強制程序中所有之行為，均不得提起行政訴訟。參照PrOVGE 66, 341 (347)。

133 德國二次戰前，即採此制。二次戰後初期，雖引進行政審判權「概括條款」，但因規定不明，加上觀念尚未普及，故一度仍認為行政訴訟以行政處分存在為前提。直至1960年，行政法院法(VwGO)頒行之後，始確立行政訴訟審判權之範圍及於所有行政法上之爭議，不以行政處分為限。

134 參見 Christian-Friedrich Menger, System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes, 1954, S. 106.

135 參見 Ernst Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 9. Aufl., 1966, S. 191. 此一概念又可追溯至威瑪憲法時期公法學者 Walter Jellinek 所提出之「事實上行政處分」(realer Verwaltungsakt)概念，參見 Walter Jellinek, Verwaltungsrecht, 3. Aufl., 1948, S. 258.

異議制度¹³⁶，其旨亦在此。反觀在行政執执行程序方面，其救濟體系的發展確實較為遲緩、落後。然隨著法治觀念之普及與行政訴訟制度之改革，以上因素已逐漸不復存在。臺灣起自1999年的行政法制興革，循序修改行政訴訟法、行政執行法，在行政訴訟法中改採審判權概括條款（行政訴訟法第2條），於行政執行法中，仿襲強制執行法第12條規定，增訂聲明異議救濟制度（行政執行法第9條），照理行政執行行為自始應受到行政法院之審查。孰料行政法院作出「違反法律」（*contra legem*）之解釋，硬生生地將行政執行法第9條規定解釋為立法者有意排除行政執行受行政法院救濟¹³⁷，令人遺憾¹³⁸。總之，衡諸當前法治思想與法制規範，以事實行為不受司法救濟保障為由，將直接強制認定為行政處分之說法，已未合時宜。較值考量者，乃執行措施若已執行完畢，能否提起違法確認訴訟之問題，此乃涉及「如何」救濟之問題。

關於「如何」救濟之問題，主要涉及應循何種訴訟種類及程序，謀求救濟。按現行行政訴訟制度雖採審判權概括主義，惟訴訟種類之制度設計，原則上是以行政行為之態樣為準，並設有不同之程序合法要件。大體而言，針對行政機關所為之行政處分，依行政處分之效力是否存在，可分為撤銷訴訟（行政訴訟法第4條）、行政處分無效確認訴訟（行政訴訟法第6條第1項前段）及行政處分違法確認訴訟（行政訴訟法第6條第1項後段）；針對行政處分以外之行為，尤其是行政事實行為，則是設有一般給付訴訟（行政訴訟法第8條第1項）。行政執行行為若被定性為行政事實行為，人民對之若

136 參見強制執行法第12條規定：「當事人或利害關係人，對於執行法院強制執行之命令，或對於執行法官、書記官、執達員實施強制執行之方法，強制執行時應遵守之程序，或其他侵害利益之情事，得於強制执行程序終結前，為聲請或聲明異議。但強制執行不因而停止。前項聲請及聲明異議，由執行法院裁定之。不服前項裁定者，得為抗告。」

137 參見高雄高等行政法院91年訴度字第783號裁定、臺北高等行政法院91年度訴字第4427、4533號裁定。

138 所幸最高行政法院已透過（97年12月份第3次庭長法官聯席會議）決議改變見解。參見本文「肆、三」。

有不服，自得提起一般給付訴訟，謀求救濟。惟究諸實際，人民對於行政執行行為提起行政訴訟之時，往往已執行完畢，同時發生該行政行為「已解決」或「消滅」(erledigt)之結果，於此情形，自無法再提起一般給付訴訟，以除去侵害，唯僅能確認該行為違法。不過，現行之行政訴訟種類中，僅有針對「行政處分」之違法確認訴訟，因而引發究應「類推適用」行政訴訟法第6條第1項後段之行政處分違法確認訴訟，抑或直接適用行政訴訟法第6條第1項前段之「行政法律關係不存在(不成立)訴訟」之疑義¹³⁹。惟從人民權利保障之觀點，無論如何皆應給予人民提起訴訟之機會。

設若直接強制之性質與行政救濟制度並無必然關連，則其定性問題自然要回歸基本面，從其行為內涵出發。按單就直接強制行為(或代履行之實施行為)以觀，例如以警棍驅散群眾或將汽車拖離現場以觀，應純屬「物理性之行為」，而為行政上之事實行為。惟若仔細審視，該措施之實施尚含有課予負解散義務之人民或汽車駕駛人「容忍」之義務，亦即，對於強制措施之實施負有不得抗拒、阻礙之義務，就此而言，不失為具有規制性之行政處分。更精確言之，直接強制(或代履行措施)合「實施行為」(物理行為)與「課予容忍義務」(規制行為)於一身。準此，人民對於直接強制(或代履行措施)如有不服，自得對上開行為依其性質提起行政爭訟，亦即辨明不服之對象，提出不服之理由。

4. 即時強制之實施

於即時強制之情形，不僅未經行政處分對於人民之義務為事前之確認，且在程序上亦省卻具有心理上強制之告戒與強制方法之確認，可謂是對人民權利干預最為強烈者，基於法治國原則及人民基

¹³⁹ 在德國主張執行行為屬於事實行為之學者，有主張於此情形應提起「確認行政法律關係不存在之訴」，其爭訟標的為過去所存在之法律關係。參見Renck (Fn. 7), S. 115 ff., 117 f.; Drews/Wacke/Vogel/Martens (Fn. 92), S. 217.

本權利之保障，即時強制必須是一種最後手段（*ultima ratio*）¹⁴⁰。從行政執行之程序構造以觀，即時強制係行政機關直接進入動用強制手段之階段，故即時強制同於「強制方法之實施」。學說上有主張，即時強制含有一種「以行為表現於外部之默示基礎處分」（*eine konkludente, durch die Tat ausgedrückte Grundverfügung*）¹⁴¹。惟亦有主張僅是行政上事實行為¹⁴²。

按行政機關在排除危險時，若因義務人不明或不在現場，而有立即採取措施之必要者，該行為（措施）無法被認定為默示之行政處分。蓋該行為（措施）無法送達相對人或使相對人知悉，而未能發生效力（參照行政程序法第110條第1項）¹⁴³。於此情況下，無論如何，行政處分之作成，在時間上，恆隨之於動用強制措施之後，甚且是一種「無相對人之行政處分」（*adressatlose Verwaltungsakte*）¹⁴⁴，亦即，行政處分之相對人尚未可知，故先作成一暫時性之規制措施，至於其內容（相對人）則留待具體化¹⁴⁵。必俟此種行政處分於相對人知悉該處分之時，始生效力。

不過，有學者批評，此種概念上之建構方式，亦可用於義務人

¹⁴⁰ Otto Mayer (Fn. 35), S. 289.

¹⁴¹ Drews/Wacke/Vogel/Martens (Fn. 92), S. 439, 530 f.; Karl Friedhelm Friauf, Polizei- und Ordnungsrecht, in: von Münch/Badura (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 9. Aufl., 1992, S. 173 Rn. 195.

¹⁴² 參見BayVG, BayVBl. 1981, 597 ff.; VGH Kassel, NVwZ 1987, 904 (907); Drews/Wacke/Vogel/Martens, (Fn. 92), S. 217; Klaus Hormann, Die Anwendung von Verwaltungszwang unter Abweichung vom Regelvollstreckungsverfahren, 1988, S. 168; 不同見解Peter Schäfer, Zur Rechtsnatur der unmittelbaren Ausführung nach Art. 9 Abs. 1 PAG – Verwaltungsakt oder Realakt?, BayVBl. 1989, S. 742 (742 ff.); Ernst Rasch, Der Realakt insbesondere im Polizeirecht, DVBl. 1992, S. 207 (210).

¹⁴³ 另參Wassilios Skouris, Die amtliche Bekanntgabe als Wirksamkeitsvoraussetzung empfangsbedürftiger Verwaltungsakte, VerwArch 65 (1974), S. 264 (277 ff.); OVG Hamburg, NJW 1992, 1909.

¹⁴⁴ Ferdinand O. Kopp/Ulrich Ramsauer (2010), Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 11. Aufl., 2010, § 35 Rn. 36 b.

¹⁴⁵ Eyermann/Fröhler (Fn. 59), § 42 Rn. 13; DÖV 1969, 396; OVG Münster, DVBl. 1973, 924 (925); Schäfer (Fn. 142), S. 742 ff.

在場之情形¹⁴⁶。例如：警察在某一存有易燃物之區域，見某甲正在抽煙。隨即奪下甲之香菸，並立即踩熄。另一種情形是，警察見一違規停車堵住交通要道，因車上無人，隨即命人將之拖走¹⁴⁷。此二種情形，均未給予義務人有自願履行之機會，隨即動用強制手段。上述情況，唯一之行政處分存在於事後所為之（代履行）費用給付處分。至於法律所定，執行機關於採取強制措施後，應立即通知義務人，則僅是一種觀念通知（單純告知），而非一種事後所為之「確認處分」（*ein feststellender Verwaltungsakt*），亦即對於所採取措施之必要性及其內容，對於義務人為具有拘束性之確認¹⁴⁸。

本文認為，即時強制之法律性質，須視義務人是否在場而定。若義務人在場，則應同於前開直接強制及代履行之性質，亦即兼有物理行為及規制作用；反之，若義務人不在場，則應屬事實行為。以汽車拖吊為例，於違規停車之汽車駕駛人不在車內之情形，由於交通執法人員無從對之作成「責令移至適當場所」之行政處分，即逕予拖離。又因汽車駕駛人於實施拖吊行為時，不在現場，故亦無課其容忍義務之可能及必要。由於行政處分須送達於相對人或使其知悉，始生效力，於本處即時強制之情形，因相對人尚不明確，無從送達，故將其定性為事實行為¹⁴⁹，似較妥適¹⁵⁰。

146 Maurer (Fn. 45), § 20 Rn. 26; Wolf-Rüdiger Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 1995, S. 321 ff.; Johannes Dietlein, Verwaltungszwang gegen Unbekannte, NWVBl. 1991, S. 81 (81 ff.).

147 VBH Kassel, NVwZ 1987, 904 (907).

148 Pietzner (Fn. 9), S. 266; Schenke (Fn. 146), Rn. 202; Engelhardt/App (Fn. 14), § 6 Anm. III 4; Dietlein (Fn. 146), S. 83 ff.; 不同見解 Volkmar Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 14. Aufl., 2008, Rn. 301; Martin Oldiges, Kostenerstattung einer Gemeinde für polizeiliche Gefahrenabwehr, JuS 1989, S. 616 (619).

149 或謂：在汽車拖吊實務上，透過掌上型電腦（PDA）已能掌握車主資料，而通常不僅會先有十分鐘之間歇性廣播示警（告誡可能在附近之義務人），且於實施拖吊前亦會在地上書寫被拖吊車輛號碼與即將置放之地點等，似已經該當於行政程序法第100條第1項後段之送達。惟查上開事實是否該當於行政程序法第100條第1項後段「送達」之要件，端視「地上書寫被拖吊車輛號碼與即將置放之地點」是否為行政處分？由此此處涉及之基礎處分的規制內涵係

雖然如此，於此仍要特別指出，即時強制雖未經主管機關事前作成行政處分，即逕予執行，惟就人民是否負有行為或不行為義務乙節，仍在主管機關「原本」應作成行政處分之範疇內。換言之，即時強制之行為實隱含有「原本應作而未作之行政處分（基礎處分）」。¹⁵⁰此點之強調，於權利救濟上殊具重要性，蓋即時強制合法性之審查，亦即關於行政機關能否為即時強制乙節，所應審究者，乃其是否符合「原本應作而未作之行政處分」之法定要件。換言之，主管機關若不得為該行政處分，即亦不得為該即時強制。以汽車拖吊措施為例，當汽車駕駛人不在車內，而其車遭交通執法人員拖吊時，其所得爭執者，非僅拖吊行為本身（例如拖吊方式致汽車受損），尚包括執法人員能否「責令其移置適當場所」（基礎處分），系爭拖吊行為若不合乎法定責令移置適當場所之要件，則該拖吊行為即構成違法。

5. 小結

各別之執行措施若有違反應遵守之程序規定，或違反實施強制方法之要件者，例如查封不得查封之物，或告戒之內容不合比例原則，或基礎處分有無效之原因或經行政法院裁定停止執行而仍為執行者，義務人或利害關係人得於執行程序終結前，向執行機關聲明異議（行政執行法第9條第1項）。對於聲明異議之決定，如有不服

「命駕駛人駛離之義務」（行為義務），然「地上書寫被拖吊車輛號碼與即將置放之地點」並無此規制內涵，蓋車已拖離，無所謂「命駕駛人駛離之義務」之行政處分之存在，至多只是告知系爭車輛已被移置的事實，故無以認定其為行政處分，從而亦無行政程序法第100條第1項後段「送達」規定之適用。

150 作者曾因舊行政訴訟制度僅有以行政處分為程序標的之撤銷訴訟，基於人民權利救濟之考量，而將（義務人不在場之）即時強制解為行政處分，參見李建良，違規車輛拖吊及保管之法律問題——兼論行政強制執行基本體系之再構成及其相關問題，政大法學評論，53期，頁135-136（1995年）。目前行政訴訟制度已作大幅修正，「非行政處分，無行政救濟」之時代已經過去，上述見解自無維持之必要，爰予變更。不同見解，參見許宗力（註98），頁554。

者，得提起行政訴訟，謀求救濟。

行政執行之措施若具有行政處分之性質¹⁵¹，義務人或利害關係人，於聲明異議仍未獲救濟者，得提起撤銷訴訟¹⁵²，例如，於金錢給付義務之執行，執行機關人員對義務人之財產所為之查封措施，即屬之¹⁵³；又如告戒及執行方法之確定，亦屬之¹⁵⁴。執行措施若屬事實行為，原則上提起一般給付訴訟救濟之，例如即時強制。惟若已經執行完畢，且已消滅者，則應改提確認訴訟（參見後述）。

五、第三人之權利救濟問題

行政強制執行之實施，若侵害（基礎處分規範效力以外之）第

151 行政執行之措施是否具有行政處分之性質，非無爭議，學說及實務上容或有不同見解，誠可理解，本文之見是否允切，亦待考驗，更不待言。惟無論如何，「基礎處分所課予之義務」與「執行措施所課予之義務」的觀念區辨，則屬行政執行法的基本觀念，不容混淆。換言之，「基礎處分傳達行止的誠命」與「執行手段課予人民之義務」指涉內涵不同，非可混同視之。為期建立正確之觀念，茲再以三例說明之，例一：主管機關命特定工廠停工，該工廠不予遵從，主管機關連續科處怠金強制之。命停工處分（基礎處分）傳達的誠命是「不作為義務」（不得動工）；執行手段（怠金）課予的是公法上金錢給付義務。例二：主管機關命甲清除其所棄置的廢土，甲未從，主管機關委請第三人代為清除，並向甲收取代履行費用。命清除廢土處分（基礎處分）傳達的誠命是「作為義務」（清除廢土）；執行手段（代履行）課予的是繳納代履行費用之公法上金錢給付義務。例三：主管機關命乙必須交付特定之文件資料，乙不從，主管機關強行進入乙之住處，進行搜索並取去該文件資料。命交付特定文件資料之處分（基礎處分）傳達的誠命是「作為義務」（交付特定文件資料）；執行手段（強行進入乙之住處，進行搜索並取去該文件資料）課予的是容忍義務（容忍主管機關進入住處、搜索及取去文件資料）。以上三例中，「基礎處分傳達行止的誠命」與「執行手段課予人民之義務」皆有不同，「基礎處分傳達行止的誠命」並不包含「執行手段課予人民之義務」，故於行政執行程序中有另以行政處分課予義務之必要。

152 依行政訴訟法第4條規定，除法律有特別規定外，提起撤銷訴訟須先經訴願程序。惟行政執行法第9條已設有聲明異議制度，此一規定應屬訴願法第1條第1項但書所稱「法律另有規定者，從其規定」之情形，故毋需再踐行訴願程序，即可提起撤銷訴訟。然此一見解似不為行政院所採。

153 另參見BVerwG, NJW 1961, 332 (333); BVerwGE 54, 314 (316); Maurer (Fn. 45), § 20 Rn. 11; App/Wettlaufer (Fn. 7), § 41 Rn. 6.

154 Erichsen/Rauschenberg (Fn. 80), S. 40.

三人之權利者，例如執行人員誤認第三人之財產為義務人之財產而予查封，或執行機關於執行拆除處分時，誤第三人之房屋為應拆除之房屋，或第三人就執行標的物有足以排除執行之權利等，應如何救濟？

按行政執行法施行細則第18條規定：「公法上金錢給付義務之執行事件，第三人就執行標的物認有足以排除執行之權利時，得於執行程序終結前，依強制執行法第十五條規定向管轄法院提起民事訴訟。」此一規定至少存有二項問題：一、其僅限於公法上金錢給付義務之執行事件，於行為、不行為義務之執行，應如何處理？二、其係依行政執行法第43條授權訂定之施行細則，是否足以作為第三人權利救濟之法源依據？

以上問題首要澄清者，乃因行政執行措施致第三人權利受有損害，究屬公法上之爭議，抑或私法上之爭議？按行政執行乃典型之公權力措施，具有公法性質，殆應無疑，則第三人之權利因執行措施而受有損害，亦應屬於公法上之爭議。例如上舉之執行人員誤認第三人之財產為義務人之財產而予查封，或執行機關於執行拆除處分時，誤第三人之房屋為應拆除之房屋等。較具爭議者，乃第三人就執行標的物有足以排除執行之權利，例如執行機關查封義務人之房屋，而第三人主張該房屋為其所有。於此情形，義務人與第三人之間存有發生系爭房屋之所有權誰屬之爭議。初觀之，此種爭議似為人民之間的私權糾紛，細究之，實仍為公法上之爭議。蓋造成第三人權利受到侵害，且為第三人所爭執者，乃執行機關之「查封」措施，而非義務人之行為，復因查封措施在性質上屬於公法行為，故此間（第三人與執行機關之間）所生之爭議應具有公法性質。至於義務人與第三人間之所有權爭議，則屬該查封措施是否違法之事由。

設若行政執行措施致第三人權利受有損害，屬公法上之爭議，

除法律別有規定外，應由行政法院審理之（行政訴訟法第2條）。是以，行政執行法施行細則第18條規定依強制執行法第15條規定向管轄法院提起民事訴訟，即有違反上開行政訴訟法規定之嫌。查行政執行法第26條規定：「關於本章之執行，除本法另有規定外，準用強制執行法之規定。」所謂「關於本章之執行」，即指公法上金錢給付義務之執行，故上開施行細則之規定，可視為行政執行法第26條規定之具體化，尚不生違背法律之問題。然由此可以反推：行為、不行為義務之執行事件，若第三人就執行標的物認有足以排除執行之權利者，應依行政訴訟法之規定，提起救濟¹⁵⁵。

六、執行完畢之權利救濟問題

行政執行已執行完畢，義務人或利害關係人若認為其權利因行政執行而受有侵害，應如何救濟？此一問題之處理，因義務人爭訟之標的為基礎處分，抑或執行行為而有不同。如前所述，基礎處分的作成與執行行為的實施，在程序構造上，乃分屬兩個不同的階段，雖互有關聯，但法律依據及程序要求實則各異。此種情形於行政執行完畢後，亦無改變，其所生之行政爭訟問題，自應加以區別，尤須注意二者之違法問題原則上並無必然之牽連關係。質言之，行政機關於執行階段之違法情事，對於基礎處分之合法性原則上不生影響。執行階段若發生「執行障礙」之情形，例如行政法院作成停止執行之裁定，或義務人自動履行，或客觀上無執行之可能者，皆不影響基礎處分之合法性。反之，基礎處分之違法性亦不當然構成執行行為之違法，行政執行之違法可能出於與基礎處分無關

¹⁵⁵ 德國邦行政執行法中，有直接規定準用民事訴訟法第771條有關第三人異議之訴規定者，亦有設有與民事訴訟法第771條相同之規定，於此情形，即由普通法院審理之。未有前揭之規定者，則由行政法院審理之。參見BGH, DÖV 1960, 597; Harald Kreiling, Rechtsbehelfe gegen Beitreibungsmaßnahmen im Verwaltungsvollstreckungsrecht, NJW 1963, 888 (890); App/Wettlaufer (Fn. 7), § 40 Rn. 9; Rudolph (Fn. 84), S. 115; Engelhardt/App (Fn. 14), Ahn. § 262 Anm. 6; Traulsen (Fn. 84), S. 72, 146 ff.; Erichsen/Rauschenberg (Fn. 80), S. 323 ff.

之獨立因素。例如執行機關選用不合比例之執行方法。不過，由於基礎處分為行政執行之執行名義，對於整個行政執行階段，具有「構成要件效力」，從行政訴訟之角度以言，已執行完畢之基礎處分對於執行行為是否全無影響？尤其，已執行完畢之基礎處分是否仍有撤銷之實益？值得探討，為學說與實務爭議之棘手課題，有待釐清，以下分論之¹⁵⁶。

（一）以「基礎處分」為爭訟標的之救濟問題

行政機關得作成行政處分，並以之為執行名義（基礎處分），採取強制執行之措施，不以該基礎處分是否合法為前提。行政處分具有之執行力所形成之法律狀態，對於人民而言，甚為不利。蓋下命處分課予人民一定之公法上義務，於其生效後，即使處分相對人（義務人）處於隨時可能被行政強制之狀態。基於法治國家權利保障之意旨，應給予人民對基礎處分尋求救濟之機會，尤其在進入執行階段之後¹⁵⁷。處分相對人若要阻止因基礎處分之生效所產生之法律上及事實上的不利效應，須主動出擊，提出撤銷訴願及訴訟，以防止基礎處分產生形式確定力，並進一步除去基礎處分之效力¹⁵⁸。

156 行政執行已執行完畢所涉及的救濟問題，基本上有兩種爭訟的面向，一是以基礎處分本身為程序標的之救濟問題；另一是針對執行階段之各種執行措施所生之權利救濟問題。就後者而言，屬於行政執行之救濟體系必須處理的問題，否則無以建構無漏洞的權利救濟體系。蓋諸多執行措施一旦執行完畢，若不予人民救濟之機會，將形成權利救濟之重大漏洞，其對人民權利之侵害有時尤甚於基礎處分。例如採取搜身、警械、管束等方法作為執行手段，其對人民身體權、隱私權、人身自由之侵害甚鉅，應給予人民救濟之機會，故有探討其救濟方法及程序之必要。其次，以基礎處分本身為程序標的之救濟問題，表面觀之，似非屬行政執行救濟的一環。實則細心思考，至少有二端與行政執行關係密切：一、基礎處分是否消滅與行政執行的方法具有互動關聯；二、由此延伸出，基礎處分能否撤銷或僅能違法確認，對於執行措施合法性之爭執的關聯性。確切的說，基礎處分若得予撤銷，則以基礎處分為基礎的執行方法即構成違法，而得予救濟之。是以，此部分與「行政執行的救濟」本身的關聯性，與其說是相當密切，不如說是異常微妙，非識者不能察覺。

157 參見Dieter Lorenz, Die Folgepflicht gegenüber rechtswidrigen Verwaltungsakten und die Strafbarkeit des Ungehorsams, DVBl. 1971, S. 165 (167).

158 撤銷判決乃屬一種「形成判決」，足以直接除去行政處分之效力。

行政法院若判決撤銷基礎處分，即產生「溯及」(ex tunc)之效力¹⁵⁹，而使業已實施或進行中之強制執行行為或措施失所附麗，而構成違法¹⁶⁰，從而在行政爭訟程序中，處分相對人尚得請求行政法院為命行政機關回復原狀之判決，此即所謂「執行結果除去請求權」。唯有如此，始能平衡行政機關得以行政處分為執行名義實施強制執行而對人民所生的不利處境。

由於訴願及撤銷訴訟之提起，並不當然發生行政處分停止執行之效力，故基礎處分於行政爭訟程序中執行完畢者，所在多有。於此情形，處分相對人原則上仍得提起或續行訴願及撤銷訴訟。行政處分之效力並不當然因執行完畢而歸於消滅¹⁶¹（學理上稱為「解消」或「解決」¹⁶²），從而得為撤銷訴訟之程序標的。行政訴訟法第196條第1項規定：「行政處分已執行者，行政法院為撤銷行政處分判決時，經原告聲請，並認為適當者，得於判決中命行政機關為回復原狀之必要處置。」其旨在此，可資佐證。

¹⁵⁹ 除非行政法院認定行政處分違法，但作成情況判決。

¹⁶⁰ 參見Walter Schmitt Glaeser/Hans-Detlef Horn, Verwaltungsprozeßrecht, 16. Aufl., 2012, Rn. 257; Hans-Günter Henneke, Verwaltungszwang mittels Zwangsgeld, Jura 1989, S. 7 (13).

¹⁶¹ 此為德國學說及實務之多數見解，參見VGH BW, DÖV 1984, 517 (520); NVwZ 1993, 1014; BayVGH, NVwZ-RR 1994, 548; Eyermann/Fröhler (Fn. 59), § 113 Rn. 39; Michael Gerhardt, in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner (Hrsg.), VwGO, Kommentar, 22. Ergänzungslieferung, 2011, § 113 Rn. 88; Friedrich Schoch, in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner (Hrsg.), VwGO, Kommentar, 22. Ergänzungslieferung, 2011, § 80 Rn. 337.

¹⁶² 參見蔡宗珍，公法上無主義務之強制執行？——評司法院大法官釋字第621號解釋，中研院法學期刊，2期，頁290（2008年）（特別是註9所列之各種用語）。此一用語係逕譯自德國學理及實務之概念„erledigt“或„Erledigung“。依德國實務及學說之見解，行政處分是否消滅，須視該行政處分之（不利負擔）規制效力是否喪失（Wegfall der beschwerenden Regelung）而定。參見BVerwGE 34, 324 (325); 73, 312 (314); Gerhardt (Fn. 161), § 113 Rn. 81 ff. 行政處分消滅之原因多端（參見李建良，行政處分的「解決」與行政救濟途徑的擇定，台灣本土法學雜誌，40期，頁105以下（2002年）），本文僅探討行政處分是否因執行完畢而消滅（解決）之問題，特此指明。

行政處分之效力不因執行完畢而當然消滅，並不表示行政處分不會因執行完畢而消滅，行政處分已執行甚至是行政處分消滅的重要徵象之一。是以，行政處分執行完畢者，於何種情形其效力消滅，爰成為行政處分是否消滅最為棘手的課題¹⁶³。

現行行政訴訟法第6條第1項後段規定：「行政處分……已執行而無回復原狀可能之行政處分……，亦同（按：亦得提起確認行政處分違法之訴）。¹⁶⁴」由此可知，行政處分已執行而無回復原狀可能者，即告消滅¹⁶⁵，無撤銷之實益¹⁶⁶，僅得對之提起行政處分違法確認之訴。處分相對人若已依法提起訴願或撤銷訴訟者，則應為訴之轉換，續行行政處分違法確認之訴¹⁶⁷。現行法以「有無回復原狀可能」作為判斷行政處分是否消滅之準據¹⁶⁸，較之舊法明確，自有助於個案之認定。然如何解釋、適用行政訴訟法第6條第1項後段之規定？何謂「無回復原狀可能」？仍非清楚。換言之，行政處分執行完畢是否「消滅」（解消）之學理爭議，並不因法有明文而自動解消，容有探究闡明之必要。就此，大抵有兩種切入的角度，一

163 行政處分是否消滅（解消），同時是行政實體法與行政訴訟法交錯夾纏、互為影響的典型問題之一。

164 此項規定係於2010年1月13日修正公布，立法理由：「行政處分已執行與行政處分消滅不同，依第一百九十六條規定之意旨，已執行之行政處分，如有回復原狀之可能，仍可提起撤銷訴訟，原第一項後段規定『確認已執行完畢或因其他事由而消滅之行政處分為違法之訴訟』，易滋行政處分已執行亦屬消滅之事由，且均得提起確認訴訟之誤會，爰予修正，期臻明確。」

165 德國實務與學說，參見BVerwGE 26, 161 (163 ff.); Eyermann/Fröhler (Fn. 59), § 113 Rn. 39; Bernd Wegmann, Rechtsschutzprobleme im Bayerischen Polizeirecht, BayVBl. 1985, S. 417 (417).

166 撤銷訴訟乃是一種「排除（國家）干預之訴訟」（Störungsbeseitigungsklage），旨在防禦持續存在中之違法干預，故行政處分之不利規制效力若已不存在，即無提起撤銷訴訟之實益。參見Gerhardt (Fn. 161), § 113 Rn. 81.

167 參見行政訴訟法第196條第2項。

168 此項立法例係採納德國通說之見解。參見BVerwGE 26, 161 (163 ff.); BayVGh, NVwZ-RR 1994, 548; Eyermann/Fröhler (Fn. 59), § 113 Rn. 39; Gerhardt (Fn. 161), § 113 Rn. 88; Pietzner Rainer/Ronellenfisch Michael, Das Assessorexamen im Öffentlichen Recht, 8. Aufl., 1993, § 27 III 3 Rn. 24.

是單點著眼於行政處分的規制內涵本身；另一是整體觀照行政處分規制效力的衍生後果。

以公法上金錢給付義務為規制內涵之行政處分，於義務人自動履行或受強制執行後，對於所生財產上之損害（或財產變動狀態）均得以回復原狀，故此類處分縱使執行完畢，通常不生行政處分消滅之問題，於學說與實務向無爭議，亦屬行政訴訟法第196條規定的典型適用案型。較具爭議者，乃本文所探討之課予行為、不行為及容忍義務之行政處分的執行問題。基本上，此一問題無法作全有全無之一概而論，而應區別情況，分別探討之。

首先，可以延伸公法上金錢給付義務之行政處分的思維，課予行為、不行為及容忍義務之行政處分執行後所生之權利變動狀態，於行政處分撤銷後，若得還原至執行前之權利狀態者，尤其該行政處分形成權利限制之持續狀態，且該行政處分之存在，構成該執行狀態的法律上基礎者，不問是由義務人自動履行或受強制執行，該基礎處分不因執行完畢而消滅，最典型的例子是「沒入」處分之執行。沒入處分以剝奪人民特定動產之所有權為規制內涵（形成效力），然此項規制效力並非於沒入處分生效時即已發生，須俟處分機關解除所有人之占有始生所有權移轉之效力，故沒入處分同時課予相對人容忍處分機關解除占有應沒入物之義務（課予容忍義務之下命處分）。沒入處分執行後，該處分為國家取得該物所有權之法律上基礎，其效力不因執行完畢而消滅，故原所有人權若要取回被沒入物，必須針對沒入處分依法提起撤銷訴訟，於獲得勝訴後，始得請求返還被沒入物。不過，被沒入物若因銷毀或拍賣而不存在者，該沒入處分即因無回復原狀之可能而消滅¹⁶⁹。

¹⁶⁹ 至於義務人得透過加價買回被拍賣物，仍非屬已執行而得予回復原狀之情形。蓋此處所謂「能否回復原狀」，係指能否透過撤銷訴訟之救濟程序而回復原狀。反之，加價買回被拍賣物與行政救濟無直接關聯，當事人隨時得加價買回系爭被拍賣物，未必需要提起行政救濟，故非屬已執行而得予回復原狀之情形。

相對於上，課予行為、不行為及容忍義務之行政處分的規制內涵，若屬於一次性或一時性的義務，一旦執行即達規制目的，既不具持續效力，亦無後續之執行費用等衍生性義務，則此類行政處分經執行完畢，不問自動履行或強制執行，通常即無回復原狀之可能，行政處分之效力即告消滅。典型的例子是臨檢措施，如警察命汽車駕駛人停車接受檢查、出示證件或接受酒測等。此類處分一旦執行，目的即達，亦無回復原狀之可能（不可能回復至未受檢的狀態），義務人如欲爭執，僅能提起行政處分違法確認訴訟¹⁷⁰。又如：主管機關要求所有入境旅客均須於機場接受體溫量測，始得入

170 司法院釋字第535號解釋理由書謂：「對違法、逾越權限或濫用權力之臨檢行為，應於現行法律救濟機制內，提供訴訟救濟（包括賠償損害）之途徑：在法律未為完備之設計前，應許受臨檢人、利害關係人對執行臨檢之命令、方法、應遵守之程序或其他侵害利益情事，於臨檢程序終結前，向執行人員提出異議，認異議有理由者，在場執行人員中職位最高者應即為停止臨檢之決定，認其無理由者，得續行臨檢，經受臨檢人請求時，並應給予載明臨檢過程之書面。上開書面具有行政處分之性質，異議人得依法提起行政爭訟。」於此段闡釋中，大法官以「載明臨檢過程之書面」為行政處分為程序標的，允許人民得依法提起行政爭訟，對於落實憲法保障人民訴願及訴訟權之意旨，固有正面意義。然就行政程序構造及其相對應之訴訟問題的細膩論述，則有不足，尤其未清楚區分「基礎處分」與「執行行為」二階程序構造，僅以「執行臨檢之命令、方法、應遵守之程序或其他侵害利益情事」等語，含糊其詞，籠統帶過。實則，在觀念上，臨檢措施應區分「命接受檢查」（基礎處分）與「實施檢查」（執行行為）二種階段。於受臨檢人遵行受檢之情形，並無行政強制之問題，僅是「命接受檢查」（基礎處分）之執行；於受臨檢人抗拒不從時，始有以強制方法（通常是直接強制）執行「命接受檢查」（基礎處分）之必要。惟無論何種情形，「命接受檢查」（基礎處分）均因執行完畢而消滅，人民若對此（基礎處分）表示不服，則僅能直接提起行政處分違法確認訴訟，而無從循序提起訴願、撤銷訴訟之所謂「依法提起行政爭訟」可言。

司法院釋字第535號解釋理由書上開闡述，目前已明定於警察職權行使法第29條：「義務人或利害關係人對警察依本法行使職權之方法、應遵守之程序或其他侵害利益之情事，得於警察行使職權時，當場陳述理由，表示異議。前項異議，警察認為有理由者，應立即停止或更正執行行為；認為無理由者，得繼續執行，經義務人或利害關係人請求時，應將異議之理由製作紀錄交付之。義務人或利害關係人因警察行使職權有違法或不當情事，致損害其權益者，得依法提起訴願及行政訴訟。」其中所稱「依法提起訴願及行政訴訟」，於適用上即須區分「基礎處分」與「執行行為」二種階段，且須注意該基礎處分是否已因執行完畢而消滅。

境。此一課予容忍義務之行政處分，一經執行（不問自動履行或強制執行），其目的即已達成，且無回復原狀之可能，受檢人對於「命接受體溫量測」（基礎處分）若有不服，僅能提起行政處分違法確認訴訟，謀求救濟。再如對於特定一次之集會遊行（以強制方法，如警棍、噴水）為驅散措施，其基礎處分（命解散處分）之效力亦歸於消滅¹⁷¹。

介於前述二者之間，較為複雜棘手的案型是，課予行為、不行為及容忍義務之行政處分的規制內涵，並非只是單純一次性或一時性的義務，其規制目的之達成（執行完畢），或具有持續性效力，或亦可能產生後續之執行費用等衍生性義務，此類行政處分經執行完畢後，行政處分之效力是否即告消滅，或其執行結果有無回復原狀之可能，非無疑問，此部分又因義務係經自動履行或強制執行，而有差別，試設例分述如下：

其一，主管機關以某業者違法開發為由，命其停止一切之開發行為（**命停工處分**）。此一下命處分所欲產生之停工規制狀態，具有持續性效力，不因義務人自動履行或受強制執行而喪失。該下命處分若未經撤銷或廢止，縱使系爭開發已處於停工狀態（執行完畢），其效力仍持續存在。換言之，該下命處分具有「不得復工」之規制效力¹⁷²。是以，該業者如有不服，仍應依法提起訴願及撤銷

¹⁷¹ 德國實務案例及見解，參見VGH BW, DVBl. 1987, 153 ff.

¹⁷² 近期引發爭議及討論的「美麗灣渡假村環評公民訴訟案」，原告（環保團體）起訴請求臺東縣政府應作成命美麗灣公司停止一切開發行為之行政處分。美麗灣公司以參加人身分參加訴訟，其提出的抗辯主張之一為：系爭開發案現已處於停工狀態，故原告無訴訟實益。就此主張，高雄高等行政法院96年度訴字第647號判決以：「參加人已停止在加路蘭段346-4地號土地上之一切開發施作工程行為，縱令屬實；然此乃屬參加人個人之行為，並非經被告依法強制命其停工，故參加人是否復工？何時復工？仍由參加人自由決定，則在被告就此部分命參加人停工之前，參加人隨時可以復工，並不受任何拘束」為由，認為原告仍有訴訟之實益。本件之訴訟類型為請求作成特定行政處分（命停工處分）之「課予義務訴訟」，雖與訴請撤銷命停工處分之訴訟不同，然上開法院見解仍足以作為命停工處分具有持續效力之佐證，不因義務人自

訴訟，以資救濟。

其二，於【思考案例】中，主管機關以甲未經許可擅自建築為由，限期命其拆除（命拆除處分）。此一課予拆除（行為）義務之下命處分所欲產生之規制狀態，係除去該無照興建之建築物。設若甲自動履行此一拆除義務，就行政處分之規制效力本身而言，目的已達，且該「特定」之建築物於拆除後亦無回復原狀之可能（重新興建乃另一建築物，而非「原來」之建築物），則系爭命拆除處分之效力即應於執行完畢（自動履行）而消滅。

其三，承上【思考案例】，設若甲不履行拆除義務，而由主管機關委託第三人代為履行，並向甲追繳代履行費用者。就此情形，若僅將焦點集中在基礎處分的規制效力本身，其與前述自動履行之情形，應無不同，基礎處分因標的物已無回復原狀之可能而歸於消滅。然則，吾人若將後續之執行措施及其所衍生之代履行費用給付義務，納入考量，則基礎（拆除）處分是否因執行完畢而歸於消滅，即非無探討之餘地。

於此須先指出者，依行政訴訟法第6條第1項後段規定提起之行政處分違法確認訴訟，行政法院所為之「確認判決」，僅具有「確認」系爭行政處分違法性的效力，並不足以除去行政處分之存續效力。換言之，行政法院縱使確認基礎處分違法，然作為執行名義之基礎處分仍屬「有效」，從而以此為基礎之所有行政執行行為亦皆屬「合法」。蓋如前所述，行政執行之發動，係以行政處分之「有效性」而非「合法性」為前提¹⁷³；基礎處分之「違法性」≠執行行

動履行或受強制執行而喪失其效力。關於「美麗灣渡假村環評公民訴訟案」之相關裁判分析，參見李建良，環評程序與行政訴訟：美麗灣渡假村環評案，台灣法學雜誌，176期，頁25-48（2011年）。

¹⁷³ 此種因程序構造所生之分立狀態，於公法上金錢給付義務之執行尤其明顯。於此情形，處分機關（例如課稅機關）與執行機關（例如法務部行政執行分署）分屬不同機關，處分機關移送強制執行後，執行機關基本上係以基礎處

為之「違法性」。因此，處分相對人或利害關係人若欲針對「執行行為」提起救濟，除非能提出執行行為之獨立不法事由，否則將因基礎處分「有效存在（縱使違法）」而無法主張執行行為之違法性，尤無可能藉由主張基礎處分違法而阻止後續或延伸之執行行為，例如代履行費用之執行。此種結果與憲法保障人民訴訟權之意旨，實不相符，亦無以契合行政執行須以行政處分為基礎的規範始意¹⁷⁴。況且，在行政處分發生形式確定力之前，其規制效力原本即僅具暫時性，該行政處分之合法性及有效性尚處於應受行政法院審查之狀態¹⁷⁵。設若行政處分一旦執行完畢，即可免去行政法院之審查，同時維持該處分的有效性及後續行政執行的合法性，則不僅不符行政救濟之制度本旨，亦將變相鼓勵行政機關儘速執行，以免去受法的控制。準此以言，若整體觀照行政處分規制效力的衍生後果，則倘行政執行之結果衍生其他之義務者，例如代履行費用給付義務，則基礎處分縱使執行完畢，其效力仍未消滅而得為撤銷訴訟之程序標的¹⁷⁶，以滿足人民權利救濟的完整需求。

於【思考案例】中，主管機關認為某房屋為違章建築，而命該建築物之所有人甲拆除之。甲不服，對該拆除處分提起行政爭訟。於行政訴訟中，主管機關如將建築物拆除，執行完畢，並命甲繳納

分（執行名義）之有效性為前提啟動執执行程序，執行機關無須也無權判斷基礎處分之合法性。

174 為填補此一權利救濟的漏洞，德國部分實務見解認為，處分相對人或利害關係人於基礎處分執行完畢前，如無提起行政訴訟之機會者，行政執行的合法性即依附於基礎處分之合法性。換言之，基礎處分若屬違法，縱未經撤銷，則同時即構成執行行為之違法性。參見VGH BW, DÖV 1984, 517 (520); NVwZ 1993, 1041. 此種見解與針對「即時強制」之救濟，同其旨趣。蓋即時強制之實施，係出於情況急迫而不及作成基礎處分。然理論上，該強制措施之實施仍須符合原本應作成、但不及作成之行政處分（基礎處分）之法定要件，故即時強制之（行政訴訟上）違法審查，其審查重點即應區分為二：一、審究（原本應作成、但不及作成）基礎處分之合法性；二、審究執行行為之合法性。基礎處分不合法，執行行為即構成違法。

175 參見Lemke (Fn. 8), S. 170 f.

176 參見Erichsen/Rauschenberg (Fn. 80), S. 323 ff.

拆除費用者，因拆除處分（基礎處分）為課徵拆除費用（代履行費用）之法律基礎，故拆除處分之規範效力仍應存在而未消滅，且有撤銷之實益（拆除處分經撤銷後，後續之執行行為即失所附麗，代履行費用之課徵處分亦構成違法，得予撤銷），得為撤銷訴訟之程序標的。

（二）以「執行行為」為爭訟標的之救濟問題

相對於以「基礎處分」為爭訟標的，義務人或利害關係人若主張於執行程序中行政機關所為之各種「執行行為」違法者，首先在觀念上不容混淆的問題是，此處所指「執行行為」違法，係出於執行階段所生之獨立事由，與前述因基礎處分之違法導致執行行為違法之情形不同。例如採取之執行方法違反比例原則，或执行程序有瑕疵等。

其次，須區辨執行行為之法律性質為行政處分，抑或事實行為。執行行為若屬行政處分，則須進一步審究該執行行為是否因執行完畢而消滅，而循撤銷訴訟或確認訴訟之途徑救濟之。例如不服課徵代履行費用之處分，應提起撤銷訴訟，如於訴訟中執行完畢者（自動繳納或強制追繳），即得聲請行政法院命主管機關為回復原狀之必要處置（返還已繳納之代履行費用）。反之，對於限制出境之處分不服者，於提起行政訴訟前或訴訟中，解除出境限制者，則僅能提起確認限制出境處分違法之訴。

執行行為若屬事實行為，由於事實行為不具規制效力，其一旦執行完畢，通常即告解消，除有違法結果而得對之提起一般給付訴訟請求排除外，就該事實行為本身而言，僅能訴請確認該行為違法，以資救濟。然因現行行政訴訟法並無「確認行政事實行為違法之訴」，解決之道，或可類推適用行政訴訟法第6條第1項後段行政處分違法訴訟之規定，並結合行政訴訟法第2條行政訴訟概括條款

之精神，創設「確認行政事實行為違法之訴」，以供運用¹⁷⁷。例如違規停車而汽車駕駛人不在車內，交通執法人員無從對之作成「責令移置適當場所」之行政處分，即逕予拖離。如前所述，本處之即時強制因相對人尚不明確，無從送達，其性質應屬事實行為。此種移置措施（拖吊措施）一經執行完畢，即告消滅，人民對之若有不服，即得提起確認訴訟，確認移置措施（拖吊措施）為違法¹⁷⁸。

除上述之行政爭訟救濟方法外，人民若因行政執行而受有損害者，尚得依國家賠償法之規定，請求損害賠償（行政執行法第10條），自不待言。

伍、綜合論述

行政強制執行之救濟制度，體系龐大，問題複雜，以簡馭繁，得有兩種挈領方法：

¹⁷⁷ 德國行政法院法亦無「確認行政事實行為違法之訴」之明文，故對於已消滅之事實行為，究應如何救濟，實務及學說頗多爭議，有認為應類推適用（續行）違法確認訴訟者，例如：BayVG, NVwZ-RR, 1991, 519; Schmidt (Fn. 59), § 113 Rn. 106; Gerhard (Fn. 161), § 113 Rn. 107; Konrad Redeker/Hans-Joachim von Oertzen, Verwaltungsgerichtsordnung/Kommentar, 5. Aufl., 1975, § 113 Rn. 36; Friedhelm Hufen, Verwaltungsprozessrecht, 7. Aufl., 2008, § 18 Rn. 66 f.; Götz (Fn. 148), Rn. 869. 另有主張應直接適用行政法院法第43條第1項提起「一般確認訴訟」（即確認行政法上關係存在或不存在之訴）者，例如OVG NW, NJW 1994, 1673; VGH BW, DVBl. 1995, 367; OVG Hamburg, NVwZ-RR 1995, 1135 (1136); Hans-Uwe Erichsen, Die Fortsetzungsfeststellungsklage, Jura 1989, S. 49 (52); Kopp/Schenke (Fn. 84), § 113 Rn. 48; Pietzner/Ronellenfitsch (Fn. 168), § 11 Rn. 9; Wolf-Rüdiger Schenke, Die Fortsetzungsfeststellungsklage, in: Erichsen/Hoppe/Mutius (Hrsg.), System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes: Festschrift für Christian-Friedrich Menger zum 70. Geburtstag, 1985, S. 461 (474); Wolf-Rüdiger Schenke, Rechtsprechungsübersicht zum Verwaltungsprozeß – Teil 3, JZ 1996, S. 1103 (1109); Jochen Rozek, Grundfälle zur verwaltungsgerichtlichen Fortsetzungsfeststellungsklage, JuS 1995, S. 414 (416).

¹⁷⁸ 人民亦得以移置費（拖吊費）繳納單（行政處分）為程序標的，提起撤銷訴訟，並於訴訟中主張移置行為（拖吊行為）違法。

其一，掌握行政執行程序構造，依「告戒」、「執行方法之確定」、「執行方法之實施」的遞進階段，分別判斷各該執行行為之法律性質，據以決定在「聲明異議」之後的行政訴訟類型；再針對執行完畢之情形，以基礎處分是否消滅，判定訴訟類型是否應轉換為「違法確認訴訟」（參見【附圖六】）。

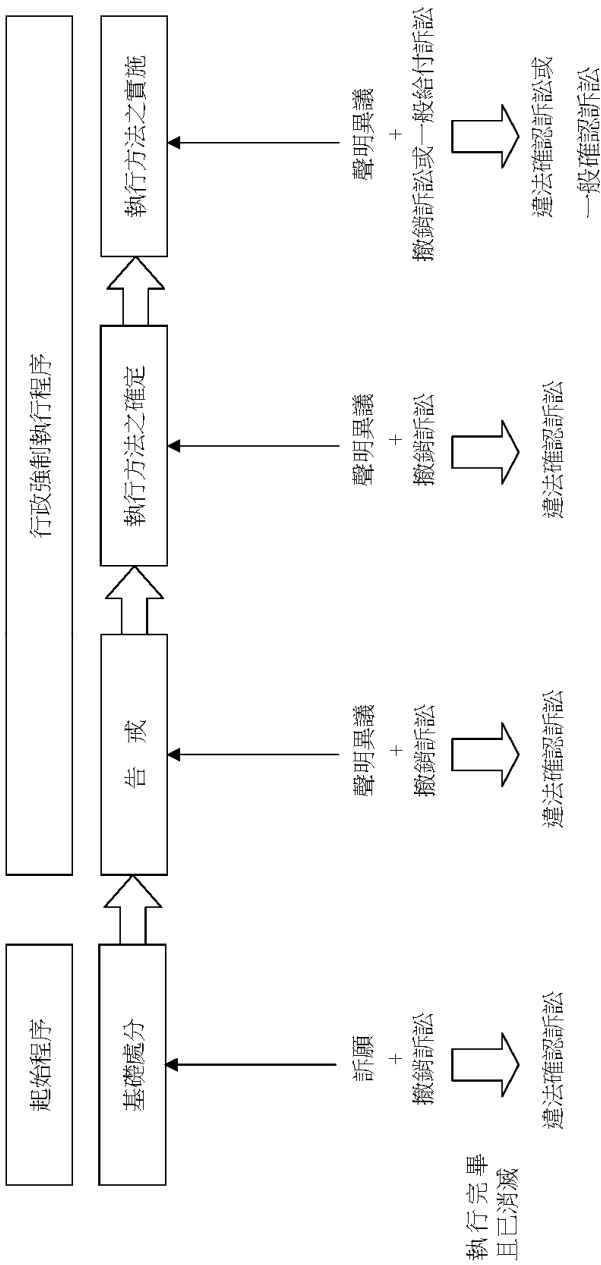
其二，以「救濟客體」（不服什麼？）、「救濟理由」（為何不服？）、「救濟方法」（如何救濟？）三個問題意識與概念要項，統整歸納出行政執行之救濟體系（參見【附圖七】）：

一、不服的標的，可能是針對基礎處分（執行名義）或執行行為。

二、若是針對基礎處分（執行名義），不服的理由可能是：執行名義違法、依據的事實或法律有變更，或義務已經履行完畢；若是針對執行行為，則不服的理由可能是根本的質疑行政執行的容許性，例如義務之履行經證明已無可能（能否執行之救濟），或者是指摘各別執行措施有違法之處（各別執行措施之救濟），抑或涉及第三人之權利侵害問題（第三人之權利救濟）。

三、救濟方法的選定，由於現行行政爭訟制度之架構，基本上係建立在行政行為法律性質的定性上，故除基礎處分應循撤銷訴訟程序救濟外，執行行為之救濟途徑，須先究明其法律性質，始能據以決定其訴訟類型。

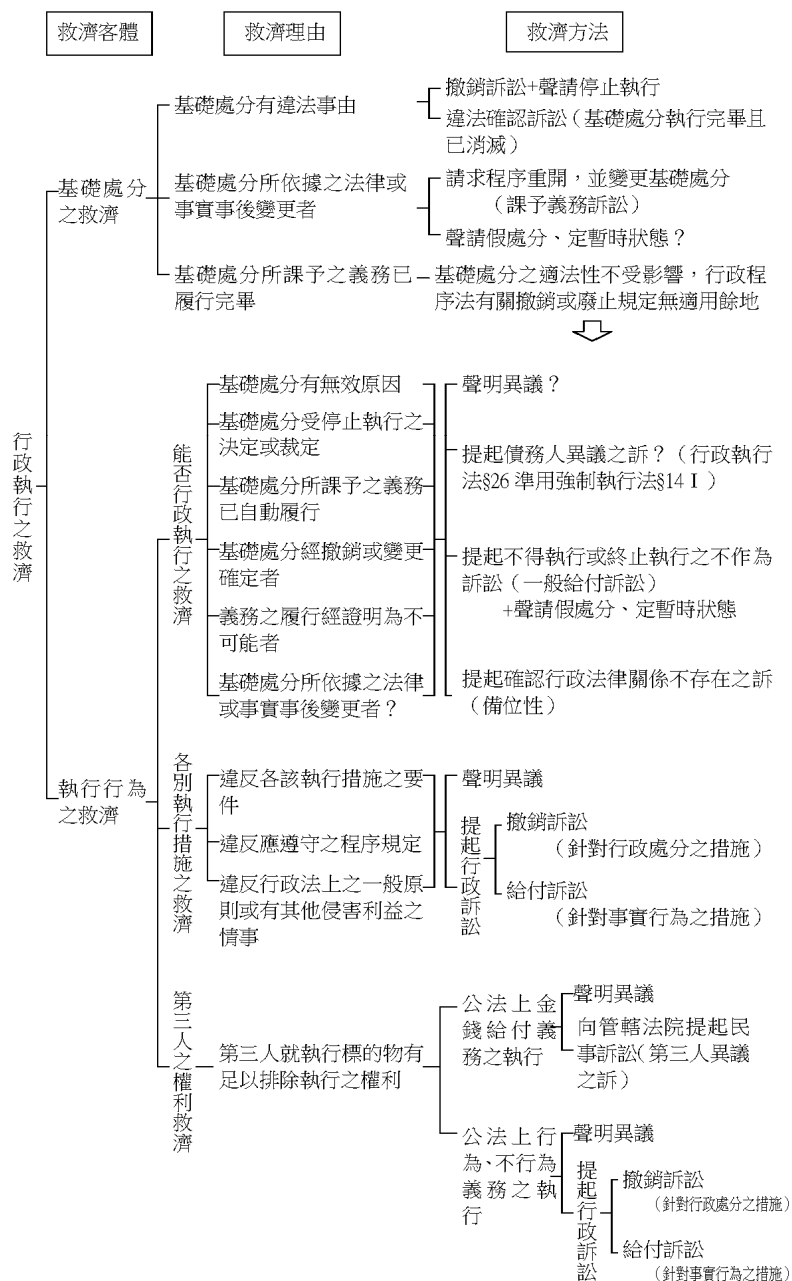
【附圖六】



行政執行之救濟體系（一）

【附圖七】

行政執行之救濟體系（二）



經由以上的挈領，最後綜合整理本文之研究所得，簡述如下，以供參考：

一、行政執行，係指行政機關對於不履行公法上義務之人（義務人），以強制手段促使其履行義務，或產生與義務已予履行相同之狀態。行政執执行程序，係接續於通常行政程序之後。經由行政程序之進行，行政處分將國家與人民之間的行政法律關係作有拘束力之具體化，以此行政處分為基礎（基礎處分），行政處分構成隨後之執执行程序之「執行名義」，從而所謂之行政執行，毋寧乃「行政處分之執行」。惟在遇有急迫情事，行政機關有立即採取強制手段之必要，無暇先作成行政處分，此種「無行政處分之行政強制」，不以人民行政法上義務之「執行名義化」為前置程序，而是在一種時間上及程序上皆予緊縮之集中過程中，「立即」以強制之方式達到義務履行之狀態，在德國學說上稱為「即時強制」（*sofortiger Zwang*）概念，在法制上除稱為「即時強制」外，亦有稱為「即時執行」（*sofortiger Vollzug*）或「直接執行」（*unmittelbare Ausführung*）。我國行政執行法所定之「即時強制」與此種嚴格意義之「即時強制」不同，應予區辨。

二、行為、不行為義務執行之制度構造，可概分為「法律基礎」、「執行名義」、「執行方法」及「執执行程序」四大部件。執行方法又可分為怠金、代履行、直接強制三類；而執执行程序包含告戒、執行方法之確定及執行方法之實施三個階段。至於「即時強制」則屬行政執行之一種類型，即「無執行名義之行政強制」，兼可運用代履行或直接強制二種方法。

三、行政執执行程序之開啟，「告戒」居於樞要地位，隨之依次為「執行方法之確定」與「執行方法之實施」，從程序構造以觀，可謂之「多階段之行政程序」，其旨在確保法之安定性，減緩行政強制之進行，以維民權。而在各階段中，復有產生新的行政處分

(基礎處分)，例如怠金之科處或代履行費用之核課，其自然亦有強制執行之問題，從而又派生出新的行政執行程序，故謂之「多層次之行政程序」。

四、基礎處分之程序與行政執行之程序，分屬不同階段，故行政執行之合法性，並非繫於基礎處分之合法性，而是決乎基礎處分之「有效性」與「可執行性」。「基礎處分之可執行性」，僅指基礎處分未經訴願機關或行政法院為停止執行之決定或裁定。對於基礎處分之救濟，義務人應在行政執行程序之外，依據訴願法及行政訴訟法之規定，謀求救濟。處分機關與執行機關若非同一，執行機關不得以基礎處分違法為由，拒絕執行，蓋應予執行之行政處分一旦生效，即對其他機關產生拘束力。基礎處分若已具形式之存續力(不可爭訟性)，除有回復原狀之情事，義務人僅能透過請求行政程序重開之方式，阻止執行之進行。

五、基礎處分作成或確定後，因事實或法律之變更，致原本有效、合法之基礎處分嗣後變成違法者，義務人雖得依據行政程序重開之規定，以行政處分所依據之事實或法律事後發生有利於其之變更，請求行政機關廢止該拆除處分(基礎處分)，行政機關若拒絕重新開啟程序，或行政機關雖重新開啟行政程序，並重新審究該行政處分，但仍維持原處分，則該義務人尚得提起行政爭訟，謀求救濟。然則，刻正進行之執行強制程序，並不因義務人對行政機關有關程序重開之決定提起爭訟而受影響，解決之道，有如下幾種可能性：1. 執行機關於此情形，例外不得開始執行或繼續執行。2. 將負擔處分之違法判斷時點，改為行政訴訟言詞辯論終結前。3. 申請行政程序重開之要件，不以行政處分確定為前提。4. 行政處分所依據之事實或法律事後發生有利於相關當事人之變更者，該當事人享有請求變更或廢棄該行政處分之權利。

六、基礎處分(執行名義)確定後，如有消滅或妨礙該處分請

求事項（義務）之事由發生，例如義務已全部履行，或行使公法上之抵銷者，義務人得依行政執行法第9條之聲明異議，執行機關若認為異議有理由者，即應停止執行之開始或續行；聲明異議若遭駁回者，義務人得循序提起撤銷在義務已履行之後所為之執行措施，同時亦得依行政訴訟法第8條第1項提出「不得執行之不作為請求訴訟」（eine Klage auf Unterlassung der Vollstreckung），並聲請行政法院為假處分之裁定，以定暫時之狀態，在行政法院作出本案裁判之前，暫時凍結執行政程序之續行。

七、告戒對於行政強制執行政程序之開啟，具決定性之規制作用，居於行政執行政程序之樞要地位，不容輕視。告戒對於「是否」及「如何」動用強制手段，具有拘束性之確認效力（執行機關若採取不同於告戒所載之強制方法，即構成違法），為行政強制執行後續階段之前提要件。是以，相對於基礎處分，告戒無疑是一獨立之行政處分，從而得為撤銷訴訟之程序標的。

八、「執行方法之確定」，指將告戒中所載之執行方法予以具拘束力之確定。例如確定怠金之金額，並科處之，或確定代履行費用之金額及義務人之繳納義務，應具行政處分之性質。質言之，怠金之確認，在性質上為「給付處分」，構成另一新的（公法上金錢給付義務之）執行政程序的執行名義。於代履行之情形，執行機關作成執行方法之確定時，始生義務人之繳納義務。於直接強制之情形，雖無類如怠金與代履行費用之課予金錢給付義務之規制作用，惟其對義務人確認即將動用直接強制手段時，實同時課予義務人「容忍」強制措施之義務。

九、於執行方法「實施」之階段，係將基礎行政處分所要求之義務（行為、不行為及容忍義務）予以貫徹（實現），其主要特徵在於，（心理上或物理上）壓制義務人之反抗意志。怠金之實施，表現在對所課怠金額度之「強制收取」，由此復開啟另一新的行政

強制執执行程序。通常先作成如命給付之處分，繼之以查封、拍賣等措施或強制取拿與怠金給付義務等值之財產，或佐以拘提管收、限制住居等間接強制方法。代履行之實施，可分為「代替義務人履行義務，以達與義務履行之相同狀態」與「收取代履行費用」二端。其中代履行費用之收取，寓有行為義務轉換為金錢給付義務之意。此一義務復以給付處分確定之，並得經由強制徵收之途徑予以執行，其情形如同怠金之強制徵收。直接強制之實施，例如警察動用警棍或以噴水方式驅散群眾，或以警力解除義務人對某一房屋之占有；又如主管機關命義務人不得於其所有土地上燃燒稻草，未獲遵從，乃逕予以澆熄等。直接強制之實施，是否具有行政處分之性質，頗具爭議，見解分歧，迄今未歇。德國實務早期見解不一，1967年2月9日，德國聯邦行政法院於一則人民請求確認警察之驅離命令及以警棍作為直接強制措施違法之訴訟事件（即所謂「施瓦本區騷動案」[Schwabinger Krawalle]），認定警棍之使用具行政處分之性質（BVerwGE 26, 161 ff.），自此成為實務上具有標竿作用之法律見解。

十、於即時強制之情形，不僅未經行政處分對於人民之義務為事前之確認，且在程序上亦省卻具有心理上強制之告戒與強制方法之確認，可謂是對人民權利干預最為強烈者，基於法治國原則及人民基本權利之保障，即時強制必須是一種最後手段。從行政執行之程序構造以觀，即時強制係行政機關直接進入動用強制手段之階段，故即時強制同於「強制方法之實施」。即時強制之法律性質，須視義務人是否在場而定。若義務人在場，則應同於前開直接強制及代履行之性質，亦即兼有物理行為及規制作用；反之，若義務人不在場，則應屬事實行為。

十一、行政執行措施致第三人權利受有損害者，因行政執行乃典型之公權力措施，具有公法性質，殆應無疑，故第三人之權利因執行措施而受有損害，例如執行人員誤認第三人之財產為義務人之

財產而予查封，亦應屬於公法上之爭議。又，第三人就執行標的物有足以排除執行之權利者，例如執行機關查封義務人之房屋，而第三人主張該房屋為其所有之情形，所生爭議亦屬公法性質。蓋造成第三人權利受到侵害，且為第三人所爭執者，乃執行機關之「查封」措施，而非義務人之行為。行政執行措施致第三人權利受有損害，屬公法上之爭議，除法律別有規定外，應由行政法院審理之。是以，行政執行法施行細則第18條規定依強制執行法第15條規定向管轄法院提起民事訴訟，即有違反上開行政訴訟法規定之嫌，蓋其並非「法律」。惟查行政執行法第26條規定：「關於本章之執行，除本法另有規定外，準用強制執行法之規定。」所謂「關於本章之執行」，即指公法上金錢給付義務之執行，故上開施行細則之規定，應係行政執行法第26條規定之具體化，尚不生違背法律之問題。

十二、行政執行已執行完畢，義務人或利害關係人若認為其權利因行政執行而受有侵害者，其救濟方法因義務人指摘基礎處分違法，抑或指摘執行行為違法而有不同。主張「基礎處分」違法者，義務人若於法定期間內，依法對基礎處分提起撤銷訴訟者，得依行政訴訟法第196條第1項規定，聲請行政法院為撤銷行政處分判決時，命行政機關為回復原狀之必要處置。不過，基礎處分若因執行完畢而消滅（解決）者，即不得提起撤銷訴訟，而應依行政訴訟法第6條第1項後段規定，提起行政處分違法確認訴訟；若於撤銷訴訟進行中發生基礎處分已執行而消滅者，得依行政訴訟法第196條第2項規定，聲請行政法院確認該行政處分為違法。主張「執行行為」違法者，須區分執行行為之法律性質為行政處分，抑或事實行為。執行行為若屬行政處分，則視該執行行為是否因執行完畢而消滅（解決），而循前述之訴訟途徑救濟之。執行行為若屬事實行為者，因現行行政訴訟法並無「確認行政事實行為違法之訴」，故須類推適用行政訴訟法第6條第1項後段之行政處分違法訴訟之規定。

本文開篇即言，現行之行政執行法，較之舊制，雖已有大幅度

的興革，但行政執行新法實施至今，學理上仍有諸多爭議，司法實務上亦面臨諸多疑問未解，或存有歧見待清，行政執行法制未臻完備之處，斑斑可見。本文以相當篇幅探討基礎處分之合法性問題及其與行政執行救濟之間的關聯，乃出於時下對於基礎處分與行政執行之間的分野與連動關係，頗多混淆、誤解，或處於未知狀態。就行政執行之救濟體系而言，基礎處分與執行行為之間「既分又聯」的關係¹⁷⁹，實為探討行政救濟體系的核心課題，若不辨明基礎處分與執行行為之分際，無以細究行政執行救濟體系及保障內涵，實務上經常在基礎處分與執行行為之間雜纏不清，以致無法準確掌握行政執行救濟問題的要害，進而開展行政執行的救濟架構，其病因在此。若謂此等實體問題與本文的主題「行政執行救濟體系」之間的連結度不強，不是出於對行政執行法理與救濟問題的錯誤認知，就是對行政執行救濟問題的理解不夠通透，故只能在表象性的救濟問題上打轉，此正是當前臺灣行政執行救濟法制與學說實務的通病¹⁸⁰。

179 基礎理論及問題探討，參見Ralf Poscher, *Verwaltungsakt und Verwaltungsrecht in der Vollstreckung*, VerwArch 89 (1998), S. 111 (111 ff.).

180 關此問題，作者於文中舉有適例，試予呈現，茲此文末，不憚叨絮，再舉一例，用以證之，事實略以：上訴人（某人民）於嘉義市某地號（下稱系爭土地）河川公地種植高莖作物，前經經濟部水利署第五河川局（被上訴人）以其位於河川區域內，為維護河防安全，分別於95年3月31日及95年6月1日函知上訴人，載明系爭土地位於河川區域內，並分別命上訴人於95年4月30日及95年6月20日以前自行剷除所種植之高莖作物，亦即認定上訴人於河川區域內違法種植高莖作物，應予剷除，並限期命其自行剷除。上訴人於收受前揭處分後，未提起訴願，以求救濟。嗣上訴人於96年1月27日再向被上訴人提出陳情，被上訴人於96年2月9日函復略謂：「說明：本案仍請台端儘速於96年3月15日前自行拆除，逾期本局訂於96年3月15日依法強制執行剷除，以維河防安全。」上訴人對96年2月9日函不服，提起行政訴訟。爭訟程序進行中，河川局於96年3月15日僱請民間承包商將系爭土地之果樹剷除。本案爭點之一為：96年2月9日函的法律性質為何？歷經數審，最高行政法院的主要見解如下：最高行政法院97年度裁字第4831號裁定謂：「（按：96年2月9日函）說明欄記載仍請抗告人儘速於96年3月15日前自行剷除該高莖作物，逾期相對人訂於96年3月15日依法強制執行剷除等語，則業已變更先前處分之法律狀態，亦即相對人重新為實體上審查，發現抗告人並未依先前處分之期限自行剷除該高莖作物，乃有所處置，即變更抗告人自行剷除之期限，否則相對人將如期依法

推究其原因，與行政法學界在此領域之耕耘不足有關，尤其常有行政救濟法「純屬」程序法的迷思與誤解¹⁸¹，而行政法院長期以來拒絕審理行政執行之訴訟事件，亦難脫干係。所幸，最高行政法院

強制執行剷除，以維河防安全；此係相對人就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為，為全新之行政處分。」

最高行政法院100年度判字第1469號判決：「本件原處分乃命上訴人自行剷除種植於系爭土地上之作物，核屬行政執行事件，自當適用行政執行法之規定。」

同上判決：「依行政執行法第29條第1項規定可知，負有行為義務而不為者，其行為能由他人代為履行者，執行機關得委託第三人或指定人員代履行之。是本件由被上訴人僱請民間承包商代為履行剷除作物之義務，並無不合。」

同上判決：「復依行政執行法第9條第1項規定：『……（略）。』同條第3項規定：『……（略）。』則本件行政執行，上訴人如對於執行方法如有意見，乃就行政執程序或方法聲明異議之程序問題，縱該執程序有瑕疵，亦屬執程序進行適法與否之問題，不影響原處分之適法性。」

以上關於96年2月9日函是否具行政處分法律性質及後續剷除果樹救濟問題的法律見解，最主要的問題出在未能準確區辨「基礎處分」與「執行行為」二種概念，也就是96年2月9日函究竟為基礎處分（課予剷除作物之義務）？抑或執行行為（實現剷除作物義務之措施）？判決理由中所謂「變更自行剷除之期限」，究係針對「基礎處分」而言，抑或「執行行為」？若屬後者（判決中一再引用行政執行法之規定，且稱本件係屬行政執行事件），則其所稱「全新之行政處分」，又究何所指？此外，判決中稱「原處分……核屬行政執行事件，自當適用行政執行法之規定」、「不影響原處分之適法性」，其中之「原處分」是否為「基礎處分」？若為「基礎處分」，何以及如何適用行政執行法之規定？凡此均顯示「基礎處分」與「執行行為」夾雜不清之現象，若不予以廓清，無以建立清晰的行政執行救濟體系。

- 181 實則，行政救濟法的內涵與課題，原本即是「程序法」與「實體法」的交錯，實體法面向討論的比重雖不宜大過程序法，卻是探討行政救濟法不可或缺的一環，甚至行政救濟法的真正棘手問題，均集中在實體法的基本觀念。諸如訴訟標的之範圍、行政處分之是否消滅（行政處分違法確認訴訟之程序合法要件之一）、訴訟權能之有無（所有訴訟類型之程序要件）、權利保護之必要、課予義務訴訟「依法申請案件」之意涵、一般給付訴訟之適用範圍（公法上結果除去請求權之承認）、行政處分之概念（撤銷訴訟之程序標的）、公法上法律關係之意涵（公法上法律關係確認訴訟之要件要素及備位性原則的適用）等，無一不是屬於行政實體法面向的問題。我國行政法學理與實務常有行政救濟法「純屬」程序法的迷思與誤解（例如所謂「救濟體系的本質是程序；如果納入太多實體面的課題，將使得救濟體系失去清晰的輪廓」之言），以致在行政訴訟法問題討論上失之膚淺、甚或時常發生誤差或無法深中肯綮（例如從程序法之規定反推出實體法之結論），這種現象同時也是我國行政救濟法始終無法進步的主要原因之一。

於2008年12月透過庭長法官聯席會議，幡然改變舊例，使行政執行之相關公法爭議及權利救濟事項，得以獲得行政法院的審理與裁判。行政執行法制、學理與實務間之交互印證、彼此攻錯，殆可預期。臺灣行政執行法治的深化，刻正起步，行政強制執行法學的開展，此其時也。

本文以現行規範為本，參採國外法制與學說，耙梳剖析行政執行救濟之諸般問題，並嘗試建立法律體系與思維架構，期能有助於臺灣行政強制體系與救濟制度之建置，提供實務運作及司法審判之參考，更祈能進一步地促使相關法制之研修，以完備臺灣行政法制，發揮人權保障之功能。

參考文獻

1. 中文部分

- 吳庚（2007），行政法之理論與實用，增訂10版，臺北：元照。
- 吳志光（2010），行政程序重新進行之要件，台灣法學雜誌，150期，頁69-73。
- 李建良（1995），違規車輛拖吊及保管之法律問題——兼論行政強制執行基本體系之再構成及其相關問題，政大法學評論，53期，頁127-160。
- （1995），因執行違規車輛拖吊及保管所生損害之國家賠償責任——兼論委託私人行使公權力之態樣與國家賠償責任，中興法學，39期，頁85-133。
- （1998），行政執行，收於：翁岳生編，行政法（下），頁873-940，臺北：元照。
- （1999），行政上即時強制之研究，收於：國立政治大學法學院編，1998年海峽兩岸行政法學術研討會實錄，頁232-282，臺北：國立政治大學法學院。
- （2000），論行政處分之違法判斷基準時——以訴願審理程序為中心，收於：台灣行政法學會編，行政法爭議問題研究（下），頁907-934。臺北：五南。
- （2000），訴願程序之違法判斷基準時，月旦法學雜誌，64期，頁22-23。
- （2001），論行政訴訟強制執行之基本體系，臺北大學法學論叢，49期，頁61-122。
- （2002），行政訴訟強制執行之救濟體系——以司法執行程序為中心，東吳法律學報，13卷2期，頁31-60。
- （2002），行政處分的「解決」與行政救濟途徑的擇定，台

灣本土法學雜誌，40期，頁105-115。

- （2007），台灣行政訴訟法制之沿革、演進與發展課題，收於：湯德宗、王鵬翔編，2006兩岸四地法律發展（上），頁259-336，臺北：中央研究院法律學研究所籌備處。
 - （2008），論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題——兼評最高行政法院93年度判字第628號、95年度第1421號判決及其相關判決，收於：黃舒芃編，2007年行政管制與行政爭訟，頁29-104，臺北：中央研究院法律學研究所籌備處。
 - （2009），試論行政執行之債務人異議之訴——兼評最高行政法院97年5月份第1次庭長法官聯席會議決議，收於：王必芳編，2008行政管制與行政爭訟，頁127-166，臺北：中央研究院法律學研究所籌備處。
 - （2010），行政罰法中「裁罰性之不利處分」的概念意涵及法適用上之若干基本問題——「制裁性不利處分」概念之提出，月旦法學雜誌，181期，頁133-163。
 - （2011），環評程序與行政訴訟：美麗灣渡假村環評案，台灣法學雜誌，176期，頁25-48。
- 李震山（1997），行政法導論，臺北：三民。
- 林三欽（2001），訴願案件之違法判斷基準時，台灣本土法學雜誌，23期，頁1-16。
- （2006），論行政訴訟之判斷基準時——兼評最高行政法院94年度判字第588號判決，收於：湯德宗、劉淑範編，2005行政管制與行政爭訟，頁41-73，臺北：中央研究院法律學研究所籌備處。
- 林明昕（2002），一般形成訴訟——德國行政訴訟法上之爭議問題，收於：翁岳生教授祝壽論文編輯委員會編，當代公法新論（下）——翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集，頁79-97，臺北：元照。
- （2003），論訴願之再審與行政處分之廢棄——一道介乎行

- 政爭訟法與行政程序法之間的法學課題，收於：公法學的開拓線——理論、實務與體系之建構，頁289-317，臺北：元照。
- 林錫堯（2006），行政法要義，3版，臺北：元照。
- 林樹埔（2010），行政程序法第128條程序重開之理論與實務，法令月刊，61卷2期，頁76-86。
- 林素鳳（2005），程序重新、訴願再審與再審之訴——兼評台北市政府九十一年十月十六日府復字第○九一一九○二七五○一號復審決定，月旦法學雜誌，118期，頁199-213。
- 洪家殷（1992），論行政處分程序之再度進行——以德國一九七六年行政程序法第五十一條之規定為中心，政大法學評論，45期，頁305-350。
- （2009），有持續效力之行政處分與行政處分程序之重新進行，台灣法學雜誌，125期，頁143-148。
- 許宗力（2000），行政處分，收於：翁岳生編，行政法（上），頁475-558，臺北：元照。
- 許登科（2003），論撤銷訴訟中行政處分之違法判斷基準時，法學叢刊，48卷2期，頁61-75。
- （2003），論訴願再審之程序標的及訴願再審決定之救濟——以評釋行政院台九十訴字第○四五一二一號決定為中心，月旦法學雜誌，92期，頁110-128。
- 黃俊杰（2010），行政法實務講座：第四講——程序重新，月旦法學教室，95期，頁26-34。
- 傅玲靜（2007），論行政程序之重新進行——以遺產稅之核課與剩餘財產差額分配請求權價額之扣除為例，月旦法學雜誌，147期，頁101-120。
- 陳敏（2011），行政法總論，7版，臺北：新學林。
- 陳新民（1997），行政法學總論，修訂6版，臺北：三民。
- 陳清秀（2011），情事變更與課稅處分之違法判斷基準時／最高行89判1265，台灣法學雜誌，179期，頁169-176。

- 陳淑芳(2007)，撤銷訴訟之裁判基準時點，台灣本土法學雜誌，90期，頁54-78。
- 陳愛娥(2010)，撤銷訴訟中判斷行政處分合法性之基準時與行政法院對行政函釋的審查權——評臺北高等行政法院九十八年度簡字第五二九號判決，月旦裁判時報，1期，頁25-30。
- 程明修(2009)，是否重開行政程序之決定均為行政處分／最高行九七裁五四〇六，台灣法學雜誌，125期，頁209-210。
- (2012)，行政程序法上有關行政處分撤銷與程序重新進行之規範改正，法學叢刊，57卷3期，頁67-109。
- 彭鳳至(2004)，論法律不溯既往原則之適用與誤用——以七十四年增訂、九十一年修正民法第一〇三〇條之一第一項之適用為例，月旦法學雜誌，104期，頁68-92。
- 彭鳳至主持，陳清秀報告(2009)，行政訴訟上事實及法律狀態之裁判基準時，行政訴訟法研究會第十二次研討會，台灣法學雜誌，125期，頁38-91。
- (2003)，論確認訴訟之備位功能：行政訴訟法第六條第三項之意涵與本質，人文及社會科學集刊，15卷1期，頁59-112。
- 詹鎮榮(2011)，行政程序重新進行之程序標的——以我國及德國行政法院相關裁判為中心，東吳公法論叢，4期，頁211-261。
- (2011)，行政程序重新進行之程序標的——我國與德國法制之比較，東吳法律學報，23卷1期，頁95-134。
- 劉建宏(2011)，既判力與行政程序重開及違法行政處分之撤銷，台灣法學雜誌，187期，頁46-64。
- (2012)，稅捐行政程序重開之探討，當代財政，14期，頁28-37。
- 劉淑範(1997)，水土保持法第二十七條「警察職權」之現行適用相關問題與立法商榷，收於：行政院農業委員會、國立臺灣大學編，水土保持法技師簽證、代履行及警察職權問題之研究，八十五年度水土保持及集水區經營研究計畫成果彙編，頁599-

600，臺北：行政院農業委員會、國立臺灣大學。

蔡宗珍（2008），公法上無主義務之強制執行？——評司法院大法官釋字第621號解釋，中研院法學期刊，2期，頁275-314。

蔡茂寅（1999），怠金處分之救濟，月旦法學雜誌，50期，頁14-15。

蔡震榮（2006），行政執行法，收於：翁岳生編，行政法（下），3版，頁157-264，臺北：元照。

賴恆盈（2011），論行政訴訟之裁判基準時，政大法學評論，121期，頁223-312。

2. 西文部分

App, Michael (1991), Die Verwaltungsvollstreckung im Baurecht, JA, S. 351-355.

—— (1991), Verwaltungsvollstreckung im Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, WUR, S. 249-257.

App, Michael/Wettlaufer, Arno (2005), Verwaltungsvollstreckungsrecht, 4. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München: Carl Heymanns.

Birk, Rolf (1967), Die Festsetzung des Zwangsgeldes nach dem Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz, BayVBl., S. 124-127.

Bleckmann, Albert/Eckhoff, Rolf (1988), Der „mittelbare“ Grundrechtseingriff, DVBl., S. 373-382.

Brühl, Raimund (1997), Die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungszwangs im gestreckten Verfahren, JuS, S. 926-932.

—— (1998), Die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungszwangs im gestreckten Verfahren, JuS, S. 65-70.

Buch, Ottweiler (1913), Das nichtkodifizierte Verwaltungszwangsrecht in Preußen. Ein Beitrag zur Lehre von den gewaltrechtlichen Verwaltungsakten und ihrer Verwirklichung, AöR 31, S. 326-437.

Burmeister, Joachim (1989), Die Ersatzvornahme im Polizei- und

- Verwaltungsvollstreckungsrecht, JuS, S. 256-262.
- Dietlein, Johannes (1991), Verwaltungszwang gegen Unbekannte, NWVBl., S. 81-86.
- Drews, Bill/Wacke, Gerhard/Vogel, Klaus/Martens, Wolfgang (1986), Gefahrenabwehr, 9. Aufl., Köln: Heymanns.
- Engelhardt, Hanns/App, Michael (1992), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz: Kommentar unter besonderer Berücksichtigung der landesrechtlichen Bestimmungen, 3. Aufl., München: C. H. Beck.
- Erichsen, Hans-Uwe (1989), Die Fortsetzungsfeststellungsklage, Jura, S. 49-52.
- (2002), in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Aufl., Berlin: Gruyter, S. 270-301.
- Erichsen, Hans-Uwe/Rauschenberg, Dirk (1998), Rechtsschutz in der Verwaltungsvollstreckung, Jura, S. 323-328.
- Felix, Dagmar (2003), Der Verwaltungsakt mit Dauerwirkung – eine sinnvolle Kategorie des Allgemeinen Verwaltungsrechts?, NVwZ, S. 385-390.
- Fischer, Peter (1980), Rechtsschutz gegen die Vollstreckung aus Verwaltungsakten - Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, BayVBl., S. 173-176.
- Fleiner, Fritz (1913), Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck.
- Forsthoff, Ernst (1966), Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 9. Aufl., München: C. H. Beck.
- Friauf, Karl Friedhelm (1992), Polizei- und Ordnungsrecht, in: von Münch/Badura (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 9. Aufl., Berlin: Gruyter, S. 97-178.
- Gaul, Hans Friedhelm (1979), Die Mitwirkung des Zivilgerichts an der

Vollstreckung von Verwaltungsakten und verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen, JZ, S. 496-511.

Gerhardt, Michael (2011), in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 22. Ergänzungslieferung, München: C. H. Beck, § 113 Rn. 1-109.

Glaeser, Walter Schmitt/Horn, Hans-Detlef (2012), Verwaltungsprozeßrecht, 16. Aufl., München: C. H. Beck.

Götz, Volkmar (2008), Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 14. Aufl., München: C. H. Beck.

Henneke, Hans-Günter (1989), Verwaltungszwang mittels Zwangsgeld, Jura, S. 7-20.

Hormann, Klaus (1988), Die Anwendung von Verwaltungszwang unter Abweichung vom Regelvollstreckungsverfahren, Frankfurt/Main: Peter Lang.

Hufen, Friedhelm (2008), Verwaltungsprozessrecht, 7. Aufl., München: C. H. Beck.

Jellinek, Walter (1948), Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Offenburg: Lehrmittel-Verl.

Kleinlein, Kornelius (1990), Der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten, VerwArch 81, S. 149-192.

König, Hans-Günther (1967), System des verwaltungsbehördlichen Vollstreckungsrechts, BayVBl., S. 262-268.

Kopp, Ferdinand O./Ramsauer, Ulrich (2010), Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 11. Aufl., München: C. H. Beck.

Kopp, Ferdinand O./Schenke, Wolf-Rüdiger (2009), Verwaltungsgerichtsordnung, 16. Aufl., München: C. H. Beck.

Krause, Peter (1974), Rechtsformen des Verwaltungshandelns, Berlin: Duncker & Humblot.

- Kreiling, Harald (1963), Rechtsbehelfe gegen Beitreibungsmaßnahmen im Verwaltungsvollstreckungsrecht, NJW, S. 888-891.
- Kugelman, Dieter (1997), Die unmittelbare Ausführung und die sofortige Anwendung von Verwaltungszwang, DÖV, S. 153-160.
- Lemke, Hanno-Dirk (1997), Verwaltungsvollstreckungsrecht des Bundes und der Länder, Baden-Baden: Nomos.
- Lorenz, Dieter (1971), Die Folgepflicht gegenüber rechtswidrigen Verwaltungsakten und die Strafbarkeit des Ungehorsams, DVBl., S. 165-172.
- Malmendier, Bertrand (2003), Die Zwangsmittelfestsetzung in der Verwaltungsvollstreckung des Bundes und der Länder, VerwArch 94, S. 25-47.
- Martens, Joachim (1968), Zur Begriffsbestimmung des Verwaltungsaktes, DVBl., S. 322-330.
- Maurer, Hartmut (2009), Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Aufl., München: C. H. Beck.
- Mayer, Otto (2004), Deutsches Verwaltungsrecht (1924), Neudruck Bd. I, 3. Aufl., München: Duncker & Humblot.
- Menger, Christian-Friedrich (1954), System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Menger, Christian-Friedrich (1977), Höchststrichterliche Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht, VerwArch 68, S. 293-299.
- Meyer, Hans/Borgs-Maciejewski, Hermann (1982), Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Frankfurt am Main: Metzner.
- Neumann, Siegfried (1957), Die Anfechtung formeller Verwaltungsakte, insbesondere der Festsetzung von Zwangsmitteln: Zur Vollziehung von Verwaltungsakten, DVBl., S. 304-306.
- Oldiges, Martin (1989), Kostenerstattung einer Gemeinde für polizeiliche Gefahrenabwehr, JuS, S. 616-623.

- Ossenbühl, Fritz (1979), Die Handlungsformen der Verwaltung, JuS, S. 681-687.
- Pietzner, Rainer (1991), Unmittelbare Ausführung als fiktiver Verwaltungsakt, VerwArch 82, S. 291-306.
- (1993), Rechtsschutz in der Verwaltungsvollstreckung, VerwArch 84, S. 261-285.
- Pietzner, Rainer/Ronellenfitsch, Michael (1993), Das Assessorexamen im Öffentlichen Recht, 8. Aufl., München: C. H. Beck.
- Poscher, Ralf (1998), Verwaltungsakt und Verwaltungsrecht in der Vollstreckung, VerwArch 89, S. 111-136.
- Rachor, Frederik (2012), Das Polizeihandeln, in: Lisken/Denninger (Hrsg.), Handbuch des Polizeirechts, 5. Aufl., München: C. H. Beck, S. 284-601.
- Rasch, Ernst (1992), Der Realakt insbesondere im Polizeirecht, DVBl., S. 207-212.
- Redeker, Konrad/von Oertzen, Hans-Joachim (1975), Verwaltungsgerichtsordnung/Kommentar, 5. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer.
- Renck, Ludwig (1970), Verwaltungsakt und Feststellungsklage – BVerwGE 26, 161, JuS, S. 113-118.
- Rozeck, Jochen (1995), Grundfälle zur verwaltungsgerichtlichen Fortsetzungsfeststellungsklage, JuS, S. 414-418.
- Rudolph, Inge (1992), Das Zwangsgeld als Institut des Verwaltungszwangs, Frankfurt/Main: Peter Lang.
- Sandler, Gerhard (2000), Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Kommentar anhand der Rechtsprechung, 4. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.
- Schäfer, Peter (1989), Zur Rechtsnatur der unmittelbaren Ausführung nach Art. 9 Abs. 1 PAG – Verwaltungsakt oder Realakt?, BayVBl.,

S. 742-745.

Schenke, Wolf-Rüdiger (1970), Vollstreckungsrechtsschutz gegen Verwaltungsakte bei nach Bestandskraft entstandenen Einwendungen gegen den zu vollstreckenden Anspruch, VerwArch 61, S. 260-273, 342-374.

—— (1985), Die Fortsetzungsfeststellungsklage, in: Erichsen/Hoppe/Mutius (Hrsg.), System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes: Festschrift für Christian-Friedrich Menger zum 70. Geburtstag, Köln: Heymann, S. 461-486.

—— (1995), Polizei- und Ordnungsrecht, in: Steiner/Arndt (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Heidelberg: Müller, S. 175-373.

—— (1996), Rechtsprechungsübersicht zum Verwaltungsprozeß – Teil 3, JZ, S. 1103-1119.

Schenke, Wolf-Rüdiger/Baumeister, Peter (1993), Probleme des Rechtsschutzes bei der Vollstreckung von Verwaltungsakten, NVwZ, S. 1-11.

Schmidt, Jörg (2010), in: Eyermann/Fröhler (begr.), Verwaltungsgerichtsordnung: Kommentar, 13. Aufl., München: C.H.Beck, § 113, S. 461-486.

Schmidt-Aßmann, Eberhard (2006), Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungs idee, 2. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York: Springer.

Schoch, Friedrich (2011), in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 22. Ergänzungslieferung, München: C. H. Beck, § 80 Rn. 1-600.

Schübel-Pfister, Isabel (2012), Aktuelles Verwaltungsprozessrecht, JuS, S. 420-425.

Skouris, Wassilios (1974), Die amtliche Bekanntgabe als Wirksamkeitsvoraussetzung empfangsbedürftiger Verwaltungsakte,

VerwArch 65, S. 264-290.

Söhn, Hartmut (1973), Steuerrechtliche Folgenbeseitigung durch Erstattung - zugleich ein Beitrag zum Steuerschuldverhältnis, München: C. H. Beck.

Stelkens, Paul (1983), Verpflichtung zur Duldung – Notwendigkeit einer Duldungsanordnung?, Natur+Recht, S. 261-264.

Stelkens, Ulrich (2008), in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 7. Aufl., München: C. H. Beck, Rn. 1-376.

Thoma, Richard (1906), Der Polizeibefehl im Badischen Recht: Dargestellt auf rechtsvergleichender Grundlage, Tübingen: Mohr Siebeck.

Traulsen, Hans-Dietrich (1971), Die Rechtsbehelfe im Verwaltungsvollstreckungsverfahren, Berlin: Duncker & Humboldt.

Vahle Jürgen (1994), Der sofortige Vollzug im Verwaltungsvollstreckungsrecht – Begriff, Voraussetzungen, Prüfungsschemata, DVP, S. 91-96.

Wegmann, Bernd (1985), Rechtsschutzprobleme im Bayerischen Polizeirecht, BayVBl., S. 417-423.

Wehr, Matthias (2007), Der Verwaltungsakt mit Dauerwirkung, BayVBl., S. 385-391.

Weiß, Wolfgang (2001), Gibt es einen Rechtswidrigkeitszusammenhang in der Verwaltungsvollstreckung?, DÖV, S. 275-285.

Wolff, Hans J./Bachof, Otto (1974), Verwaltungsrecht, Bd. I, 9. Aufl., München: C. H. Beck.

——— (1978), Verwaltungsrecht, Bd. III, 4. Aufl., München: C. H. Beck.

Wolff, Hans J./Bachof, Otto/Stober, Rolf/Kluth, Winfried (2010), Verwaltungsrecht, Bd. 2, 7. Aufl., München: C. H. Beck.